NARS 정책연구용역보고서

이 보고서는 국회입법조사처의
정책연구용역사업에 의한 것임.

해외 통신시장 사후규제 사례 연구
- 이중규제 해소방안을 중심으로 -

연구책임자
이 영 대(법무법인 수호)
최경규(동국대학교 경영대학)

2013. 7. 31.

제 출 문

국회 입법조사처장 귀하

본 보고서를 「해외 통신시장 사후규제 사례 연구 -이중규제 해소방안을 중심으로」 연구용역의 최종보고서로 제출합니다.

2013년 7월

이 영 대(법무법인 수호)
최 경 규(동국대학교 경영학과)

□ 요약

통신시장이 공익 독점의 체제에서 시장경쟁 체제로 전환되어 사업법 상 규제와 경쟁법 상 규제가 공존하게 되면서, 종종 양 규제가 중첩되어 이중규제의 양상을 띠게 된다. 이는 사업자의 입장에서 감독관청 관할의 중복 혹은 양립으로 규제의 위험이 높아지고, 기업의 생산비용 증가를 초래한다.

본 연구는 우리나라, 미국, 유럽연합, 일본 등에서 실제로 일어났던 법적 분쟁 사례에서 각국의 법원이 보여준 이중규제 관할권과 적용법 배분의 원칙을 정리하여 합리적인 규제 공존의 방안을 모색하고, 나아가 해석론을 입법론으로 발전시켜 바람직한 대안을 제시한다.

먼저 미국, 일본, 유럽연합의 각국의 사업법적 규제에 관한 입법례와 판례를 살펴보면, 인가약관 적법성 추정의 원칙 등에 따른 사업법적 규제의 적법성 추정, 독점의 지렛대 원리 등을 통한 수직 통합적·업종 종단형의 규제, 시장에서의 경쟁제한성에 초점을 두는 미시경제적 규제의 관점에서 벗어나 정치·경제·문화·지역사회를 아우르는 거시경제적 관점에서의 규제 등을 통하여 사업법과 경쟁법의 중복규제 및 권한 배분의 문제를 극복하려는 시도들을 찾을 수 있다.

더 나아가 사업법이 적용된 각국의 판례를 검토해 보면, 통신사업자와 계약을 하는 다른 사업자 또는 최종 소비자가 원고로서 제기하는 약관의 조건 등에 관한 민사소송에서는, 인가약관 적법성 추정의 원칙 등이 적용되고, 사업법 규제 당국을 피고로 하는 행정소송의 경우는 사업법 당국의 규제를 재량행위로 보아, 그 위법성에 대한 엄격한 입증이 요구되기 때문에 권리구제에 어려움이 따르는 것을 알 수 있다. 이러한 난점을 극복하기 위해 각국의 법정에서는 경쟁법 위반 소송이 시도되는데, 이 경우도 대부분 시장에서의 경쟁 자체가 전체적으로 저해되는 효과를 입증하기 어려운 경우가 많다. 더 나아가 최종 소비자가 제기하는 소송의 경우에는 나아가 위 경쟁저해 효과가 최종 소비자에 피해로 연결됨을 입증해야 하므로 원고의 승소 가능성은 매우 낮다고 할 것이다.

결국 사업법 위반을 청구원인으로 하는 소송에서나 경쟁법 위반을 청구원인으로 하는 소송에서 권리구제가 되는 유력한 방법은 규제 당

국이 위반 사업자가 소송 당사자가 되는 행정소송이라고 할 것인데, 문제는 결국 규제 당국만이 법원의 사후규제를 촉발하는 당사자가 될 뿐, 직접 피해자인 경쟁사업자나 최종 소비자는 이러한 권리구제의 절차에서 벗어나 있는 현실이다.

따라서 경쟁사업자나 최종 소비자의 행정 소송의 당사자 적격을 확대하는 입법적 방안의 도입이 필요하다. 이는 행정소송에서 권리보호의 법익 확장을 통해 원고 적격을 확대하는 흐름에도 부합한다고 할 것이다. 사업법 위반 사실에 대해, 그 위반 사실로 피해를 받은 경쟁사업자나 최종 소비자는 사업법 규제 당국의 인가 취소 등 적절한 행정처분을 구하고, 만일 위 신청이 거부되면, 그 이행을 구하는 행정소송을 제기할 수 있어야 한다. 실제로 사업법상 인가에는 거시경제적 규제 요소가 심사되므로, 그 내용을 구성하는 최종 소비자 보호는 단순한 반사적 법익의 범주를 이미 벗어난다고 할 것이다.

그러나 보다 실천적인 대안은 실제 소송에서 구체적인 구제절차를 강화하는 것이라고 할 것이다. 종래의 인가의 적법성을 추정하는 전통적 해석 방안을 토대로, 경쟁자 보호에서 경쟁 보호로의 입증책임의 완화, 특정 시장에서의 독점력의 관련 시장으로의 전이에 관한 법률상 추정 등 절차적 편의주의를 통해 통신 사건의 입증에 있어서의 정보 비대칭을 치유하는 입법적 결단이 요구되며, 이러한 입증책임의 전환이야말로 실질적인 권리구제의 효과를 확보하는 요체가 된다고 할 것이다.

차 례

Ⅰ. 서론 1

1. 통신시장에서의 사후규제 강화 및 이중규제의 문제점 1

2. 사후규제의 관할권 배분 문제 2

3. 비교법적 연구 및 경제법학적 연구 3

Ⅱ. 우리나라 통신시장의 규제 현황 5

1. 사업법 상 규제 5
가. 「정부조직법」 개정에 따른 규제 주체의 변화 5
나. 진입/퇴출 규제 6
다. 요금/약관 규제 8
라. 비대칭 규제 8
마. 거시경제적 규제 9

2. 경쟁법 상 규제의 공존 13
가. 규제의 경합 13
나. 중복규제 16
다. 통신시장 행정 소송의 기본 구조 19
라. 행정지도가 개입된 가격담합 시 경쟁법상 규제 22

Ⅲ. 미국 통신시장의 사업법 규제 25

1. 미국 사업법상 규제 형식 25
가. 공익 독점 시대에서의 규제 25
나. 수정최종판결(Modified Final Judgement) 체제 35
다. 「1996 통신법(Telecommunications Act of 1996)」의 규제 39

2. 미국 사업법 적용의 구체적 사례 47
가. 공익독점시대 하의 사례 47
나. 수정최종판결(MFJ)체제 하에서의 사례 50
다. 「통신법(Telecommunications Act of 1996)」적용의 사례 58

3. 미국 사업법 판례분석 67
가. 사업법 위반의 민사 사건 67
나. 사업법 위반의 행정 사건 68

Ⅳ. 미국 통신시장에 대한 경쟁법 규제 69

1. 미국 경쟁법의 규제형식 69
가. 중복 규제 69
나. 통신법의 진화 70

2. 미국 경쟁법 적용의 구체적 사례 76
가. 요약 76
나. 구체적인 내용 79

3. 미국 경쟁법 위반 판례 분석 90
가. 소비자 제기 경쟁법 위반 소송 90
나. 경쟁자 제기 경쟁법 위반 소송 91
다. 판례의 동향 92

Ⅴ. 일본 통신시장의 규제 94

1. 일본 사업법의 규제 형식 94
가. 비대칭규제 94
나. 업종 종단적 규제 97
다. 규제의 독립성 99
라. 중복 규제의 실제 100
마. 사업법의 진화 101

2. 일본의 전기통신사업 관련 구체적 사례 104
가. 요약 104
나. 구체적인 내용. 106

3. 일본 판례에 대한 분석 114

Ⅵ. 유럽 통신시장의 규제 115

1. 유럽 전기통신사업과 경쟁법 115

2. SMP 이론 116

3. 회원국 규제 118
가. 독일 118
나. 영국 120

4. 유럽연합 전기통신사업관련 구체적 사례 120
가. 요약 120
나. 구체적 내용 122

5. 유럽연합 판례분석 128

Ⅶ. 입체적 규제분류를 통한 입법방안의 제시 130

1. 행정재량에서 계약재량으로 130
가. 행정재량 130
나. 계약재량 131

2. 미시경제적 규제에서 거시경제적 규제로 132
가. 미시경제적 규제 132
나. 거시경제적 규제 133

3. 착취남용 규제에서 종단통합 규제로 134
가. 착취남용 규제 134
나. 수직적 종단통합형 규제로 135

4. 일반 규정에서 구체적 규정으로 136
가. 일반 규정 136
나. 구체적 규정 137

5. 실체적 경합에서 상상적 경합으로 138
가. 실체적 경합 138
나. 상상적 경합 138

6. 경쟁자 보호에서 소비자 보호로 139
가. 경쟁자 보호 139
나. 소비자 보호 140

Ⅷ. 맺음 (입법의 방향성 제시) 142

Ⅸ. 참고문헌 145

표 차 례

[표 1] 공법상 특허가 7
[표 2] 사업법과 경쟁법의 중복규제 현황 17
[표 3] 인가(license) 소유 여부 26
[표 4] 공익독점시대 하의 사례 요약 47
[표 5] MFJ 체제 하의 사례 요약 50
[표 6] 1996년 통신법 하의 사례 요약 58
[표 7] 사업법 위반 민사사건 요약 67
[표 8] 사업법 위반 행정사건 요약 68
[표 9] 미 경쟁법 적용의 사례 요약 76
[표 10] 소비자 제기 경쟁법 위반 소송 요약 91
[표 11] 경쟁자 제기 경쟁법 위반 소송 요약 92
[표 12] 일본 「전기통신사업법」의 비대칭 규제 96
[표 13] 일본의 업종 종단적 규제 98
[표 14] 일본전기통신사업 관련판결 요약 104
[표 15] 일본 통신 관련 소송 요약 114
[표 16] 유럽연합 전기통신사업관련 판결내용 요약 120
[표 17] 유럽연합 소송 요약 128

그 림 차 례

[그림 1] 가격-비용-영업 결정 11
[그림 2] 지배적기업모형 12
[그림 3] 경쟁자 배제 시장 12
[그림 4] 고흥군 LPG충전소 사건 개요 19
[그림 5] 부산교통 사건 개요 20
[그림 6] 청주시 연탄공장 사건 개요 22
[그림 7] KT-하나로 가격 담합 사건 개요 23
[그림 8] KT 가격 담합 사건 개요 24
[그림 9] Bell Atlantic과 NYNEX의 합병 사례 30
[그림 10] SBC와 AT&T의 합병사례 32
[그림 11] AT&T의 분할 결정 35
[그림 12] FCC 조직 41
[그림 13] FCC, DOC, FTC의 관할 41
[그림 14] Arlington v. FCC 사건 개요 48
[그림 15] 전미케이블통신연합(NCTA) v. Gulf Power 사건 개요 49
[그림 16] MCI v. AT&T 사건 개요 52
[그림 17] AT&T v. FCC의 사건 개요 53
[그림 18] Marco v. AT&T 사건 개요 54
[그림 19] TCI Mail v. MCI 사건 개요 55
[그림 20] Wegoland v. NYNEX 사건 개요 56
[그림 21] CCI v. AT&T 사건 개요 57
[그림 22] AT&T v. Iowa Utilities Board 사건 개요 60
[그림 23] Verizon v. FCC 사건 개요 61
[그림 24] U.S. Telecom Association v. FCC 사건 개요 62
[그림 25] AT&T v. Portland시 사건 개요 63
[그림 26] Comcast v. FCC Case 사건 개요 64
[그림 27] NCTA v. Brand X 사건 개요 66
[그림 28] Goldwasser v. Ameritech 사건 개요 79
[그림 29] Covad v. BellSouth 사건 개요 82
[그림 30] MetroNet v. U.S. West Communication 사건 개요 83
[그림 31] Trinko v. Bell Atlantic 사건 개요 84

[그림 32] LinkLine v. AT&T사 등 사건 개요 86
[그림 33] Bell Atlantic v. Twonmbly 사건 개요 88
[그림 34] KDDI v. 총무성 사건 개요 106
[그림 35] 일본통신 v. NTT 도코모 사건 개요 109
[그림 36] NTT 동일본 v. 일본 공정위 사건 개요 111
[그림 37] Telefonica, S.A. v. EC 사건 개요 122
[그림 38] Telekomunikacja Polska v. EC 사건 개요 123
[그림 39] Deutsche Telecom v. Mannesmann AG & Co 사건 개요 125
[그림 40] AOL v. Deutsche Telekom 사건 개요 126
[그림 41] GSM-Gateway 사건 개요 127

해외 통신시장 사후규제 사례 연구
- 이중규제 해소방안을 중심으로 -

Ⅰ. 서론

1. 통신시장에서의 사후규제 강화 및 이중규제의 문제점

전통적으로 자연독점적인 것으로 인식되었던 통신 산업에 최근 급격한 기술혁신에 의한 다양한 통신서비스가 출시되어 활발한 경쟁이 도입되자, 해외 각국은 종래의 사전적·경직적인 규제방식에서 벗어나 통신법상 규제에도 경쟁법적 원리를 도입하고 사후적인 규제방식으로 전환하고 있다. 이러한 흐름에 따라, 우리 「전기통신사업법」도 기존의 사전적·획일적인 역무구분 방법을 폐지하고 요금인가제를 완화하는 등 여러 가지 노력을 하고 있으나, 아직까지 나날이 가속화되는 통신시장의 치열한 경쟁상황에 적절히 대응하지 못하고 있는 바, 이에 대한 입법정책적 대응방안 마련이 시급한 실정이다.

특히 최근 국내 통신시장에서 반경쟁적 행위에 대한 규제와 관련하여, 전문규제기관과 일반경쟁규제기관 간 권한중첩의 문제가 지속적으로 이슈화되고 있다. 「전기통신사업법」 제54조는 동법 제50조 제1항을 위반한 전기통신사업자의 행위에 대하여 시정조치를 명하거나 과징금을 부과한 경우, 그 사업자의 동일한 행위에 대하여 '동일한 사유'로 「독점금지및공정거래에관한법률」(이하, 「공정거래법」)에 따른 시정조치 또는 과징금의 부과를 할 수 없다고 규정하고 있지만, 위 '동일한 사유'의 의미에 대한 명확한 기준이 없고, 「공정거래법」이 불공정거래행위의 요건에 대하여 「전기통신사업법」상 금지행위 요건보다 폭넓게 규정하고 있어 동일 행위에 대한 다른 사유로의 규제가 가능한 바, 사실상 공정거래위원회(이하 '공정위')가 모든 사안에 대하여 조사 및 제재를 할 수 있기 때문이다. 방송·통신 융합의 진척으로 방송통신위원회(이하 '방통위')가 통신시장에 대한 전문규제기관으로 설치되고 이러한 방통위의 기능 중 상당부분이 미래창조과학부(이하 '미래부')로 이전되어, 경쟁규제에 있어서 전문규제기관인 방통위와 미래부 및 일반

경쟁규제기관인 공정위 간의 법적 관할배분의 불분명성으로 인한 규제 실무상의 중복규제 또는 규제기준의 혼선이 발생하고 있는 실정이다.

통신 3사의 단말기 보조금과 관련하여 지난 2012년 6월 방통위가 '부당한 이용자 차별'을 근거로 136억 원 규모의 과징금을 부과한 것에 대하여, 최근 2013년 3월 공정위가 '불공정거래행위 중 위계에 의한 부당한 고객 유인행위'에 해당한다며 다시 과징금을 부과한 것이 그 대표적인 예이다. 이를 계기로 방통위와 공정위의 이중규제 논란의 해소를 위한 입법정책적 방안 마련이 시급하다는 지적이 제기되었다. 이러한 규제권한 행사의 혼선은, 정책의 일관성 상실과 책임귀속의 불명확이라는 문제를 초래할 뿐만 아니라, 규제 권한의 중복행사로 인해 전기통신사업자의 법적지위에 매우 큰 불이익을 줄 수 있으며, 궁극적으로 소비자들의 불이익으로 귀결된다.

2. 사후규제의 관할권 배분 문제

전문규제기관과 일반경쟁규제기관 간의 권한배분 논의와 관련하여, 사후규제에 대한 관할권 배분이 특히 문제가 된다. 통신 운용기술과 관련된 일체의 기술적 규제, 통신서비스요금 책정 및 시장진입에 대한 경제적 규제와 같이 방송통신시장에서 경제·사회·환경·행정적 목적 실현을 위한 규제는 전문규제기관이 담당하여야 한다는 데에는 대체로 이견이 없다. 그러나 유효경쟁이 존재하지 않던 시장상황에서는 전문규제기관의 '경쟁조성' 기능이 중심에 있었으나 시장이 경쟁화함에 따라 일반경쟁규제기관의 사후적 경쟁규제와 전문규제기관의 사전적·사후적 경쟁규제가 중첩되는 현상이 발생하였다.[1)]

이에 대한 지금까지의 논의는 대체로 '일반법에 대한 특별법 우선의 원칙' 이론에 근거하거나, 혹은 통신에 대한 일체의 기술적 규제·통신서비스요금 책정이나 시장진입에 대한 경제적 규제 등은 전문영역에 해당하여 보다 전문성을 가진 전문규제기관이 담당하는 것이 바람직하므로 일차적 규제권한은 전문규제기관에 주고, 일반경쟁규제기관은 이에 대해 상호 협력하는 체제를 유지하는 것이 바람직하다는 의견이 다

1) 김태호, "방송통신시장 경쟁규제에서 일반경쟁규제기관과 전문규제기관 간의 권한 배분", 『경쟁규제와 법』, 제1권 제2호, pp. 136-161. 2008.

수이다.[2] 양 기관의 규제가 공존해야 한다고 할 때 이들이 조화롭게 행해질 수 있는 기준으로서 '경쟁사업자들 간의 수평적 규제'만이 문제되는 영역에서는 일반경쟁규제기관의 규제가 우선하고, '소비자 보호를 위한 수직적 규제'가 행해지는 경우에는 일반경쟁법의 적용을 배제하여 전문규제기관의 일차적 관할권만이 존재하는 것이 타당하다는 연구가 선행된 바 있다.

하지만 이를 단순히 이중규제의 문제로 간주하기 보다는, 통신에서의 '중복규제'의 실체를 거시경제적, 미시경제적 관점 및 실체법적, 소송법적 관점으로 보다 면밀하게 분석하여, 두 가지 규제가 규율 차원을 달리하여 상호 조화롭게 공존하는 가운데 최대한의 효과를 달성할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

대부분의 국가에서 일반경쟁규제기관은 그 이전부터 존재하였는바, 방송·통신시장에서 전문규제기관의 필요성이 나날이 증대되어 규제기관 간의 권한 배분의 문제는 전문규제기관이 존재하는 여러 나라에서 이미 논의가 진행되어왔다. 따라서 본 연구에서는 해외 주요국 사례들에 대한 폭넓은 조사·연구를 실시함으로써 각국의 규제기관들이 수평적 규제·수직적 규제와 관련하여 취하고 있는 규제의 방법과 그 효과 및 영향 등에 대해 분석한다. 이를 바탕으로 전문규제기관과 일반경쟁규제기관의 규제를 '중복규제' 문제로 국한해서 보는 시각에서 벗어나 양 기관의 규제가 충돌하지 않고 병존할 수 있는 구체적 기준을 제시하고, 국내 규제체계의 개선을 위한 입법정책적 방안을 논의하고자 한다.

3. 비교법적 연구 및 경제법학적 연구

통신시장규제에 관하여는 종래 행정법학계를 주축으로 양 기관 간 체계정립을 위한 법체계상의 이론적 연구 및 해외 각국을 대상으로 한 비교법적 연구 등이 이루어져 왔고,[3] 경제법학계에서는 시장경쟁과의

2) 김태호, 2008.
3) 전반적인 국내 논의의 개관으로는 이원우, "통신시장규제에 있어서 전문통신규제기관과 일반경쟁규제기관의 관계", 『행정법연구』, 제14호, 2005.10.; 신영수, "통신시장의 경쟁촉진을 위한 규제기관의 권한 조정", 중앙법학, 제6집 제1호. 2004.4. 참조. 비교법적 연구로는 이원우 편, 『정보통신법연구Ⅰ - 통신시장에 있어서 전문규제기관과 일반경쟁규제기관의 관계』, 경인문화사. 2008.; 이희정, "통신시장에 대한 경제규제권한의 배분과 조화-영국 모델의 시사점", 『토지공법연구』, 제37집 제1호, 2007.8.

상관관계에 관한 연구 등의 학문적 접근 외에도 방통위, 공정위 등 정부부처에서 정기적으로 세계적 규제동향에 대한 연구가 꾸준히 이루어졌다. 특히 통신시장 내 시장지배적 사업자에 대한 비대칭규제에 대한 연구가 주를 이루었다.[4)]

하지만 경쟁규제의 문제가 규제관할배분의 중심 문제로 되면서 방통위와 공정위 양 기관에 의한 중복규제의 혼선의 문제는 좀 더 자주 현실화·복잡화 되고 있으며, 통신시장에서의 행정부 기관 간 관할배분 논쟁은 통신시장 특유의 사정을 넘어 행정조직법 일반이론 차원에서 검토할 만한 쟁점을 담고 있다. 그러므로 본 연구는 해외 주요국들의 통신 전문규제기관과 일반경쟁규제기관의 권한배분 및 사후규제 사례들을 조사·분석한 뒤, 이를 바탕으로 하여 국내 규제체계의 시사점을 도출하고자 한다.

이 연구는 다음과 같은 체계로 이루어진다. 우선, 통신시장 이중규제의 문제점 및 통신시장 활성화에 따른 사후규제의 중요성을 간략히 검토하고, 해외 주요국들의 통신 전문규제기관과 일반경쟁규제기관의 권한배분 사례 및 사후규제 주요 사례를 조사하여 분석하는 것을 그 일차적인 목적으로 한다. 이러한 분석결과를 바탕으로 하여 경쟁규제에 있어서 어떻게 전문규제기관과 일반 경쟁기관 간의 권한을 배분할 것인지에 대한 일반적인 기준과 입법 방안을 제시함으로써 우리나라의 규제체계 개선을 위한 최적화된 입법정책적 방안을 제안하고자 한다.

4) 이영대, “통신시장에서의 시장지배적 사업자에 대한 비대칭 규제의 법적 성격에 대한 소고”, 『정보법학』, 제9권 제1호. 2007.

Ⅱ. 우리나라 통신시장의 규제 현황

1. 사업법 상 규제

가. 「정부조직법」 개정에 따른 규제 주체의 변화

2013. 3. 23. 법률 제11690호로 「정부조직법」이 개정되면서, 과학기술과 정보통신기술 발전을 통하여 일자리를 창출하고, 경제부흥의 기반을 마련할 수 있도록 미래부를 신설하고, 그 소관업무에 국가정보화 기획·정보보호·정보문화, 방송·통신의 융합·진흥 및 전파관리, 정보통신산업, 우편·우편환 및 우편대체에 관한 사무가 포함되었다(「정부조직법」 제28조).

이렇듯 방통위의 방송통신 진흥 및 융합 등의 기능과 교육과학기술부의 과학기술 관련 기능을 통합하여 미래부를 신설하는 내용으로 「정부조직법」이 개정됨에 따라, 2013. 3. 23. 법률 11711호로 「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」도 방통위의 기능을 공영방송 임원선임에 관한 사항, 지상파방송사업자의 허가·재허가 및 종합편성이나 보도에 관한 전문편성을 하는 방송채널사용사업자의 승인에 관한 사항, 방송용 주파수 관리에 관한 사항, 종합유선방송사업자 등의 허가·재허가·변경허가 및 관련 법령의 제정·개정에 대한 동의에 관한 사항, 방송광고에 관한 사항 등으로 규정하였다.

방통위와 미래부 간의 기능 분담에 따라, 방통위의 심의·의결 사항에서 통신사업자의 허가·취소 등에 관한 사항, 방송·통신 관련 기술정책의 수립에 관한 사항, 전기통신설비의 제공·공동이용·상호접속 또는 공동사용 등이나 정보제공에 관한 협정의 인가 등에 관한 사항 등은 삭제되었고 (동법 제12조), 대신 2013. 6. 21. 대통령령 제24634호 '미래창조과학부와 그 소속기관 직제'에 의하면, 산하 통신정책국은 통신시장 경쟁상황 평가, 기간통신사업의 허가, 양도·양수, 합병 및 휴지·폐지, 통신시장 경쟁 정책의 수립, 전기통신서비스의 도매제공 제도 수립 및 시행, 통신시장 망(網) 개방 및 망 중립성 정책의 수립, 전기통신설

비의 상호접속 및 접속료 정책 수립 및 시행, 상호접속 등 협정의 신고 및 인가, 보편적 역무 제도 수립 및 시행, 전기통신서비스의 요금 정책 및 이용약관의 인가 및 신고 등 사무를 담당하여, 기존의 방통위 기능의 상당부분이 미래부로 이전되었다.

따라서 기존 경쟁정책 관련 분야에서 공정위와 방통위의 중복규제로 문제가 되던 사업의 양수 및 법인의 합병과 관련하여, 2013. 3. 23. 법률 제11690호 「전기통신사업법」 제18조에 의하면, 기간통신사업의 전부 또는 일부를 양수하려는 자, 기간통신사업자인 법인을 합병하려는 자, 허가를 받아 제공하던 기간통신역무의 일부를 제공하기 위하여 법인을 설립하려는 기간통신사업자는 미래부 장관의 인가를 받아야 한다.

나. 진입/퇴출 규제

1) 진입/퇴출 규제의 특징

진입/퇴출 규제의 본질은 사업법 상 인허가이다. 특히 기간통신사업자에 대한 허가는 사업수행권을 독점적으로 창설한다는 의미에서 공법상 특허에 가까운바, 이러한 권리설정 행위는 엄격한 자격심사를 요건으로 한다. 따라서 모두에게 허용된 행위에 대한 금지를 해제한다는 행정법상 허가와는 구별되는 것이다. 양자의 가장 큰 차이는, 금지해제인 허가의 경우 해제요건에 부합하는 한 반드시 부여되어야 하는 것으로 기속행위로서의 성질을 갖는데 반하여, 공법상 특허는 신청자의 자격을 어느 일면이 아닌 종합적이고 전면적으로 심사하여야 하는 것으로 여기에는 사업법 당국의 재량이 필연적으로 개재되어 재량행위로 분류된다는 것이다.[5] 이를 요약하면 다음과 같다.

5) 이병태, 『법률용어 사전』, 법문북스, 2010.

[표1]공법상특허가

구분	허가	특허
개념	질서유지를 위하여, 일반적으로 금지된 영업행위를,특정한 경우에 해제하여 줌으로써, 당해 영업을 할 수 있는 자연적 자유를 회복시켜주는 명령적 행정행위	공익목적을 위하여, 사업수행권을 사인에게 부여하는 형성적 행정행위
대상사업	사회질서 유지가 필요한 사업	국민생활에 필수적인 재화나 역무를 제공하는 공익사업
목적	사회공공의 안녕과 질서유지를 도모	사회공공의 복리를 증진시키려는 취지
재량행위성	기속행위적 성격이 강함	재량행위적 성격이 강함
감독	소극적인 감독	적극적인 간섭

자료: 이병태, 2010.

사업법 상 구체적인 경우 허가와 특허를 구분하는 기준은 법령의 문언과 취지, 당해 행정행위의 성질과 분야, 기본권관련성과 공익관련성의 비중 등을 모두 고려하는 것이 다수설과 판례의 입장이다. 구별의 실익은 행정소송에서의 입증책임에 있다. 기속행위 취소소송은 법률요건의 구비 여부만을 심사하므로 원고의 입증부담이 경감된다. 이에 반하여 공법상 특허의 취소소송은 기본적으로는 특허 부여 시 행정청의 재량이 인정되므로, 위법성에 대한 입증책임은 재량이라는 항변에 막혀 완수하기 어렵다. 결국 재량이 남용되었거나 주어진 재량권을 일탈하였다는 점을 입증해야 하는 바, 이는 기속행위 취소에 비하여 훨씬 엄격하게 심사된다.

2) 사업법의 실제

「전기통신사업법」 제21조에 따르면, 별정통신사업 경영에는 등록을 필요로 한다. 법령의 문언상 이는 기속행위에 해당하는 강학상 허가에 가깝다. 그러나 공정경쟁 촉진, 이용자 보호, 서비스 품질 개선, 정

보통신자원의 효율적 활용 등에 필요한 조건을 붙일 수 있으므로, 이 범위 내의 재량이 인정된다.

동법 제 18조 합병인가를 살펴보면, 사업의 양수 및 법인의 합병 등에는 미래장관의 인가를 받아야 한다. 인가 여부를 심사함에 있어서는 통신망 활용, 이용자 보호, 국제 경쟁력 등과 함께 다양한 공익성 지표들이 심사된다. 합병 인가는 법령의 문언 및 공공의 이익과 관련된 통신사업의 특성상 재량행위로서 특허에 가깝다.

다. 요금/약관 규제

1) 보편적 역무 보장

사업법 당국의 인허가권을 바탕으로 사업자를 상대로 약관이나 요금에 대한 규제권을 행사할 때, 여기에는 인가취소권이 논리적으로 전제되어 있다. 따라서 인가를 할 것인가 아닌가에 관한 재량이 약관 심사와 요금 규제에 포함된다. 일단 심사된 약관은 재량행위의 결과로서 그 위법성을 입증하기 어려우며, 소송에서는 그 적법성을 추정 받는 것으로 해석된다.

약관/요금 규제의 핵심은 '보편적 역무'(universal service)를 보장하고, 합리적인 가격을 유지하는 것으로, 이는 '망 중립성'(network neutrality)의 개념에서 나온다. 독점적 사업자는 그 지위를 이용하여 가격을 자의적으로 책정해서 소비자에게 직접적인 피해를 입히거나, 혹은 경쟁회사를 축출하여 장기적으로 소비자에게 피해를 입힐 위험이 있는 바, 위 망 중립성은 평등 접근권, 무차별 접근 보장의 이념을 요금 규제를 통하여 구체화하여 사업법 당국이 약관/요금 규제를 통하여 달성하고자 하는 궁극적 목표로서 소비자를 보호한다.

라. 비대칭 규제

1) 기간통신사업자에 대한 비대칭 규제

「전기통신사업법」은 모든 사업자에 대한 규제를 규정한다. 통신사업자는 상호접속의무를 적용받아 설비개방의무를 부담한다. 기간통신사업자에 대하여는 가중된 규제가 부여되어, 상호접속 시 체결되는 계약인 협정에 대하여 사업법 당국의 적극적인 개입이 허용되고, 요금 산정 기준이 고시되거나, 체결된 협정은 반드시 당국에 신고 되어 심사된다.

2) 시장지배적 사업자에 대한 비대칭 규제

같은 기간통신사업자라 하더라도 시장지배적 사업자에 대해서는 더욱 엄격한 규제가 적용된다. 시장지배적 사업자에 대하여는 엄격한 요금 인가제가 시행되는 반면, 다른 후발사업자들은 요금 신고제를 적용한다. 이는 공정경쟁 및 후발사업자 육성을 통한 산업발전, 이로 인한 이용자 편익증진 등의 사업법 목적을 달성하기 위한 규제철학을 반영한 조치이다.

마. 거시경제적 규제

1) 네트워크 외부성

보편적 역무를 보장하는 네트워크 중립성 외에 통신시장에 대한 규제의 다른 중요한 전제는 네트워크 외부성이다. 네트워크 외부성은 네트워크 산업의 외부에서 네트워크 산업으로 인하여 효용이 증감하는 성향을 의미하여, 가장 중요한 요소는 이용자의 수이다. 네트워크의 이용자수는 단순한 매출 기준에 그치는 것이 아니라, 네트워크의 규모와 접속 횟수, 도달 범위를 결정하므로, 네트워크 평가에 있어서 가장 중요한 기준이 된다. 네트워크 외부성은 네트워크 간 연결을 촉진한다. 가령 유선 전화, 무선 전화, 인터넷 전화라는 전통적인 산업 개념을 넘

어서 그 경계를 넘는 새로운 개념의 확대된 시장이 정의되면, 그것이 확대된 네트워크가 되는 것이며, 종래의 관점에서 보면 이는 개별 산업을 횡단하는 새로운 출발점이 된다.

이러한 관점을 확대하면, 종래 사업자 간 인수합병, 합자회사, 합작투자, 불공정거래, 끼워 팔기, 독점협정 등의 사업체 간 발생하는 경쟁적 요소를 평가할 때 미시경제적 차원에서 경쟁저해만을 심사했던 종래의 경쟁법 당국의 규제와는 차별화된 사업법 당국 규제의 의미가 더욱 중요해진다.

미시경제적 관점에서 경쟁규제를 할 때 기업들 간 혹은 한 기업에 직접적으로 영향을 주고받는 공급자, 경쟁자들의 시장 내 역학관계, 기업의 직접적인 이해당사자들을 고려하여야 하는 반면, 거시적 관점에서의 규제는 국민경제 전체의 시각에서 사회간접자본으로서의 통신시장의 역할, 산업연관효과, 산업육성효과, 고용효과, 물가 요소, 소유 구조 등을 통한 경제력 집중 문제, 민영화 등 운영형태, 이용료 정책에 반영되는 소득 정책 등 기업의 활동에 영향을 받을 수 있는 외부성에 대한 심사가 반드시 병존되어야 한다.

2) 네트워크 경쟁성[6)]

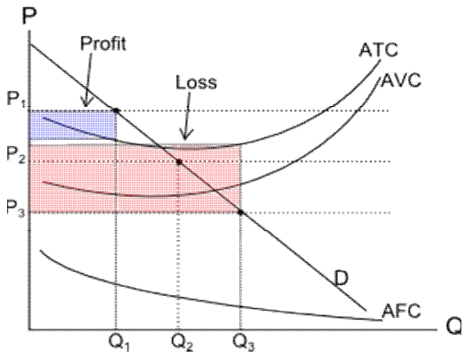
시장경제에서 경쟁은 소비자의 후생을 증진시킴과 동시에 다수의 공급자들이 서로 경쟁함으로써 산업의 효율성을 향상시킨다. 통신시장의 경우, 경쟁의 범위와 수준이 동종 사업자 사이의 경쟁에 한정된 것이 아니라, 공급 사슬의 전후방 및 시장의 이종사업자 간에도 경쟁을 하게 된다.

네트워크 경쟁성에 대한 규제를 분석하기 위해 우선 동종 사업자 사이의 수평적 경쟁저해에 관한 규제의 필요성을 살펴보면, 전형적인 수평적 경쟁저해 행위는 약탈적 가격(predatory pricing) 설정으로 인한 타 사업자 방해이다. 약탈적 가격이란 시장지배적 지위의 기업이 경쟁사업자를 시장에서 몰아낼 수단으로 자신의 가격을 일정 비용 아래로

6) 이영대·최경규, “시장지배적지위 남용행위 중 소비자 이익 저해 행위에 대한 규제 방안”, 『2012년 상반기 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서』, 연구 2012-01차. 공정거래조정위원회. 2012. 7.

설정하는 것을 일컫는다. 약탈적 가격의 대표적인 기준으로 평균총비용 기준(ATC Rule)과 아리다-터너 기준(Areeda-Turner Rule)이 있다.[7] 이 두 기준에 대한 분석에 앞서 기업의 영업 결정과 비용의 관계를 살펴볼 필요가 있다. 산업의 비용곡선은 다음의 [그림 1]과 같은 형태를 띤다.

[그림 1] 가격-비용-영업 결정



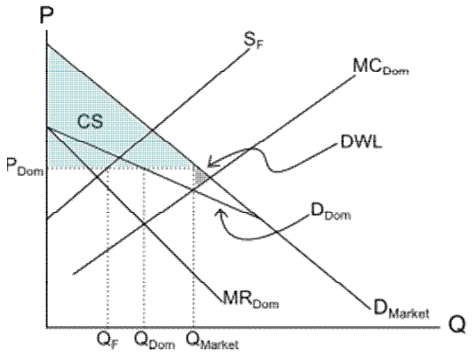
시장지배적 지위의 기업이 시장가격을 설정하게 되면 규모가 작은 경쟁업자들은 그 가격을 따를 수밖에 없다. 예를 들어, 아리다-터너 기준에 의하면 영업의 유지와 중단을 결정하는 평균변동비용(AVC)을 약탈적 가격의 기준으로 삼고 시장지배적 지위의 기업이 AVC 보다 낮은 가격 P_3를 설정하면 경쟁업자들은 이보다 높은 가격을 소비자들에게 요구할 수 없게 된다는 것이다. 그러면 손실을 감당하지 못하는 소규모 경쟁자들은 영업 중단을 결정하고 산업에서 퇴출당할 수밖에 없을 것이다. 하지만 단기적 손실을 버틸 수 있는 자본력을 갖추고 있는 시장지배적 지위의 기업은 경쟁자들이 퇴출된 후에 P_1 수준으로 가격을 높여 장기적인 독과점 이윤을 추구할 수 있다.

[그림 2]는 약탈적 가격의 설정 이전에 독보적인 시장지배력을 가진 하나의 지배적 기업(dominant firm)과 다수의 경쟁적 비주류(competitive fringe)로 구성된 시장 상황을 보여준다. 지배적 기업은 D_{Dom}이 수요곡선이고 한계수익(MR_{Dom})과 한계비용(MC_{Dom})이 일치하는

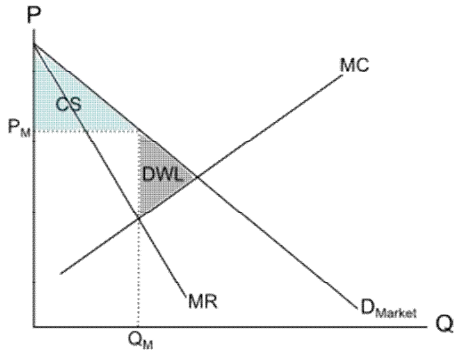
7) Areeda, P. & D. F. Turner, *Antitrust Law,* Little, Brown & Co. 1978.; Areeda, P. *Antitrust Analysis,* Little, Brown & Co. 1981.

수량 Q_{Dom}을 생산하고 이에 따른 가격 P_{Dom}을 설정한다. 경쟁적 비주류는 이 가격을 받아들여 수량 Q_F를 생산하여 시장 전체의 생산량은 Q_{Dom}과 Q_F의 합 Q_{Market}으로 나타난다. 이때 사회후생의 일부는 사중손실(DWL)로 잃게 되고 소비자 잉여도 감소한다. 이러한 약탈적 가격 설정으로 인해 경쟁적 비주류가 퇴출되면 시장이 독과점 체제로 전환되면, [그림3]에서 나타나듯이 가격이 독점가격(P_M)으로 상승하고 공급수량(Q_M)이 감소하여 사중손실의 급격한 증가와 소비자 잉여의 현저한 감소가 발생한다. 약탈적 가격에 의한 타 기업의 퇴출은 지배적 기업의 독점을 초래하여 장기적으로는 소비자의 단기이익을 능가하는 피해를 낳을 수 있기 때문에 위 약탈적 가격이 문제가 된다.

[그림 2] 지배적기업모형



[그림 3] 경쟁자 배제 시장



네트워크 경쟁성은 네트워크의 산업통합적 성격이 침해된 소비자 이익의 외연을 확장하고, 이에 따라 규제대상이 되는 지배적 기업의 범위가 달라진다는 특징을 갖는다. 나아가 사업자의 행위마다 소비자 이익의 침해의 현저성도 달라질 수 있기 때문에 이에 대한 규제기준의 합의와 일관된 기준설정이 필요하다.

3) 규제의 내용

우리 사업법 상 인허가는 거시경제적 요건에 관한 심사를 포함한다. 즉 기간통신사업자 허가에 있어서 정보통신자원의 효율적 활용, 품질개선, 이용자보호 요건은, 국민경제의 사회적 하부구조로서의 통신시

장에 대한 단순한 단일 시장에서의 경쟁 보호 이상의 사업적합성 심사를 의미한다(「전기통신사업법」 제6조 제4항). 또한 통신요금은 공공요금의 범주에 포함되어 그 산정에 있어 공공요금의 안정성, 물가변동, 경제상황의 변화와 같은 거시경제 지표가 고려되어야 한다(물가안정에 관한 법률 제4조, 동 시행령 제6조).

2. 경쟁법 상 규제의 공존

가. 규제의 경합

방통위에 의한 규제의 근거는 「전기통신사업법」으로서 사업허가의 원천인 동시에 기본 규제의 근거이므로, 사업법에 의한 규제라 칭할 수 있다. 동시에 공정위에 의한 규제의 근거는 통신시장의 공정경쟁을 확보하기 위한 「공정거래법」으로서 이는 경쟁법에 의한 규제에 해당된다. 결과적으로 전문규제기관의 사업법과 일반경쟁규제기관의 경쟁법에 의한 규제는 규제의 경합을 초래한다.

실제 규제 실태를 살펴보면, A통신사업자는 최근 3년간 방통위로부터 총 1,929일(연평균 643일, 일평균 2건)의 조사를 받았고, 공정위로부터도 총 420일(연평균 140일, 3일 평균 1건)의 조사를 받았다.[8)]

1) 요금/약관 규제

가) 1998년, 이동통신 3사의 가입비 면제를 통한 가입자 유치행위에 대하여, 정보통신부는 부당한 이용자차별로 시정명령을 하였고, 공정위는 부당한 고객유인 행위로 시정명령을 하였다.

나) 2006년, LGT의 기분존 요금제에 대하여, 통신위원회가 부당한

8) 이익현, “대한민국 경제법제 발전 60년사”, 「경제법제 선진화 방안 세미나」 발표자료. 전경련·법제처 공동개최. 2011. 11. 23.

이용자 차별로 시정명령을 하였음에도, 공정위는 부당염매에 해당하지 않는다고 판단하였다.

다) 2005년 12월에 공정위가 내린 "4개 시외전화사업자의 부당한 공동행위 등에 관한 건"에 대한 판정은 논란을 야기하였다.[9] 동 사건에서 피심인 KT는 문제가 된 맞춤형 정액요금제를 출시한 것은 정보통신부의 행정지도에 의한 것으로 이는 「전기통신사업법」 제33조의 4항 취지에 부합하는 "법령에 따른 정당한 행위"라고 주장하였다. 이에 대하여 공정위는 「공정거래법」 제58조의 "법령에 따른 정당한 행위"에 해당하기 위해서는 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하는 법률 또는 그 법률에 의한 명령의 범위 내에서 행하는 필요 최소한의 행위여야 하는데, 「전기통신사업법」 제33조의 4는 "정보통신부장관은 전기통신사업의 효율적인 경쟁체제의 구축과 공정한 경쟁 환경의 조성을 위하여 노력하여야 한다"는 선언적인 규정만을 두고 있을 뿐이고, 같은 법 제33조의 5 내지 38조의 6에서 소위 '유효경쟁'을 위한 구체적인 정책수단들을 나열하고 있어, 「전기통신사업법」에는 사업자의 요금상품 출시여부 및 상품내용, 요금수준 등을 사업자간 합의를 통해 결정할 수 있다거나 정통부가 이를 요구할 수 있음을 인정하는 구체적인 규정이 전혀 존재하지 않는다는 점을 들어 KT의 주장을 기각하였다.[10]

2) 접속규제

가) 전기통신사업자가 사내의 비영업직원을 대상으로 이동전화 판매를 독려한 행위에 대하여, 방통위는 「전기통신사업법」 제36조의 3 제1항 제4호에 근거하여, 이동전화역무와 관계없는 비영업부서 직원들에게 이동전화서비스 판매목표를 부여하는 것은 이들이 목표달성을 위해 업무시간(09:00~17: 00) 중에도 이동전화서비스를 판매하도록 조장·방조하여 비영업부서 직원이 시내, 시외, 국제전화 및 회선설비임대 등 본연의 역무에 대한 서비스에 소홀히 할 우려가 있으므로 해당 통신이용자의 이익을 현저히 저해한 행위로 보고 과징금 41억원을 부과하였

9) 공정거래위원회, 의결 제2005-331호, 사건 2005단체0162. 2005. 12. 15.
10) 공정거래위원회, 위의 글, 34면

다.[11] 공정위 또한 「공정거래법」 제23조 제1항 제3호 및 같은 법 시행령 제36조 제1항 관련 [별표1] 제5호 나목에 근거하여, 부당하게 자기 또는 계열회사의 임직원으로 하여금 자기 또는 계열회사의 상품이나 용역을 구입 또는 판매하도록 강제하는 행위, 즉 사원판매행위로 보아 과징금 20억 원을 부과하였다.

나) 최근 방통위는 2010.9.24. 과 2011.9.19. 두 차례에 걸쳐서 통신 3사의 단말기 보조금 지급행위에 대하여 「전기통신사업법」 제50조 제1항 제5호, 동법 시행령 제42조 제1항 [별표3] Ⅴ.5호 가목을 적용하여 이용자 차별행위로 시정조치를 부과한 바 있다. 한편, 공정위는 2012.3.14. 단말기 제조사들과 함께 통신 3사에 대하여 휴대폰 가격을 부풀린 후 보조금을 지급하여 '고가 휴대폰'을 '할인 판매' 하는 것처럼 소비자를 기만하였다는 이유로 「공정거래법」 제23조 제1항을 적용하여 시정명령과 과징금 지급명령을 부과하였다.[12]

방통위 심결 제2010-58-248호(사건번호: 200903조사12) (이하 '제1심결')와 방통위 심결 제2011-51-174호(사건번호: 201106조사019) (이하 '제2심결')의 각 의결내용을 살펴보면, 제1심결에서는 단말기 보조금 지급행위 중 ①보조금 지급수준이 가입자 1인당 평균 예상이익과 가입자 1인당 평균 제조사장려금에서 조성된 단말기 보조금의 합산액인 27만원을 초과하는 보조금 지급과 ②신규, 번호이동 가입자와 기기변경 가입자간 차별행위 등을 이용자 차별행위로 규제하고 있다. 특히 SKT는 제1심결의 심의과정에서 "보조금 차별지급이 위법하더라도 제조사 장려금으로 인하여 발생한 보조금 차별에 대해서는 이동통신사에게 책임을 물을 수 없다"는 취지의 주장을 하였으나 방통위는 「전기통신사업법」 제50조 제2항에 의하여 SKT의 유통망에서 보조금을 차별적으로 지급한 경우 그 재원의 출처에 불문하고 이동통신사가 책임을 진다는 이유로 위 주장을 받아들이지 않고 단말기 보조금 지급과 관련하여 제조사장려금을 포함시켰다.

나아가 제2심결에서는 SKT가 단말기 출고가와 약정외 보조금을 포함한 장려금 지급기준, 단가표 등을 유통망에 작성, 배포하고 유통망에

11) 방송통신위원회, 200401조사019.
12) 공정거래위원회 홈페이지, 2012.3.15.
<http://www.ftc.go.kr/news/policy/competeView.jsp?news_no=1390&news_div_cd=2>

서 SKT가 배포한 자료를 바탕으로 이용자를 가입시킨 건을 규제의 대상에 포함시켰다.

이에 비하여 공정위 심결은 단말기 보조금 지급방식 특히 제조사가 재원을 부담하는 약정외 보조금을 위계의 수단으로 마케팅에 활용하였다는 점을 문제 삼고 있다. 즉, 제조사가 지급할 약정외 보조금인 "장려금"을 감안하여 대리점에 대한 "출고가"를 통신 3사에 대한 "공급가"에 비하여 현저히 높게 책정하고, 출고가와 공급가의 차이에 해당하는 금원을 소비자(이용자)에 대한 보조금 지급에 활용하였으므로, 소비자에게 실질적인 할인혜택이 없음에도 불구하고 마치 휴대폰 구입비용 부담을 덜어주는 것처럼 기망하여 소비자를 유인했다는 것이다.[13)]

이처럼 「전기통신사업법」 제54조에서 동법 제50조 제1항을 위반한 전기통신사업자의 행위에 대하여 시정조치를 명하거나 과징금을 부과한 경우, 그 사업자의 동일한 행위에 대하여 동일한 사유로 「공정거래법」에 의한 시정조치를 명하거나 과징금을 부과하지 못하도록 규정하여 전기통신사업법과 공정거래법에 의한 중복규제를 제한하고 있으나, "동일한 행위"와 "동일한 사유"의 해석에 따라서 통신사의 입장에서는 중복규제로 해석되는 규제들이 행해지고 있는 실정이다.

나. 중복규제

전문규제기관의 법적 인가가 있을 때, 일반경쟁법 적용이 제외되는 경우도 있지만, 양 규제가 공존하는 경우도 있다. 즉, 그 인가가 경쟁보호를 심사하지 않거나 인가의 책임을 전문기관이 전면적으로 부담하지 않을 때, 즉 해당산업에 관한 책임을 전적으로 전문기관에 지우려는 입법의도가 부인되는 경우 일반경쟁법도 적용되는 것이다. 본 연구에서는 이와 같이 규제가 공존하는 영역에서 보다 체계적인 분류를 통해 관할에 있어서의 혼선을 해결하고자 한다.

이러한 사업법과 경쟁법의 중복 규제 현황을 정리하면 다음과 같다.[14)]

13) 손금주, "전기통신사업법 제54조의 중복규제 여부: 단말기 보조금 관련 방송통신위원회와 공정거래위원회의 규제를 중심으로", 『경제규제와 법』, 제5권 제1호. 2012. pp220-229.
14) 박동주, 『정보통신시장에서의 통신규제정책 연구: 통신위원회와 공정거래위원회간 역할 재정립을 중심으

[표 2] 사업법과 경쟁법의 중복규제 현황

구분	사업법	경쟁법
진입/탈퇴 규제	o 기간통신사업자의 허가, 허가변경, 사업겸업 승인, 사업 휴·폐지 (「전기통신사업법」 제6조, 제16조, 제17조, 제19조) o 상호접속제도(「전기통신사업법」 제39조) -금지행위의 유형 및 기준 고시/금지행위에 대한 시정조치 (「전기통신사업법」 제50조, 52조)	o 기업결합의 제한: 시장 경쟁을 실질적으로 제한하는 기업결합의 금지, 기업결합의 신고 접수 및 심사 (「공정거래법」 제7조, 제12조) o 시장지배적 지위의 남용 금지: 필수설비의 사용, 접근에 대한 거절, 중단 또는 제한은 다른 사업자의 사업활동에 대한 부당한 방해로서 금지됨 (「공정거래법」 제3조의 2)
약관 규제	o 요금 및 약관의 규제: -기간통신사업자의 이용약관 신고 (「전기통신사업법」 제28조 제1항) -미래창조과학부장관의 인가 (「전기통신업법」 제28조 제2항) -금지행위(부당한 요금산정, 약관위반행위 및 이용자의 이익을 현저하게 저해하는 방식의 역무제공)에 대한 시정조치 (「전기통신사업법」 제50조)	o 시장지배적 지위의 남용 금지: 상품판매, 용역제공의 부당한 조절, 다른 사업자의 사업활동 및 새로운 사업자 참가에 대한 부당한 방해금지 (「공정거래법」 제3조의 2) o 부당한 공동행위의 금지: 다른 사업자와 공동으로 경쟁을 제한하는 공동행위의 금지 (「공정거래법」 제19조) o 불공정약관의 규제: -불공정약관조항의 사용금지 (「약관규제법」 제17조) -공정거래위원회의 시정조치 (「약관규제법」 제17조의 2) / 관청인가약관 등에 대한 공정거래위원회의 시정조치 요청 (「약관규제법」 제18조) -공정거래위원회의 표준약관 심사 (「약관규제법」 제19조, 제19조의1, 제19조의 2)

로』, 서울대학교 행정대학원. 2003. p.70

접속 규제	o 공정경쟁촉진규제 -금지행위의 유형 및 기준 고시/금지행위에 대한 시정조치 (「전기통신사업법」 제50조, 52조) -전기통신설비의 제공과 공동사용, 정보제공 (「전기통신사업법」 제35조, 41조, 42조) -전기통신번호의 관리계획 (「전기통신사업법」 제48조) -전기통신사업의 회계정리 (「전기통신사업법」 제49조)	o 불공정거래행위의 금지: 부당한 거래거절, 차별취급, 부당한 경쟁사업자 배제, 부당한 고객유인, 거래강제, 거래상 지위의 남용, 구속조건부 거래, 부당한 사업활동 방해, 부당한 내부거래 등의 금지 (「공정거래법」 제23조)

시장지배적 사업자의 약탈적 가격설정과 경쟁배제 및 소비자 이익의 현저한 감소 등 시장실패에 대한 규제의 필요성으로 행해지는 통신시장에서의 과도한 규제로 인한 시장기능의 소실 우려에 대응하여 '정부에 의한 규제'에 대한 완화조치가, 두드러지게 행해지고 있다. 「공정거래법」의 해석에서 보이는 적용제외규정의 대폭적인 축소도 그 예이다.

규제완화의 근저에 있는 철학은, 설사 불완전한 시장이라도 정부에 의한 시장으로의 참여규제, 투자규제 또는 가격규제보다는 시장에 의한 자율적인 규제가 효율적이라고 하는 것이다. 그러나 시장의 자율성에만 맡기는 것은 정부에 의한 경제규제의 불충분성으로 인해 국민의 편익이 감소하게 된다. 따라서 시장의 자율적인 규제로 인한 편익의 감소와 정부의 개입 내지 규제로 인해 발생하는 규제비용을 종합적으로 고려해야 한다.

경쟁을 우선시하는 정책의 틀 안에서 새로이 정해야 하는 것은, 규제시장 및 규제완화시장에서의 경쟁법의 역할이다. 이론상으로는 사업법과 경쟁법 사이에 모순은 없다. 그것은 공익사업규제나 공적독점과 같이 중요하면서 전통적인 사유는 해당 시장에서 경쟁논리와 아울러 고려되어야 하기 때문이다. 마찬가지로 경쟁법은 카르텔, 부당한 기업

결합 또는 시장지배적 사업자 지위의 남용 등의 행동에 의해 해당 시장에서 경쟁을 침해하는 행동을 저지하는 기능을 한다.

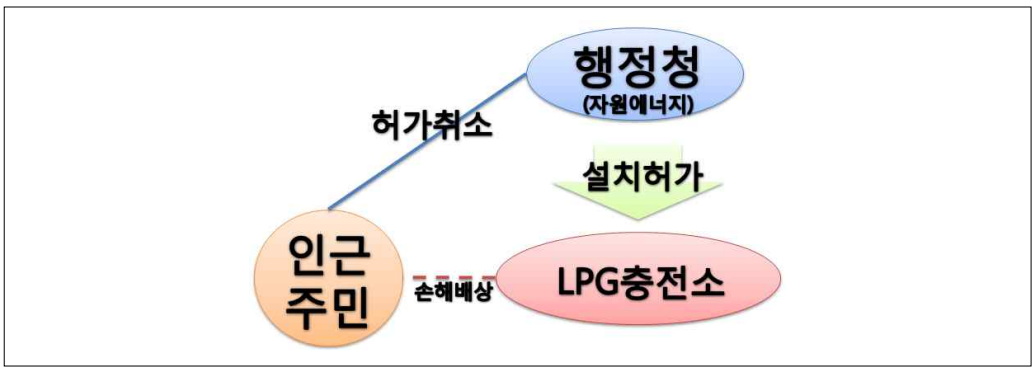
다. 통신시장 행정 소송의 기본 구조

행정소송에는 ①정부의 수익적 행정처분을 받은 사업자의 영업행위가 거래상대방에게 손해를 입혔을 때, 그 상대방이 수익적 행정처분에 대해 다투는 소송, ②특정인에게 주어지는 수익적 행위가 경쟁관계의 타인에게 법률상 불이익을 초래할 때, 그 타인이 자기의 법률상 이익의 침해를 다투는 경쟁자 소송, ③이웃하는 자들 사이에서 특정인에게 주어지는 수익적 행위가 타인에게 법률상 불이익을 가져오는 경우, 그 타인이 자기의 법률상 이익침해를 다투는 이웃소송이 있다.

통신시장의 행정소송도 이러한 기본구조를 갖으며, 통신시장의 소송에서 사업법 및 경쟁법 위반소송이 실체적 경합을 할 때 각 소송의 청구취지는 어디까지 가능한지, 사업자 아닌 제3자의 당사자 적격이 인정되는지 등 법률적 구제절차의 범위를 결정하는 중요한 기준이 정립되어야 한다. 위 세 가지 행정소송의 구조를 해당 판례로 상세히 살펴보면 다음과 같다.

1) 고흥군 LPG충전소 사건: 대판 83부59

[그림 4] 고흥군 LPG충전소 사건 개요[15)]



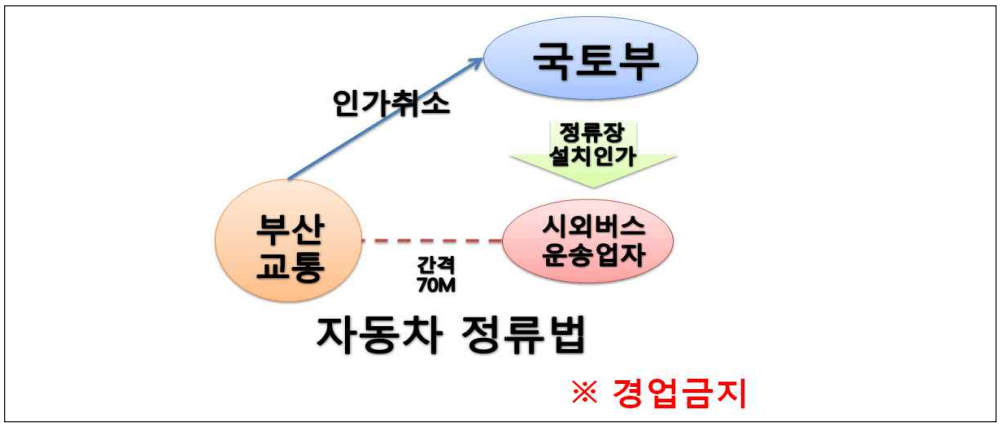
15) 대판 83부59

이 충전소 사건은 특정인에 대한 면허나 인허가 등의 수익적 행정처분이 있고, 이에 기반을 둔 영업행위가 있었을 때 자신의 법률상 이익이 침해된 자가 수익적 행정처분을 다투는 소송이다.

통신시장의 행정소송의 기본 형태 중 하나는 이 사건처럼 사업자의 행위로 인하여 이용자가 불이익을 입은 경우 그 구제를 신청하는 절차이다. 즉, 통신사업자의 행위가 상대방에게 손해를 입혔을 때, 인허가 당국을 상대로 통신사업자에게 시정조치를 하도록 요구하거나 나아가 인허가를 취소하도록 요구하는 구조이다. 통신시장의 소송에서 침해된 법익을 근거로 위와 같은 소송이 가능한지, 허용되어야 하는지가 논의되어야 한다.

2) 부산교통 사건: 대판 75누12

[그림 5] 부산교통 사건 개요[16]



이 부산교통 사건에서는 「자동차 운수사업법」상 자동차운수사업 면허요건의 취지상 신규면허나 구간 연장허가 등에 대한 기존 운수업자의 이익을 인정하여 부산교통이 국토부에 대해 70미터 간격으로 제3자에게 정류장설치를 인가한 행정처분의 취소를 구하는 소송의 원고적격을 인정받았다.

통신시장 소송의 다른 형태는 이 같은 경쟁자 소송으로서, 경쟁관계에 있는 자들 사이에서 특정인에게 주어지는 수익적 행위가 타인에게는 법률상 불이익을 초래하는 경우에 그 제3자가 자신의 법률상 이익

16) 대판 75누12

의 침해를 다투는 소송이 있다.

문제는 경쟁자 소송의 청구원인이 사업법이 아닌 경쟁법인 경우이다. 가령, SKT가 Melon에 대하여 특화된 DRM을 설정한 경우 Melon의 경쟁사의 입장에서는 호환성이 없어서 이러한 특화된 DRM 설정은 그 경쟁사의 비용을 높여 이익을 침해하는 것이고, 부가된 비용은 소비자에게 전가되어 소비자의 이익 침해로 나타난다.[17] 이러한 상황을 교정하기 위해서 경쟁법에 의한 규제가 존재하는데, 여기서 사업법과 경쟁법에 의한 각 규제의 경합이 나타나게 된다.

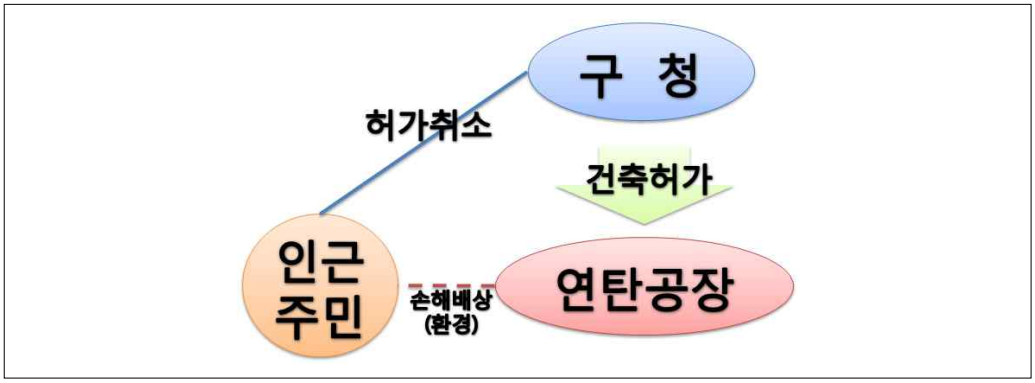
이러한 경우에 사업법 위반 소송과 실체적 경합을 이룬다고 보면, 어느 규제가 더 적합한지, 당사자에게 중복규제의 위험을 부여하는 것이 아닌지, 각 소송의 청구취지는 어디까지 가능한지, 위 당사자 자격이 간접손해자인 이용자에 의해 대위되어 행사될 수 있는지 등의 문제가 된다. 엄격한 실체적 경합을 이룬다고 보는 견해에서는 각 법규가 정해진 바에 따라 엄격하고 독립적으로 행사되어야 하며, 완전히 구별된다고 본다. 한편 단순한 법조 경합이라고 파악하는 관점에서는, 특별법인 사업법 위반만이 적용되고, 경쟁법은 그 적용이 배제된다고 주장한다.

본고에서는 이러한 규제관할권의 충돌에 관한 비교법적 고찰을 통해 합리적 대안을 모색한다.

17) 공정위 심결 07-044

3) 청주시 연탄공장판례: 대판 74누9697

[그림 6] 청주시 연탄공장 사건 개요[18)]



이웃소송은 이웃하는 자들 사이에서 특정인에게 주어지는 수익적 행위가 타인에게는 법률상 불이익을 가져오는 경우에 그 타인이 자기의 법률상 이익의 침해를 다투는 소송이다. 여기에는 허가를 주는 행정청으로서 규제기관이 존재하여 연탄공장이 영업을 할 수 있도록 하는 진입규제를 담당한다. 원고 적격이 인허가 당사자가 아닌 일반 인근주민의 이익에게 확장되는가에 관하여 이를 법률상 보호되어야 할 공권적 법익으로 인정하는 경향이 뚜렷하다.

공권적 법익은 사업법과 경쟁법의 규제가 중복되는 경우, 법률적 구제절차의 범위를 결정하는 가장 중요한 법적 요건 중 하나이다. 가령 사업법 위반의 경우, 사업자 아닌 제3자가 당사자 적격이 있는지를 결정할 때 위 보호법익으로 인정되는 입법상, 판례상 기준이 정립되어야 한다. 본고에서는 다른 나라의 사례를 검토하고, 우리의 규제 현실에 비추어 의미 있는 대안으로 활용될 수 있는지를 모색한다.

라. 행정지도가 개입된 가격담합 시 경쟁법상 규제

사업법과 경쟁법이 경합하는 경우, 실제 사례에서는 해결의 구체적 기준을 세우기가 어렵다. 사업법인 「통신사업법」상 인허가는 재량행위로 보아야 할 것이고, 인허가 사업자를 상대로 행정지도를 한다면 이

18) 대법 74누9697

는 인가거부권 내지 인가취소권을 바탕으로 한 행정지도가 된다. 이러한 경우, 경쟁법의 적용은 행정지도와 경쟁저해 행위와의 인과관계를 따져 적용되어야 한다. 다음의 두 판례는 행정지도와 담합 간의 인과관계에 따라 경쟁법 적용이 부인된 경우와 인정된 경우이다.

1) 경쟁법 적용이 부인된 KT-하나로 가격담합 사건[19]

[그림 7] KT-하나로 가격 담합 사건 개요

본 사안은 경쟁법 적용이 부인된 사안이다. 규제기관은 후발사업자로 경영위기에 빠져있던 하나로통신을 존속시킬 목적으로 시장지배적 사업자로 브랜드 우위에 있던 KT에 대해 요금인하 억제 및 할인상품 출시 억제와 시장점유율의 양보를 주 내용으로 하는 행정지도를 하였다. 그 후 위 행정지도와 동일한 내용으로 KT와 하나로 사이에 담합이 이루어졌다. 위 행정지도와 담합 사이의 인과관계는 부정될 수 없으며, 따라서 경쟁법 적용이 부인되었다.[20]

19) 대법 2007두19416
20) 설민수, “규제완화와 공정거래법의 적용: 행정지도가 개입된 가격담합을 중심으로”, 『저스티스』. 2010.8. 262-263면

2) 경쟁법이 적용 된 KT 가격담합 사건[21)]

[그림 8] KT 가격담합 사건 개요

대법 2007도19584 사건은 위 사건과 달리 경쟁법이 적용된 사안으로, 행정지도는 KT의 접속료와 관련하여 후발사업자에게 KT의 상품을 설명해 줄 것과 후발사업자들도 동일한 유형의 상품을 출시할 수 있도록 접속료를 감면해 주라는 요구였다. KT는 그 기회에 후발사업자들과 동일한 내용의 상품을 출시하기로 담합하였는바, 이는 행정지도와의 사이에 인과관계가 없다.

다음 장에서는 해외의 규제의 이론적 논의와 판례를 분석하여 규제 중복의 해결방안을 모색해 본다.

21) 대법 2007도19584

III. 미국 통신시장의 사업법 규제

1. 미국 사업법상 규제 형식

가. 공익 독점 시대에서의 규제

「1934년 통신법」(Communications Act of 1934)(이하, 「통신법」)의 성립부터 1982년 AT&T가 분할되기까지를 '규제 하의 독점'의 시대라고 부른다. 「통신법」이 성립되고, 정보통신의 규제에 관한 넓은 재량을 가진 규제기관으로서 연방통신위원회(Federal Communications Commission: FCC)가 설립되었다. FCC의 규제목표는 필수설비의 확보와 이에 대한 보편적 역무 제공이며, 기본적으로 벨 시스템이라고 불리는 AT&T의 경영체제를 추인하는 형태로 규제가 이루어졌다.

1) 업종 종단형 사업법 규제[22)]

가) 공익사업(public utility) 독점 사업자 규제

전화기가 발명된 다음 해인 1877년에 벨 전화회사가 설립되고, 이후 이 회사가 AT&T가 된다. 당초에는 전화기 특허를 이용하여 독점적으로 사업을 진행하였는데, 1984년 전후, 특허 기간이 종료되면서 독립계 전화회사들이 시장참여를 시작하게 된다. 그러나 당시에는 장거리통신망을 만드는데 많은 비용이 들었기 때문에, 각지에 지역자본 등에 의한 전화회사가 설립되더라도 장거리 통신에는 참여가 어려운 상황이었다. 따라서 이용자의 요구가 많은 장거리 통신을 제공하기 위하여 이미 네트워크를 구축하고 있는 AT&T와의 상호접속이 필요했고, 그로인해 AT&T는 전미의 전기통신네트워크를 장악하게 된다.

22) 情報通信政策研究所、『海外情報通信判例研究会報告書（第1集)』, 総務省. 2010.

1980년대 중반까지는 유선전화가 통신의 주요 영역이었는데, 전화와 같은 네트워크 사업은 통신망을 설치하는데 막대한 매몰비용이 필요하다. 또한 공급에 있어서의 규모의 경제, 수요에 있어서 네트워크 외부성을 갖는다. 즉, 사업자 간 서로 연계되어 있지 않을 경우, 가입자가 많은 사업자의 가입자는 더 많은 상대방과 통화를 할 수 있어 보다 많은 편익을 제공받게 된다.[23)]

1934년 「통신법」의 성립부터 1982년에 AT&T가 분할되기까지의 '규제 하의 독점' 시대의 「통신법」은 사업법으로서 '규제 하의 독점'을 규율하는 바, 필수설비에 대한 접속 보장, 요율 인가를 통한 적정 요금 유지 등이 사업법의 중요한 입법 목적이다. FCC는 통신사업자에게 사업자로서의 자격을 부여하고, 나아가 사업범위와 내용을 규정하는 감독관청이 된다. 이는 합병의 경우와 같이 인수기업(acquiring firm)이 피인수기업(to-be-acquired firm)의 영역으로 진입하고 피인수 기업이 해당 영역에서 퇴출하는 법적 효과가 동시에 일어날 때, FCC가 합병심사 시 인수기업이 피인수기업이 보유하고 있는 인가(license)를 습득하고 사용할 수 있도록 허용되어야 하는지 여부를 판단하는 과정에서 명확하게 나타난다.

[표 3] 인가(license) 소유 여부

인가 소유	인수 기업	피인수 기업	FCC 관할 대상
인수전	X	O	피인수기업
인수후	O	X	인수기업

나) 수직 착취형 독점 사업자 규제

통신시장에서의 사업법은 시장종단형 규제의 형태를 띠게 되는데, 복수의 시장에서의 독점 사업자를 규율하기 위해서 '독점의 지렛대(leveraging)' 이론이 적용되었다. '독점의 지렛대'는 어느 시장에서의 독점력을 이용하여 거래거절 등의 행위를 함으로써, 해당 시장이 아니라

23) 신종철, 『통신법해설: 전기통신사업법의 해석과 사례』, 진한엠엔비, 2013, 16면.

아직 독점력을 획득하지 못한 다른 시장에서 경쟁 상 유리한 효과를 얻는 전략을 전개하는 것을 말한다. 설사 법적으로 획득된 독점력의 이용이라도 그것이 경쟁을 배제하고, 경쟁상의 이점을 획득하거나 경쟁상대를 축출하기 위해서 이용되는 것은 위법이다. 어느 시장에서의 독점력의 이용이 다른 시장에서의 경쟁의 침해 또는 축출을 목적으로 할 때는 경쟁법 위반에 해당되는 것이다.

복수의 시장을 수직적으로 연결하는 종단통합형 시장행태는, 만일 그 통합의 형태가 배타적이라면, 브랜드 내 경쟁(intra-brand competition)은 줄이지만, 반면에 유통채널의 확보로 브랜드 간 경쟁(inter-brand competition)은 늘이는 결과를 낳는다. 경쟁법 규제기관은 이와 같은 수직적 반경쟁 행위를 수평적 반경쟁 행위보다 너그럽게 받아들이는 경향을 보인다. 여기에서 사업법 규제의 필요성이 대두되는 것이다.

독자적으로 「통신법」 하에서 반경쟁 행위를 규제할 권한이 있는 FCC는 수직적 반경쟁 행위에 대하여 일반 규제기관에 비해서 부정적인 태도를 취한다. 모든 산업을 규제하는 일반규제기관과는 달리 전문규제기관인 FCC는 정보통신산업만을 규제하기 때문에 산업 전반에 대한 보다 많은 전문지식을 갖추고 있다. 또한, 앞서 언급한 바와 같이 전문규제기관은 거시적으로 통신 산업의 발전, 거시지표의 고려, 소비자의 보호 같은 비경쟁관련 이슈도 다루기 때문에 일반규제기관이 간과하기 쉬운 수직적 반경쟁 행위를 규제하는데 적당하다.

수직적 반경쟁 행위 규제에 있어서 FCC의 필요성을 분명히 보여주는 사례는 'Comcast와 General Electric 그리고 NBC Universal의 합병 사건'이다. NBCU는 방송 컨텐츠 제공자이고, Comcast는 컨텐츠를 배포하는 회사이므로 종단통합형 수직적 합병에 해당하는 바, 경쟁 당국은 이에 대해 아무런 제동을 걸지 못한 반면에, FCC는 NBCU 방송 프로그램에 Comcast의 경쟁자가 접근하지 못하도록 하여 경쟁을 약화시킬 우려가 있다는 점에 주목하였다. 또한 반대로 Comcast가 NBCU 이외의 방송사업자로부터는 방송 컨텐츠를 제공 받지 않아 컨텐츠 제작 시장의 경쟁을 약화시킬 우려도 있었다. 이에 FCC는 경쟁법 규제기관이 중요하게 생각하는 요인뿐만 아니라, 경제 모델, 실증 연구 등을 통해 전반적이고 세부적인 로드맵을 제시했다.[24)]

24) FCC, "Comcast Corp./General Electric Company, and NBC Universal, Inc., Memorandum Opinion and

Comcast-NBCU의 합병의 피해를 분석하기 위하여, 해당 합병이 Comcast로 하여금 경쟁회사를 배제할 수 있거나 가격을 마음대로 올릴 수 있는 충분한 시장지배력을 갖도록 하는지, 경쟁에 미치는 피해가 어느 정도인지를 고려하였다. 우선 1단계에서 Comcast가 경쟁회사를 영구히, 혹은 일시적으로 배제했는가, 그리고 경쟁회사의 경영비용을 증가시켰는가를 평가하였는데, FCC는 Comcast가 이 세 가지 방해전략을 다 사용할 수 있는 입장에 있다고 판단하였다. 2단계에서는 Comcast가 경쟁회사를 배제시키는 것이 과연 해당 시장의 경쟁 감소에 영향을 미치는가를 고려하였다.

또한 FCC는 Comcast-NBCU 합병 건을 다루면서 추가적으로 경제모델과 실증분석도 사용하였다. FCC는 기존의 합병에 사용되었던 경제모델이나 이론 등을 각 합병 건에 맞게 개량하여 적용하는데, 이는 FCC가 경쟁법 규제기관보다 정보통신시장에 대해 보다 깊은 전문지식을 갖추고 있기 때문에 가능한 것이다. Comcast-NBCU 합병 건에서 FCC는 다음의 경제 연구를 사용하였다.

첫째, 고객의 이전과 가격의 변화 등을 종합적으로 계산해서 이익과 손해를 분석하였다. 둘째, 통합 회사와 경쟁회사의 프로그램 제공 가격 협상에 대한 각종 시나리오를 분석하였다. 종단통합형 합병에서는 시장 간 상호작용의 분석이 사업법 규제의 내용이 되며, 이는 단일시장의 경쟁분석 이상의 것이다. 셋째, 프로그램 단가 실증분석으로, 합병이 결과적으로 프로그램 단가가 상승하는 결과를 초래하였는지 등을 분석하였다. 넷째, 과거 반경쟁 행위 이력 분석으로 Comcast가 자회사의 프로그램 방영을 선호했는지, 만약에 그렇다면 자회사 프로그램 선호가 효율성 향상을 위해서였는지, 아니면 단순히 타회사를 배제한 반경쟁 행위였는지 등을 종합적으로 분석하였다. 이는 단지 경쟁자 입장에서의 손해분석을 넘어서 소비자의 관점에서 피해를 확인한 것으로 사업법 규제의 정당성을 보여준다.

수직적 종단합병에서 FCC 규제관할의 필요성을 정당화하는 또 다른 예는 1997년 'SBC와 AT&T의 합병 심사 사례'이다. 경쟁당국은 지역전화 회사인 SBC와 장거리 전화 회사인 AT&T의 합병은 보완적인 성격이라고 보고 합병을 관대하게 넘겼으나, FCC는 장기적인 산업 전반

Order," FCC 11-4. 2011.

에 걸친 청사진을 가지고 해당 합병 건을 심사한다면, 장거리 회사와 단거리 회사도 빠른 시일 내에 경쟁관계에 돌입할 것이라고 판단하여 위 합병을 막았다. 결국 SBC와 AT&T는 8년이 지난 2005년에서야 FCC가 요구한 서비스 품질보호, 가격동결 정책을 통한 소비자보호, 정보통신서비스 발전에의 기여를 조건으로 하여 합병에 성공할 수 있었다.[25)]

'Verizon과 MCI의 수직 합병'도 2005년에서야 FCC의 허가를 이끌어 낼 수 있었다. FCC는 Verizon과 MCI의 합병을 허가하면서도, 위와 같은 조건을 걸었는데, 이는 거시경제적 요소를 포함하여 비경쟁적인 측면에서 FCC가 달성하고자 하는 목표에 보다 근접하게 해주는 것으로, 위 조건 모두가 공익을 위한 것임에 틀림이 없어 경쟁법 규제기관은 할 수 없는 역할을 FCC가 수행한 것이라고 볼 수 있다.[26)]

'AOL과 Time Warner의 합병'에서도 FCC의 소비자를 보호하려는 노력이 엿보인다. FCC는 AOL에 합병 전부터 제공해오던 인스턴트 메시지 서비스를 앞으로도 지속적으로 운용하도록 지시했는데, 이는 합병 자체가 경쟁에 미치는 영향과는 아무런 관련이 없다고 할 것이나, 해당 서비스를 사용하던 소비자를 보호하는 기능을 수행한다는 측면에서 거시적인 역할을 수행한 것으로 볼 수 있다.[27)]

다) 절차적 편의주의(procedural opportunism)

미국 통신시장에서의 1차적 규제권은 사업법 집행 당국인 FCC에 있다. FCC는 입법 기능, 행정 기능, 사법 기능을 통합적으로 담당한다. 이는 행정적 편의와 효율성을 확보하며, 아울러 이용자인 국민들의 편익을 증대하려는 행정목적을 위한 시스템이다. 또한 FCC는 공익 목표를 지향하며, 통신 서비스 품질 보호, 통신 서비스의 민영화 추진, 다양한 정보와 관점에 대한 고객의 접근성 보장 등을 추구함에 있어, 준 입법권, 준 행정권, 준 사법권을 통합적으로 행사한다.

이를 '절차적 편의주의(procedural opportunism)'라고 하며, 궁극적

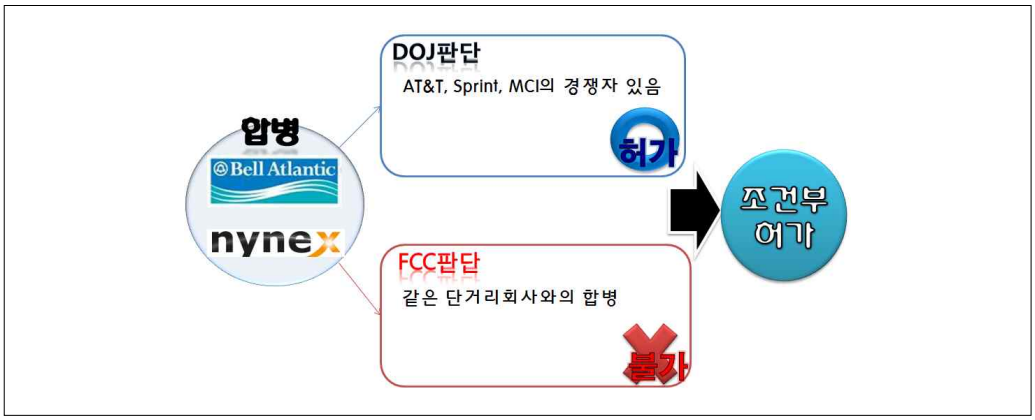
25) FCC, "SBC/AT&T, Memorandum Opinion and Order," FCC 06-183 (2005)
26) FCC, "Verizon/MCI, Memorandum Opinion and Order," FCC 06-184 (2005).
27) Weiser, Philip J., "Reexamining the Legacy of Dual Regulation: Reforming Dual Merger Review by the DOJ and the FCC," 61 *Federal Communications Law Journal* 167. 2008.; FCC, "AOL/Time Warner, Memorandum Opinion and Order," FCC 01-12, 16 F.C.C.R. 6547. 2001.

으로 사업법의 감독기관으로서 감독의 효율성을 확보하기 위한 것이다. FCC는 정보통신분야의 인허가 과정에서 폭넓은 재량권을 행사할 수 있다. FCC의 인허가, 합병심사에서 회사 측에서 자신들의 사업이 공익에 반하지 않음과 공익에 좋음을 증명해야 하며, 이는 피심사 대상인 기업의 입장에서는 사업비용으로 인식된다.[28]

2) 진입/퇴출 규제

가) 확대된 경쟁: 네트워크 간 경쟁[29]

[그림 9] Bell Atlantic과 NYNEX의 합병 사례



사업법 상 진입규제는 인허가권 행사로 나타난다. 통신사업자의 인허가는 사업양도, 인수합병 등 퇴출시에도 심사된다. 기존 사업자를 인수하는 새로운 사업자에 대한 새로운 적격성 심사과정이 포함되기 때문이다. 통신사간 인수합병의 대표적 사례로 'Bell Atlantic과 NYNEX의 합병'을 꼽을 수 있다. FCC는 양자가 모두 단거리 전화회사인 NYNEX와 Bell Atlantic 간의 합병을 심사하였다.[30]

당시 뉴욕시에서 가장 큰 단거리 전화회사였던 NYNEX가 경쟁자인 Bell Atlantic을 인수하는 경우 충분한 경쟁이 보장될 것인가가 이 사건

28) Baker, Jonathan B., "Sector-Specific Competition Enforcement at the FCC," *The Federal Communication*, September 21, 2010.
29) FCC, "Bell Atlantic/NYNEX Corp.," 32 F.C.C.R. 19,985. 1997.
30) FCC, 1997.

의 쟁점이었다. FCC는 실질적으로 NYNEX의 라이벌이 될 잠재력이 있는 회사는 뉴욕시에 인접한 뉴저지 지역에서 강세를 보이고 있는 Bell Atlantic 외에는 없다고 판단하였다. 물론 AT&T, Sprint 및 MCI도 단거리 망을 보유하고 있기는 하지만, 이들은 모두 장거리 중심 전화회사로 단거리 전화회사와 기본적으로 치열한 경쟁관계에 있다고 보기는 힘들었기 때문이다. 따라서 NYNEX와 Bell Atlantic의 합병이 지나친 반경쟁을 초래할 수 있다고 판단한 것인데, 이는 FCC가 행하는 합병심사가 단순한 획정 시장 내에서의 경쟁뿐 아니라, 거시적 산업규제의 성격까지 띠고 있음을 보여주는 것이다.

나) 거시경제적 규제

거시경제적 관점에서의 규제는 설정하여야 할 통신 산업 진보의 방향성, 정보통신 산업 전반에 대한 방향성을 고려하고, 규제 완화, 서비스 및 품질 보호, 보편적 역무 확보 문제를 고려하여야 한다. 또한 지역 사회 및 문화 발전도 염두 해두어야 한다. 이처럼 거시적 환경에 대한 전반적인 분석에 의해 장기적인 외부의 기회와 위협을 연구하고 판단함으로써 거시경제적 규제가 마련되는 것이다.

통신서비스산업의 민영화, 정보통신정책 추구 등 정보통신산업의 발전을 위한 규제, GDP대비 중요도, 소득/부의 재분배, 실업 예방 등을 위한 거시지표의 고려, 그리고 망 중립성, 서비스, 품질 및 가격의 보호, 다양한 정보와 관점에 대한 소비자의 접근성 보장을 통한 소비자 보호 등이 거시적 관점의 쟁점들이다. 아래에서는 통신산업 발전, 거시지표의 고려, 소비자 보호를 위한 FCC의 규제에 대해서 알아보도록 한다.

(1) 통신산업발전

[그림 10] SBC와 AT&T의 합병 사례

'SBC와 AT&T의 합병' 심사에서, 경쟁당국은 지역 전화회사인 SBC와 장거리 전화회사인 AT&T의 합병은 서로 '대체적'인 것이 아니라 '보완적'이라고 보아, 합병을 관대하게 인정하였다. 그러나 FCC는 장기적인 산업 전반에 걸친 청사진을 가지고 해당 합병 건을 심사한다면 장거리 회사와 단거리 회사도 빠른 시일 내에 경쟁관계에 돌입할 것이라고 판단하였다. FCC는 네트워크간 경쟁을 이끌어내어 가능한 한 규제완화를 허용하고자 했기 때문에, 1997년 당시 FCC의 의장이었던 훈트(Reed E. Hundt)는 "AT&T와 SBC의 합병은 상상도 할 수 없는 일"이라며 위 합병을 막았다. SBC와 AT&T는 결국 2005년이 되어서야 FCC가 네 가지의 산업 전체 정책결정을 염두에 두고 만든 해결방안을 이행하는 것을 조건으로 합병에 성공했다.[31] **이는 전통적인 시장획정 방안과는 궤를 달리하는 FCC의 거시경제적 규제로서, 여기서 경쟁법 규제와의 본질적 차이가 드러난다.**

'Verizon과 MCI의 합병' 건에서도 FCC는 비슷한 입장을 취한다. FCC는 Verizon과 MCI의 합병을 허가하면서 네 가지의 조건을 내거는데, 이 네 가지 조건 모두가 협의의 경쟁과는 직접 관련이 없는 것이었다.[32] 조건 가운데 하나인 Naked DSL의 제공은 일반 DSL과는 다르게 전화선 없이도 인터넷 연결을 제공하는 것으로 통신산업 발전을 위해서 FCC가 지원하는 정책이었으며, 또한 FCC는 Verizon과 MCI의 인터넷 백본 제휴사로 하여금 접근 정책을 인터넷 웹사이트에 밝히도록 하

31) FCC, "SBC/AT&T, Memorandum Opinion and Order," FCC 06-183. 2005. FCC가 내건 네 가지 조건은 ① 서비스 품질보증, ② 가격동결정책을 통한 소비자 보호, ③ 정보통신서비스 발전, ④ 망 중립성 제도의 강화이다.

32) FCC, "Verizon/MCI, Memorandum Opinion and Order," FCC 06-184 (2005).

였는데, 이는 미래에 발생할 수도 있는 반독점 이슈를 미리 막을 수 있는 세이프가드 역할을 수행하여 장기적으로 통신산업 발전에 기여할 것으로 기대 되었다.

(2) 거시경제 지표의 고려

(가) 국내총생산(GDP): 「하트-스코트-로디뇨 법」

1976년에 제정된 「하트-스코트-로디뇨 법」(Hart-Scott-Rodino Acts)은 기업합병 심사에 대한 법적 기준을 규정하고 있다. 「하트-스코트-로디뇨 법」에 의하면 일정 금액 이상 규모(Size of Transaction Test)의 기업합병이 일어나거나, 회사의 자산이 양도될 경우, 매수자는 이와 같은 거래의 승인을 요청해야 한다. 기업합병에 대한 사전심사 시 '일정 금액 이상 규모의 기업합병' 에 대한 기준은 매년 국내총생산과 인플레이션을 반영한다.[33] 가령, 경제 불황을 겪은 2010년에는 합병신고 기준이 처음으로 하향 조정되었다가, 경기가 조금씩 회복되면서 그에 상응하는 미국 국내총생산이 증가한 결과 2011년과 2012년에는 기업합병 심사기준액이 다시 상향 조정되었다. 2013년의 경우, 2월 11일부터 6,820만 달러 이상 일정 자산 규모를 갖는 기업 간 합병을 심사한다. 이는 2012년 기준 7,090만 달러 보다 하향 조정된 기준수치로, 매년 변동하는 경제를 국내총생산과 인플레이션과 같은 거시지표로 반영하여 산정한 결과이다.

「하트-스코트-로디뇨 법」은 '일정 자산금액 이상 소유의 개인(Size of Person Test)'에 대한 기준도 마련하고 있다. 2013년 기준에 따르면, 순매출액 혹은 총자산 1,420만 달러 이상의 개인이 소유하는 기업과 상대방 기업의 개인이 14,180만 달러 이상을 소유한 경우로 설정하였다. 이처럼 일정 금액 이상 규모의 기업과 일정 자산금액 이상 소유의 개인을 사전에 신고하고 경쟁제한성 여부를 사전에 신속하게 검토하도록 한 것이 「하트-스코트-로디뇨 법」의 제정 목적이다.

33) http://www.ftc.gov/bc/hsr/introguides/guide2.pdf

(나) 소득 재분배

FCC의 규제 기준으로 제시되는 "공공의 이익, 편의, 필요성"에는 소득과 부의 재분배라는 측면도 포함된다.[34] 징수된 과징금을 FCC는 특정한 전화이용자, 저소득층, 농촌 및 산간지역 이용자에게 정부 보조금의 형태로 지급한다. 또한 장거리 전화 이용자들보다 단거리 전화 이용자에게 보조금 형태로 이용요금을 지급하기도 한다. 이는 저소득층이 장거리보다 단거리 전화를 더 많이 이용한다고 판단했기 때문이다. 이처럼 과징금을 정부 보조금의 형태로 지급하여 소득과 부의 재분배 효과를 낳는다. 이와 같이 '공공의 이익(public interest)' 이라는 측면에서 소득과 부를 보조금 형태로 재분배하여, 규제의 대한 정당성이 법적으로 마련되었으며, 이처럼 소득과 부의 재분배라는 측면의 거시적 경제를 고려하여 사업법을 집행하여 온 것이다.

(다) 실업문제

2011. 3. 20. 미 이동통신사업자 규모 2위인 AT&T가 4위인 T-Mobile USA를 모회사인 독일의 Deutsche Telecom과의 협의를 통해 390억 달러에 인수하겠다는 발표를 하였다. 2009년 금융위기 이후 가장 큰 규모의 기업 인수합병 건인 동시에, AT&T와 T-Mobile USA의 합병으로 인해 이동통신사업자 빅3의 나머지 두 사업체인 버라이즌(Verizon)사, 스프린트(Sprint Nextel)사, 그리고 소비자에 대한 영향을 평가해야 하기 때문에 정계 및 규제기관의 관심이 더 크게 쏠렸다.

인수합병 계획이 발표되자 이동통신사업자 3위인 스프린트사는 반대의사를 표시하였고, FCC 율리어스 게나춥스키(Julius Genachowski) 의장은 AT&T가 T-Mobile USA를 인수 합병할 때 "공공의 이익"을 증명해야 한다고 주장하였다.[35] 이에 대하여 AT&T는 합병 계획에 중소 이동통신사에게 T-Mobile의 자산의 40%를 매각할 것이라는 계획을 포

34) Krattenmaker, Thomas G., "The True Believers: Some Thoughts on Competition, Regulation, the FTC and the FCC." *Ftc.gov*. Federal Trade Commission, 16 Sept. 2004.
35) Levin, Harvey J., "Social Welfare Aspects of FCC Broadcast Licensing Standards," *American Journal of Economics and Sociology*, Vol. 13, No. 1. Oct. 1953. pp. 39-55.

함시켰으나, 12월 19일, 결국 AT&T는 T-Mobile USA의 인수 합병 계획을 철회한다는 최종적 입장을 밝혔다.

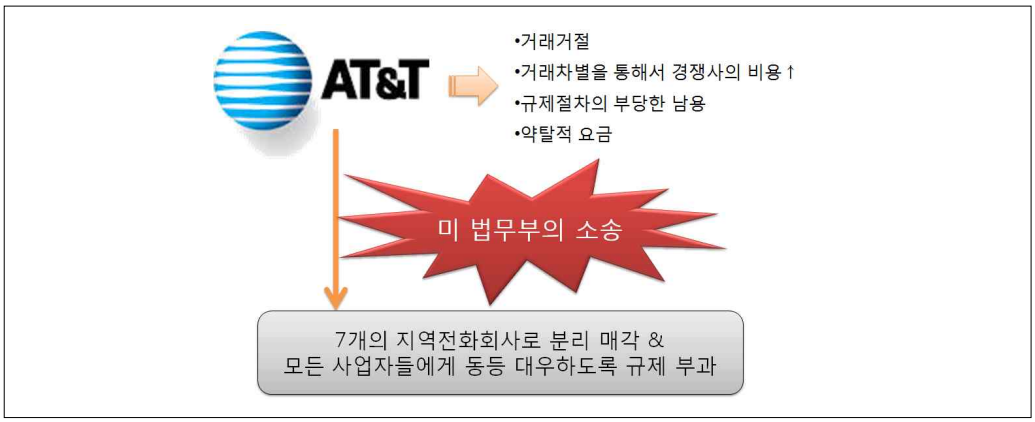
이는 AT&T와 T-Mobile USA의 인수합병으로 인한 실업을 예방하기 위해 규제 당국이 개입하여 결과적으로 합병 계획을 무산시킨 전형적인 사례이다. 거대 기업 간 인수합병을 독점 방지, 경쟁제한 방지를 이유로 반대한 규제 당국의 의견에는 거시적 경제 관점, 즉 실업예방이 포함되어 있다. 합병으로 인한 실업을 사전에 막기 위한 노력이 기존 회사들의 노동조합의 단체교섭권이 확대된다는 긍정적 효과보다도 더 중요하다고 판단한 것이다.

나. 수정최종판결(Modified Final Judgement) 체제

AT&T의 분할이 결정된 1982년 수정최종판결(Modified Final Judgement: MFJ)을 기점으로 공익 독점의 시대는 수정최종판결체제로 옮겨가게 된다. MFJ 체제에서의 규제는 독점적·시장지배적 사업자와 비지배적 사업자에 대한 비대칭 규제에서 가장 중요한 사업법 상 규제는 상호접속의 규제와 '인가약관 적법성 추정 원칙'으로 대표되는 약관 규제이다.

1) 수정최종판결

[그림 11] AT&T의 분할 결정



AT&T의 분할(divestiture)이 결정된 1982년 MFJ는 AT&T에 대한 독점금지 소송을 결착시키기 위한 것으로, 형식적으로는 1956년의 동의 판결을 수정한 것에 해당한다. 이로써 ① AT&T가 보유하고 있던 지역 전화회사의 소유 분리, ② AT&T의 사업을 장거리 회선부문으로 한정, ③ 분리 자회사의 업무범위의 자유화 등이 결정되었다.

1974년 미 법무부(Department of Justice: DOJ)는 AT&T의 독점적 지위가 적절하게 억제되지 못하고 있다고 판단하여, AT&T를 연방법원에 기소하였다. DOJ가 제기한 AT&T의 혐의 내용은 다음과 같다. 경쟁사에게 부과하는 접속료를 자사에게 제공하는 수준보다 높게 책정하거나 접속지연 및 접속품질 저하를 통해 경쟁사를 불리하게 한 행위 및 경쟁사를 배제하기 위하여 약탈적 가격을 책정한 행위가 「독점금지법」제2조에 위반한다는 것이다.[36)]

경쟁사업자들이 지속적으로 제기해 온 또 하나의 불만은, AT&T의 약탈적 가격이었다. 그러나 규제당국이 AT&T의 요금구조를 효과적으로 규제하지 못하여 법정에서의 약탈적 가격의 입증은 이루어지지 못했다. AT&T 자신조차도 개별 서비스의 비용을 정확하게 파악하고 있지 못했기 때문에 AT&T가 약탈적 가격을 책정했다는 것(가격이 어떤 기준의 비용 이하에서 설정되었다는 점)을 입증할 수 없었던 것이다. 따라서 DOJ는 AT&T가 비용과 무관하게 가격을 책정했다는 점을 들어 변형된 형태의 약탈적 가격을 주장하였다. AT&T가 경쟁이 도입된 부문의 서비스 가격을 설정하는데 있어 경쟁시장 조건, 즉 경쟁사의 배제만을 고려했을 뿐 비용 수준에 대한 연구가 없었다는 것으로, 경쟁시장에서 가격을 설정하는 데 있어 AT&T의 유일한 목적은 독점의 유지라는 주장이다.

실제 AT&T 내부 문서에서도 비용에 대한 정보 없이 요금이 책정되었음이 나타났는데, 규제를 받지 않는 기업이 비용과 무관하게 요금을 책정하는 것은 비합리적이다. 그러나 AT&T와 같이 수익율 규제(rate-of-return regulation)를 받는 기업은 발생하는 비용을 충당할 수 있는 수준에서 요금이 책정되므로, 경쟁부문의 서비스 요금은 자신의 시장을 방어하기에 충분히 낮은 수준으로 설정하고 여기서 발생하는 손실을 규제 부문의 요금 인상을 통해 보전 받을 수 있게 되어 규제의

36) 김희수 외, 『통신사업의 합리적 비대칭 규제방안 연구』, 연구보고 01-52, 정보통신정책연구원. 2001. 12.

대상이 되는 기업은 이러한 형태의 약탈적 가격을 책정할 동기와 능력을 갖게 된다.

이 사건은 1982년 연방 D.C. 항소법원의 해롤드 그린(Harold Greene) 판사의 조정결정(consent decree)에 의해 종결되었는데, 1954년의 조정결정이 수정되었다는 점에서 '수정최종판결'(MFJ)이라고 불린다. 이 MFJ에 의해 1984. 1. 1. AT&T는 22개 지역전화운영회사(Regional Bell Operating Companies: RBOC)로 분할되었고, 시내전화와 장거리전화가 분리되었다.[37]

MFJ에서 AT&T의 장거리전화 부문과 시내전화부문을 분리하도록 한 것은 경쟁부문을 AT&T에 남겨두고 독점적인 시내전화 부문을 매각하라는 것이다. 이는 불공정 경쟁의 발생 원인이 근본적으로 규제를 받는 필수설비 부문과 경쟁부문이 통합된데서 비롯되었으므로 필수설비 부문과 경쟁부문의 경계선을 분명하게 하되, 단지 조직을 자회사로 분리하는 조치 정도가 아니라 더 강한 구조분리가 선택됐다. 이러한 판결은 수직 통합된 상태에서 규제를 통해 반경쟁적 행위를 금지하는 방식이 비효율적이라는 DOJ의 입장이 반영된 것이다.

여기서 지역통신과 장거리통신의 분리에 관하여는, 전미를 LATA(Local Access and Transport Area)라는 지역으로 나누고, 그 지역 내의 통신을 지역통신, 지역에 걸치는 것을 장거리통신이라고 규정하였다. 이로써 시내통신, LATA 내 통신, LATA 간 통신 및 주(州)간 통신으로 나누어 각각 사업자와 규제기관이 다른 체제가 되었다. 시내통신과 LATA 내 통신은 지역전화회사가 제공하여 주의 공익사업위원회가 규제하고, 주 내 LATA 간 통신은 AT&T가 제공하고 주의 공익사업위원회가 규제하며, 주간 통신에 관해서는 AT&T가 제공하고 FCC가 규제하는 것으로 되었다.

2) 상호접속 규제

MFJ 체제에서 가장 중요한 사업법 상 규제는 상호접속의 규제로서 이는 기간통신사업자에 대하여 재판매를 의무화하고 액세스에 있어서

37) 안덕근, "통신시장 관련 이중규제 판례 연구: Trinko 사례 중심으로", 『법학논총』, 제24집 제4호. 2007.

의 차별을 금지하는 것을 골자로 한다. 즉, ① 독점적 사업자가 필수 시설을 보유하고, ② 경쟁자가 실제상으로 또는 합리적으로 해당 시설을 조달할 수 없으며, ③ 독점적 사업자가 경쟁자에 대하여 필수 시설에 대한 제공을 거절하고 있는데, ④ 해당 시설의 공동이용은 실제적으로 가능하다면, 기간통신사업자의 필수 설비 재판매가 의무화 되고, 접속에 있어서 차별을 금지하는 것으로 규제가 이루어진다.

MFJ 체제 이전의 AT&T는 다른 기업들의 통신시스템이 자사의 전국 네트워크와 연결되는 것을 거부하여 왔다. AT&T의 경쟁사들은 전용회선을 통해 장거리 시장에 진입하였는데, 경쟁사가 한 도시의 기업 통신망을 다른 지역의 시내전화와 연결시키는 장거리 전용 통신시장을 열었어도 시내전화와의 상호접속이 없이는 장거리 전용 통신망이 기업 내부 통신망 외에는 의미가 없어 대기업 이외에는 수요가 없게 된다. 그러므로 장거리 전용 통신시장의 형성에 있어 시내전화와의 상호접속 허용이 필수적인 것이었다. 시내전화 교환기에 대한 접속은 회선측(line-side) 접속과 트렁크측(trunk-side)접속으로 크게 나뉘는데, 회선측 접속은 AT&T가 상당한 비용을 경쟁사들에게 부담시키므로 경쟁사들은 트렁크측 접속을 선호했으나 AT&T가 이를 거부하여 분쟁이 지속되던 상황이었고, AT&T의 이러한 행위는 반경쟁적 사례로서 지적되어 왔다.

MFJ는 경쟁사들에게 AT&T보다 높지 않은 시내 접속료를 보장함으로써 장거리 부문의 유효경쟁체제를 유지하고자 하였다. 서비스 품질을 기준으로 동등접속이 이루어지도록 함으로써 분리된 시내전화 사업자들이 비용을 평균하여 모든 경쟁사에 대하여 동일한 접속료를 부과하도록 하였다. 즉, 분리된 시내전화 회사가 AT&T에 대하여 접속을 제공하는 것이 비용이 적게 들더라도 경쟁사와 동일하게 접속료를 부과하도록 한 것이다. 시내전화 회사들이 모든 교환사업자(inter-exchange carriers)들과 정보서비스제공 사업자들(information service providers)에게 교환접속(exchange access), 정보접속(information access), 교환 서비스를 세분화된 개별 요금기준으로 제공하되 유형, 품질 및 요금에 있어 AT&T와 동등하게 제공하도록 했다.

3) 약관 규제

통신사업자의 영업활동에 대한 규제 당국의 인가가 있고 그 규제책임을 당국에 지우려는 입법의도가 인정될 때, 일단 위의 인가된 계약조건, 특히 가격조건은 규제 당국의 재량으로 심사된 것이므로 그 적법성이 추정된다고 할 것이다. 이를 '**인가약관 적법성 추정 원칙(filed rate doctrine)**'이라 한다.[38] 이 원칙은 당사자 사이의 개별계약에 앞서 통신위에 등록된 표준약관의 적법성을 추정하여 이용 약관에 정해진 등록요금을 우선시 한다. 이는 사업자가 이용자를 유인하기 위하여 부당하게 낮은 요금을 책정하지 못하도록 하여 공정경쟁을 유인하기 위하여 제정되었다.

다. 「1996 통신법(Telecommunications Act of 1996)」의 규제

「1996년 통신법(Telecommunications Act of 1996)」(이하, 「96년 법」)은 그 이전인 1934년에 제정된 연방통신법의 일부를 수정한 형태로 성립되었다. 「96년 법」은 모든 정보통신시장에서의 경쟁도입을 촉진함을 목적으로 하여, 경쟁에 대한 진입장벽을 제거함으로써 전화 등 통신서비스의 제공에서의 경쟁을 촉진함을 강조하고 있다. 이에 따라 시내 상호접속규제, 보편적 역무를 보장하는 약관규제, 접속요금을 규율하는 요금규제가 FCC에 의해 부과되었다.

1) 사업자별 규제

「96년 법」은 Title Ⅰ에서 정보서비스를 규율하고, TitleⅡ는 전화회사 등 기간통신사업자에 대한 규율을 규정하며, TitleⅢ에서 TV, 이동통신, 라디오 위성방송 등의 관할을, TitleⅣ에서 케이블 방송산업 등의 관할을 규율하고 있다. 이 중 가장 문제가 되고 있는 것은 Title Ⅰ이 규정하는 FCC의 권한과 관할이 연방통상위원회(Fair Trade Commission:

38) '인가약관 적법성 추정원칙(filed tariff doctrine)'은 인가약관에 정해진 등록 요금에 적법성을 부여하는 것으로 '등록 요금 원칙'이라고도 한다.

FTC)와 중복된다는 것이다.

FCC는 '기본서비스(basic service)'와 '고도서비스(enhanced service)'를 구별하고, 고도서비스 시장은 매우 경쟁적이고, 또 진입장벽이 낮은 것을 근거로, 고도서비스 제공자는 음성전화 서비스를 제공하는 전화회사와는 달리 1934년 「통신법」의 제2편의 규제에 따르는 '기간통신사업자'로 취급하지 않았다. FCC는 고도서비스 시장으로의 진입 및 고도서비스 제공자에 대한 기본서비스 제공 조건의 부과에 대해서, 「96년 법」의 제1편에 기인하여 관할권을 행사해 왔다. 위 법은 '전기통신서비스' 및 '정보서비스'의 정의를 내리고 있는데, 여기의 '정보서비스'가 '고도서비스'와 유사한 것이다. FCC는 ISP가 '순수한 전송회로' 를 제공하지 않는 것, 즉, 컴퓨터에 의한 정보의 처리, 정보의 제공, 및 컴퓨터를 통한 그 밖의 제공'을 정보서비스로 분류하는 것은 적절하다고 판단했다.

2) 재판매/액세스 규제

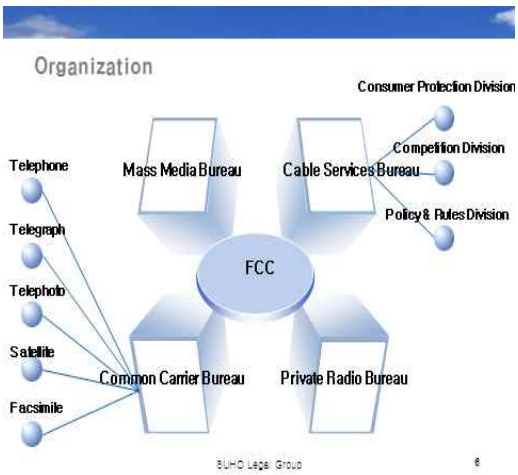
「96년 법」은 모든 통신사업자에 대하여 다른 통신사업자의 설비·기기와의 사이에 직접·간접의 상호접속 의무가 있음을 일반적으로 확인했다. 그러나 통신사업자라고 해도 원천 설비를 가진 사업자부터 단순한 부가통신사업자까지 그 실체는 천차만별이어서 모두를 일률적으로 다루기에는 무리가 있으므로, 「전기통신법」은 원천 설비의 보유상황에 따라서 통신사업자를 두 종류로 크게 나누고, 각각 다른 구체적 의무를 부과하고 있다.[39]

즉, 일반적인 전기통신사업자에게는 설비·기기에 대한 직접·간접의 **상호접속의무**(251조(a)항(1)호) 및 공중이나 장애자의 전기통신서비스에 대한 접근 확보를 위한 기술표준에의 준거의무(동2호)를 부과하는데 그치는 반면, 원천 설비를 가진 **지역교환사업자(LECs 전화교환서비스 내지 교환접근을 제공하는 사업자)**에 대해서는, 자기가 제공하는 전기통신서비스의 재판매 거절이나 **차별적 취급 등의 금지**(251조(b)항(1)호), 번호이동성의 제공의무(동2호), 경쟁자에 대한 다이얼패리티(자사에 가

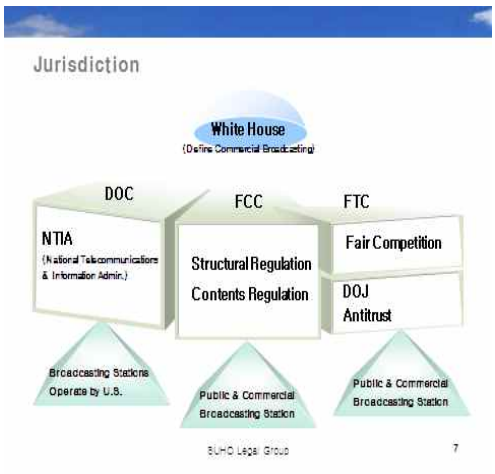
39) 土佐和生、"事業法規制と独禁法規制の排他制御", 立命官法学, 2·3号 (300·301号). 2005.

입하지 않은 이용자라도 그자가 지정하는 서비스 제공자에게 특별한 다이얼링을 하지 않고 자동으로 접속시키는 제도)의 제공의무(동3호) 등을 부과함으로써 그 의무의 내용을 가중하고 있다.

[그림 12] FCC 조직



[그림 13] FCC, DOC, FTC의 관할



3) 요소별 분리접속 의무

「96년 법」은 정보통신산업에서의 경쟁의 활성화를 내용으로 하는 규제개혁의 중심적 기둥으로서 경쟁을 활성화하는데 기여하여 왔다.[40] 그 가운데서도 특히 지역정보통신시장에서는 경쟁도입 시에 가장 문제가 되는 지역정보통신망의 '기존 지역 교환 통신사업자(Incumbent Local Exchange Carrier: ILEC)'에 의한 길목(bottleneck) 독점을 해소하는 조치가 중요하다. 「96년 법」은 ILEC에 대해서 '신규 지역 교환 통신사업자(Competitive Local Exchange Carrier: CLEC)'의 지역통신망으로의 접속의무를 규정하고, ILEC가 보유하는 시설에 **요소별 분리접속 (Unbundled Access)**[41]을 함으로써 경쟁을 촉진하려고 하였다.

위와 같은 통신사업을 함에 있어서 필요불가결한 시설을 독점적으

40) 미국에서의 정보통신산업에 대한 주요 규제의 하나인 분리접속 의무에 관한 연방통신위원회(FCC)가 공표한 보고서, 2003.8.21

41) 요소별 분리접속(unbundled access): 네트워크의 기능이나 구성요소를 세밀하게 분해하여 필요시 되는 것만을 공급하는, 말하자면 알라카르테 방식의 접속형태

로 소유하고 있는 ILEC와 그 경쟁상대인 CLEC와 사이의 접속에 관한 규칙의 하나인 요소별 분리접속의무에 관하여는 위 법 제251조가 규정하고 있다. 일반적으로 위 제251조는, 신규참여사업자가 기존 사업자의 시설을 이용하여 서비스 제공을 함으로써 그들 사이에서의 경쟁을 촉진하기 위한 상호접속에 관한 규정이다.

동조(a)항에서는 모든 정보통신사업자에게 다른 정보통신사업자와의 상호접속이 의무화된다. 동조(b)항에서는 지역정보통신시장으로의 경쟁도입을 위해, 모든 지역정보통신회사에 대해서 자기의 시설을 재판매함을 의무화하고 있는 것이다. 동조(c)항에서는 ILEC에 대해서 그 소유하는 접속시설을 CLEC에 개방, 즉 요소별 분리접속의무(3호)를 비롯하여, 상호접속을 적절한 조건 하에서 비차별적으로 할 것(2호), 도매가격으로 재판매할 것(4호) 등을 의무화하였다.

요소별 분리접속의무를 직접 규정하고 있는 것이 바로 위 동조(c)항이다. 그에 더하여 자기의 네트워크와 거기에 접속을 바라는 모든 타 사업자의 설비·기기 사이에서 전화교환서비스 내지 교환 접속의 전송 및 라우팅을 위해, 기술적으로 가능한 모든 포인트에서, 적정하고·합리적이면서 **차별없는 조건**으로 자기 사용과 동등한 품질에서의 상호접속을 추가적으로 의무로 하고 있으며(251조(c)항(2)호), 동시에 이들 기존 사업자에게는 타 사업자 간에 상호접속 교섭에 성실하게 임하여야 하는 의무(동1호), 개별 망의 기능・망의 구성요소를 요소별로 분리접속하여 제공하여야 하는 의무(동3호), 타사업자에 대한 전기통신서비스의 도매가격으로의 재판매의무(동4호), 콜로케이션(타사업자의 국 내 등에 교환기 등 설치)의 의무(동6호)등도 규정하고 있다. 또한 BOCs(AT&T 분할로 독립한 지역전화회사로서 ILECs)에는 또한 사업자 간 공정·대등을 유도하기 위한 법정 경쟁체크리스트(271조(c)항(2)호B)를 충족하는 의무 등이 부가되고 있다. 동항은 ILEC의 경쟁상대인 CLEC에 대해서 ILEC가 소유하는 시설에 접속시킬 의무를 규정하고 있다.

동법 제251조(d)항(2)호에서의 두 가지 판단기준의 구체적인 내용과 경쟁법과의 사이의 관계에서는 다음의 ① 요소별 분리접속 의무의 존부, ② 분리접속의무의 대상이 되는 통신망 요소(network elements)의 의미, ③ 서비스 제공능력 저해의 고려요소 및 입증방법(이 점이 특히 경쟁법과 관련성을 갖는다), ④ 접근 필요(necessary)의 해석방법이 중요하다. 그리고 어떤 경우에 요소별 분리접속의무가 ILEC에 부과되

는지에 관해서, 동조(d)항은 UNE(Unbundled Network Elements: 접속의무의 대상이 되는 요소별 네트워크 시설)의 판단에 있어, CLEC가 사업 활동을 할 때, ILEC의 보유 시설을 이용하지 않으면 해당 사업 활동을 할 수 없는 경우, 그 시설이 필요한지, CLEC가 이용할 수 없는 경우에 ILEC가 보유하는 시설을 개방해야 할 의무를 지는지를 묻고 있다.[42] 위 제251조(c)항(3)호과 251조(d)항(2)호는 모든 ILEC에 대해서 적용되는 것이 전제가 된다.

「96년 법」에서는 ILEC와 CLEC 쌍방에 의해 전미 지역정보통신과 장거리 정보통신 양시장에서의 경쟁 도입을 꾀하고, 또한 CATV 사업자에 의한 정보통신시장으로의 참여를 촉진시켰다. 그 결과 1997년부터는 특히 지역정보통신시장에 이르기까지의 일정한 시설 베이스에서의 투자나 경쟁이 행해지고 있으며, 다양한 정보통신서비스가 제공되고 있다.

4) 수요자 시장별 규제

정보통신시장이 확대되면서 제공되는 수요자시장은 기업시장(enterprise market)과 가정용시장(mass market)으로 구별할 수 있다. 이는 각각의 시장에서 정보통신서비스를 제공하고 있는 사업자가 차지하는 비율이 다르다는 점에서 규제 틀을 파악하는데 중요하다.

기업시장은 정보통신서비스의 수요처가 대규모의 고객, 주로 기업을 대상으로 한 시장이다. 1980년대 중반부터 ILEC의 지역망 시설을 이용하여 사업자에게 서비스를 제공해 온 CLEC가, 「96년 법」제정 이후에도 해당 시장에서 일정한 지위를 갖고 있는 것이 특징적이다. 이는 CLEC가 서비스를 함에 있어서 필요한 시설을 소유하고 있는데다가, ILEC의 요소별 접속의무에 의해 서비스 제공이 한층 용이해졌기 때문이다. 최근 특히 xDSL이나 광섬유에 의한 사업자에게 제공하는 고속 대용량 서비스에 있어서 기업시장의 확대에 동반하여 ILEC가 그 수익을 대폭 증가시키기도 하였다. 기업시장에서 대용량의 정보통신이 가능한 루프는 요소별 분리접속의무에서 제외된다. 또한 ILEC 이외의 복수

42) 외국의 전기통신분야에서의 시장지배적 지위의 남용규제 등에 관한 조사, 2013.7.10

의 사업자가 회선의 도매가 가능한 경우, 또는 사용자에게 직접 회선을 제공할 수 있는 경우 요소별 접속의무가 면제된다.

가정용 시장은 정보통신서비스의 대상이 일반가정용인 시장이다. 「96년 법」제정 이전에 이 시장에서 서비스를 제공하고 있는 사업자는 독점적 서비스제공사업자이기도 했다. 위 법 제정 후, 많은 CLEC가 일반 가정용 정보통신서비스를 제공하기 시작하였다. 특히 최근에는 인터넷의 대규모 보급에 의해 브로드밴드 서비스가 주목되는 가운데, 일반가정용 정보통신서비스에서의 경쟁이 활성화 되고 있다. 현재는 대부분의 xDSL서비스 제공 주체인 사업자는 ILEC로 요소별 분리접속의무의 대상이 되는 시설은 ILEC가 단독으로 사용하고 있는 내로우밴드(narrowband: 협대역) 및 브로드밴드(broadband: 광대역) 서비스 제공을 위한 동선 루프와 서브 루프이다.

5) 보편적 역무의 확보

「96년 법」은 FCC에 폭넓은 규제의 재량을 허용하고 있다. 사업자에는 ILEC와 CLEC 두 종류가 있는데, FCC의 규제는 CLEC가 지역 통신시장을 진입하는데 있어서 시장지배적인 ILEC에 피해를 당하지 않도록 보호하기 위한 것으로, ① ILEC는 최소한 자사에 제공하는 품질에 상당하는 수준의 상호접속을 CLEC에 제공해야 하며, 조건이나 가격 등이 차별적이어서는 안 되고, ② ILEC는 네트워크 요소(network elements)를 요소별로 개별적(unbundled)으로 팔아야 한다. 개별적으로 판매가 이루어져야만 CLEC가 해당 서비스를 구매한 후에 자체적인 브랜드 네임 하에서 재판매하는 것이 가능하기 때문이다.[43]

이처럼 「96년 법」은 ILEC가 CLEC를 위해서 UNE를 사용할 수 있게 하도록 해야 한다고 규정하고 있다. 즉, 기존사업자가 경쟁신규사업자에게 특정 망 요소를 의무적으로 빌려주도록 한 것이다. 동법 제251조(c)항(3)호(요소별 접속)는 UNE를 "경쟁사업자가 전기통신서비스를 위해 통신망설비의 임대를 요청하는 경우, 기술적으로 가능한 모든

43) Legg, Michael J., "Telecommunications Access Pricing and Regulator Accountability through Administrative Law and Takings Jurisprudence," *Federal Communications Law Journal*, Volume 56, Issue 3. 2004.

곳에서의 세분화된 통신망 요소에 대한 비차별적인 접속을 공정하고 합리적인 제공 대가에 기초하여 경쟁사업자에게 제공해야 할 기존 사업자의 의무"로 규정하고 있다. 또한 「96년 법」은 FCC가 어떠한 UNE가 CLEC에게 제공되어야 할지를 정할 권한도 주고 있다.[44]

6) 광대역 통신망 규제

1990년대 말, 브로드밴드 서비스에 대한 요구가 높아지는 가운데, 케이블 모뎀 서비스의 일반 보급이 시작되면서, 케이블 회선망을 보유한 브로드밴드 케이블 사업자의 강한 경쟁력에 대하여 비계열 ISP가 축출되는 것에 대한 불안이 지적되었고, 케이블 사업자의 '오픈 액세스(open access)'를 요구하는 목소리는 '마지막 1마일의 투쟁(battle for the last mile)'이라는 표현으로 여론의 주목을 받았다.

미국에서의 브로드밴드정책은 케이블 사업자가 제공하는 케이블 모뎀을 사용하는 브로드밴드 인터넷 서비스, 즉 '케이블 모뎀 서비스'에 대한 규제를 통해 발전해 왔다.[45] '케이블 모뎀 서비스'란, 케이블 사업자에 의해 보유된 '전송로'인 케이블 회선망을 경유해서 제공된 '인터넷 서비스'를 의미한다. 케이블 회선망은 원래 한방향의 '다채널 비디오 프로그램 배선(Multichannel Video Programming Distribution: MVPD)' 서비스로서 '케이블 서비스'를 제공하는 목적으로 설비되었으나, 그 후 쌍방향의 회선 교환형의 전화서비스를 제공하는 목적으로 사용되었다.

케이블 모뎀 서비스는 일반적인 '인터넷 서비스 제공자(Internet Service Provider: ISP)'에 의해 종래부터 제공되어왔던 ISP 서비스를 포함한다. 그러나 그것은 대부분의 경우에 있어서 전송로인 케이블 회선망을 경유하는 인터넷에서의 물리적인 접속 및 데이터 전송이라는 구성요소를 포함한다.

케이블 모뎀 서비스를 제공하고 있는 케이블 사업자가 「통신법」

44) FCC는 7가지 UNEs(local loop, network interface device, local and tandem switching, interoffice transmission facilities, signaling networks and call related databases, operations support systems, operator services and directory assistance)가 제공되어야 한다고 정했다.

45) 최근 미합중국에서의 케이블 모뎀을 경유하는 브로드밴드 인터넷 서비스에 대한 규칙을 둘러싼 의론에 대해서. 재론(再論) -National Cable & Telecommunications Assn v. Brand X Internet Services에서의 미합중국 최고재판소 판결을 중심으로-

제153(46)의 의미에서 전기통신을 '제공'하고 있는지는, 최종 사용자에게 제공된 기능의 성질에 의해 결정된다. 소비자의 시점에서 당해 서비스의 케이블 회선이 통상의 언어 메시지를 컴퓨터 처리 또는 메시지의 축적을 행하지 않고 '있는 그대로' 전송하거나 수신하는 목적이 아니라, '월드 와이드 웹'(World Wide Web: WWW) 등에 접속하는 목적으로 사용되고 있는바, 케이블 모뎀 서비스는 정보서비스의 범주에 '통합되는' 성질을 가지고 있고, '독립형'(stand-alone)으로 '있는 그대로' 전기통신을 제공하는 것은 아닌 것이다.[46)]

케이블 모뎀 서비스를 제공하는 케이블 회사의 케이블을 사용한 인터넷 서비스가 「96년 법」에서 통신서비스인지 정보서비스인지가 문제가 되는데, 전자는 기본적 서비스로서 규제가 있고, 후자는 첨단 서비스로서 규제가 없기 때문이다. 가령 브로드밴드 서비스 사업자인 xDSL서비스 사업자는, 정보를 축적하여 소비자에게 제공하는 사업을 하고 있으므로, 통신서비스를 이용하나 정보서비스라고 보아야 할 것이고, 그렇다면 해당 사업자는 재판매 의무, 요소별 접속의무를 지지 않게 된다.

법원은 AT&T와 Portland시 사건에서 케이블 사업자는 케이블 모뎀 서비스를 최종사용자에게 제공하기 위해서 전기통신을 사용하는데 지나지 않고, 전기통신 서비스는 제공하고 있지 않다고 판단했다. 그리고 당시 제공되고 있던 케이블 모뎀 서비스를 케이블 서비스가 아니라, 각 주(州) 사이의 정보서비스로써 분류하는 것이 적절하고, 분리해서 제공되는 전기통신서비스는 존재하지 않는다고 결론지었다. 그 결과 케이블 사업자는 케이블 모뎀 서비스를 제공하는 범위에 있어서는 기간통신사업자를 규제하는 「연방통신법」 제2편이 아니라, 동법 제1편 아래에서 보다 완화한 규제에 따라서, 특히 법에 규정된 요건 하에서만 자신의 네트워크를 경쟁사에 개방하는 의무를 지게 되었다. 또, 동법 제6편 아래에서 규제된 케이블 모뎀 서비스와는 달리 지방정부의 감독권한에는 따르지 않게 되었다.

법원의 입장은 정부 주도에 의한 사업법에 근거한 '오픈 액세스' 의

46) 케이블 모뎀 서비스를 제공하는 케이블 회사가 그 제공에 대해 데이터전송을 포함하는 최종 제품을 구성하는 분리된 구성요소를 사용하는 것이라고 하더라도, 최종 제품인 인터넷 서비스를 제공하고 있는 것이라고 판단하는 것이 가능하고, 이렇듯 기능적으로 통합된 구성요소인 전송부분이 분리되어 제공된다고 표현할 필요는 없는 것이다.

무가 브로드밴드시장에서의 경쟁을 왜곡하고, 기술혁신을 정체시킨다는 것이다. 현재의 브로드밴드 서비스 제공에 관련된 모든 플랫폼 간 경쟁이 활발한 상황을 고려하면, 오픈 액세스 자체가 브로드밴드 서비스 제공을 위한 인프라 및 콘텐츠에 대한 투자경쟁을 손상한다는 이해가 근저에 있다. 그러나 이러한 견해는 역으로 CATV시장을 포함한, 브로드밴드 서비스 제공에 관련된 전 플랫폼 사이에서의 접속의무를 약화하여 경쟁저해의 우려를 낳았다. 이에 대한 대안으로, 현재 「96년 법」이 규정·규제하고 있는 CATV나 ILEC, 위성통신, 무선통신 등 사업자별 규제가 아니라, 업종 종단적으로 정보통신산업을 수정함으로써, 플랫폼인 물리층을 중립적(neutral)으로 개방의무를 부과하고, 그 위에 있는 층의 시장에서의 경쟁을 촉진·유지시킬 것이 주장되고 있다.

2. 미국 사업법 적용의 구체적 사례

가. 공익독점시대 하의 사례

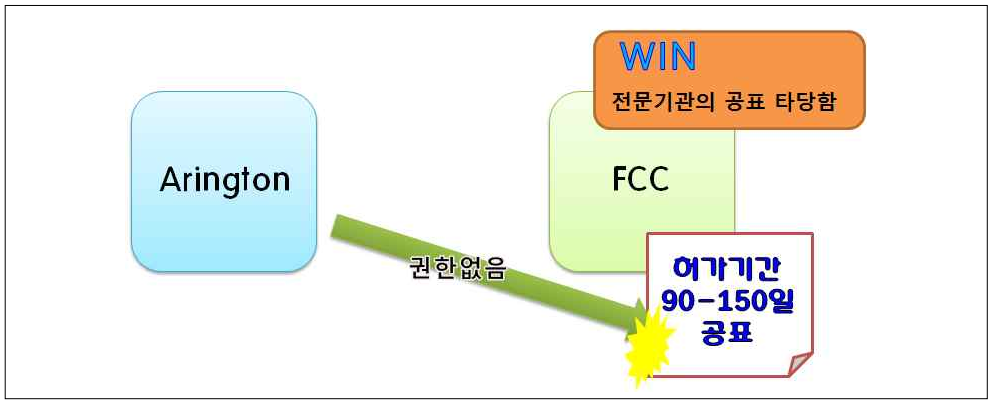
[표 4] 공익독점시대 하의 사례 요약

소의종류	사안	청구취지	청구원인	판결의 요지
행정	Arlington v FCC	FCC가 정한 규정의 무효 확인 청구	피고에게「연방통신법」제322조의 상당한 기간을 정할 권한이 없다.	FCC가 해당법령이 허용하는 한도에서 자발적으로 해석하는 것을 허용한다(청구기각).
민사	NCTA v Gulf Power	전신주 부착물 설치 허가 청구	전력회사인 피고는 FCC의 관할에 속하는 부착물들을 전신주에 설치하는 것을 허가하여야 한다.	FCC의 관할권은 점차 확대되어가고 있는바, FCC가 규제하는 전신주 부착물은 종래 케이블TV회사의 부착물에 한하지 않는

				다(청구인용).

1) Arlington시 대 FCC 사건

[그림 14] Arlington v. FCC 사건 개요



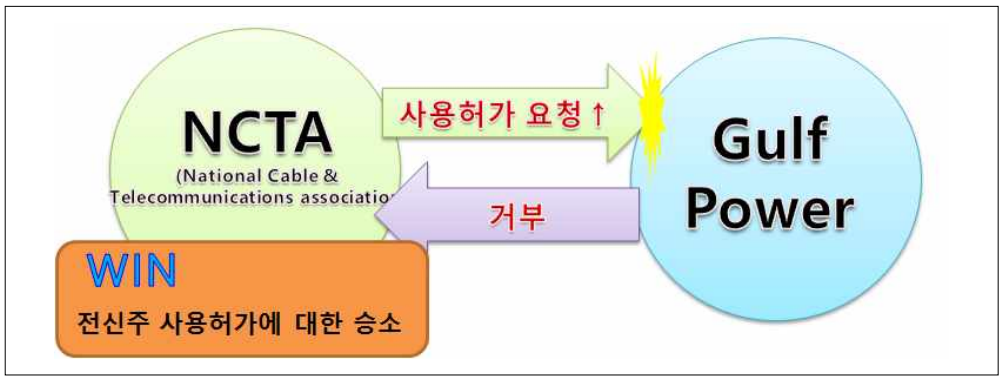
본 사안은 FCC와 지방정부 사이의 기관관할 소송으로, 알링턴 시가 FCC의 설비허가 기간이 지나치게 짧다는 것을 이유로 규정의 무효를 확인하고자 한 것이다. 무선 통신 산업에 필수적인 이동전화 기지국과 안테나 설비를 갖추기 위해서는 지방 정부 당국의 허가가 필요한데, 「연방통신법」 제332조가 '지방 정부 당국은 상당한 기간 내에 설비허가를 해야 한다'고 명시하고 있을 뿐 명확한 기간은 설정 하지 않고 있는데 대하여, FCC가 90일에서 150일 사이가 원칙적으로 상당한 기간에 해당된다고 공포하자, 알링턴 시가 이에 반발하여 위 소송을 제기하여 FCC에게 합당한 기간이 얼마인지 설정할 권한은 없다고 주장하였다.

이에 연방대법원은 "FCC가 해당 법령을 허용하는 한도 내에서 자발적으로 해석하는 것을 허락한다"는 취지로 판시하였다. 대법원은 FCC가 스스로의 관할권을 해석하는 권한 행사를 통하여 문제에 대한 결정을 내릴 수 있다고 설명하였다.[47]

47) City of Arlington, Texas v. Federal Communications Commission

2) 전미케이블통신연합(NCTA) 대 Gulf 전력회사 사건

[그림 15] 전미케이블통신연합(NCTA) v. Gulf Power 사건 개요



본 사안은 정보기술서비스 산업의 규제분류 문제가 연방대법원까지 간 최초의 사례로, 원고인 전미케이블통신연합(National Cable & Telecom munications Association: NCTA)이 Gulf Power를 상대로 전신주에 부속물 부착 허가를 구하는 소송을 제기하여 승소한 사안이다. 「통신법」의 개정법의 일부로 도입된 1978년「전주부착법」(Pole Attachments Act: PAA)은 FCC에 공익기업(public utility company)이 소유하고 있는 전신주에 설치되는 부착물(attachments)의 요금 및 조건 등의 규제권을 주었다. 이는 당시 소비자들 사이에 인기리에 퍼지고 있던 케이블 TV 회사를 전신주 소유 회사의 독점적인 가격설정으로부터 보호하기 위함이었다.[48]

첫 PAA가 통과되었을 당시에는 FCC가 규제권을 가진 부착물로는 케이블TV회사의 부착물이 유일했다. 그러나 「96년 법」 개정과 함께 FCC의 관할권이 유선기반 통신서비스까지 확대되었고, 1998년 PAA 개정법이 FCC에 초고속 인터넷 접속, 종래의 케이블 TV의 복합서비스, 무선 통신서비스 관련 부착물까지도 규제할 수 있는 권한을 주었다.

미 연방대법원은 FCC 관할권의 확대가 추세임을 강조하면서 FCC의 손을 들어주었다. 위 Gulf Power 사건은, FCC의 광범위한 규제권을 인정한 사례로 이로 인하여 소비자는 초고속 인터넷 접속 및 각종 정보서비스를 보다 저렴하게 이용할 수 있게 되었다. 사실 케이블 회사,

48) Deltorto, Darci, "Pole Position: National Cable & Telecommunications Association v. Gulf Power Co. and the Implications of the FCC's Pole Attachments Act Reaching Higher Ground", *Akron Law Review*, Vol. 37. 2004. pp. 87-129.

전기통신회사, 인터넷 회사를 구분하는 것은 갈수록 어려워지고 있고, 새로운 분야가 지속적으로 생기기 때문에, 의회가 일일이 이에 맞춰 법안을 수정하는 것은 무의미하며 위 Gulf Power 사건의 결정으로 FCC는 '공정하고 합리적인'(just and reasonable) 범위 내에서 전신주에 부착물을 설치하고자 하는 어떠한 종류의 서비스 제공자라도 규제할 수 있게 되었다.

이처럼 PAA는 네트워크의 구축을 용이하게 하고, 보편적 역무에 기여하였다. 즉, 다양한 사업자의 참여를 보장하고, 그에 의해서 소비자에게 풍부한 서비스의 제공을 가능하게 하는 규제적 틀을 구축하는 기반으로 자리매김하였다.

나. 수정최종판결(MFJ)체제 하에서의 사례

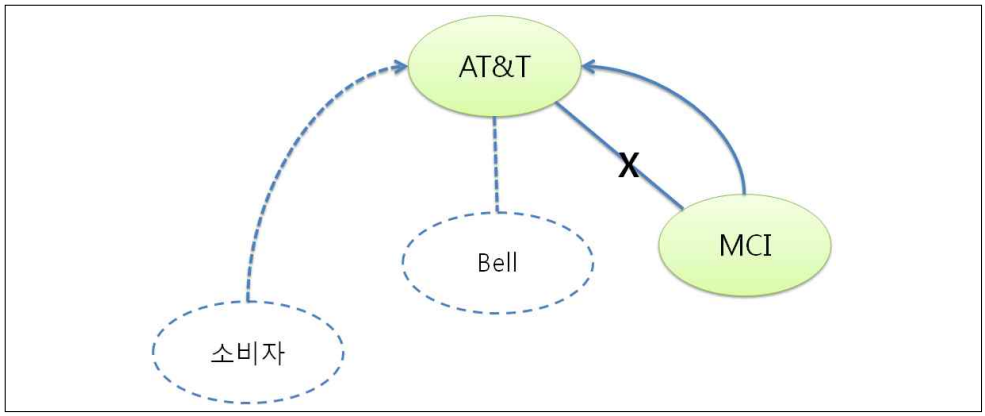
[표 5] MFJ 체제 하의 사례 요약

소의 종류	사안	청구취지	청구원인	판결의 요지
민사	MCI v. AT&T	원고가 피고의 시내 통신망으로 접속할 수 있도록 허용할 것을 청구	시내통신망을 필수설비로, 이를 보유하고 있는 피고는 이에 대한 접속을 허용할 의무가 있다.	피고는 필수설비인 시내 통신망으로의 접속 의무를 이행하라(청구인용).
행정	AT&T v. FCC	FCC의 비대칭적인 요금신청 규제에 대한 취소를 청구	FCC가 AT&T 에 대해서만 「통신법」상의 요금 신청에 대한 규제를 부과하는 것은 위법이다.	「통신법」에서 정하는 요금 신청에 관한 규제를 비대칭적으로 유보하는 것은 위법 이다(청구인용).
민사	Marco Supply v. AT&T	등록된 표준약관상의 통신요금 지급의무의 부존재 확인을	AT&T가 고객유치를 위하여 등록표준약관보다 낮은 요금을 책정하였는	등록된 표준약관이 당사자들의 개별적인 계약보다 우선하

		청구	바, 위 약관상의 요금을 지급 할 의무가 없다.	여 적용된다(청구기각).
민사	TCI Mail v. MCI	원고는 피고가 주장하는 통신요금이 부당하다고 청구	피고가 개별 계약의 내용과 달리, 등록 표준약관 상의 가격조건에 의한 통신요금을 청구한 것은 부당함.	등록 표준약관 상의 가격조건은 그 적법성이 추정되므로, 원고는 피고가 청구하는 통신요금을 지급할 의무가 있다(청구기각).
민사	Wegol and Ltd v. NY NEX	피고가 수령한 통신요금에 대하여 부당이득에 의한 반환을 청구	피고가 등록 표준약관 상의 가격기준에 의해, 소비자들에게 비싼 가격에 통신 서비스를 제공하고 그 요금을 수령한 것은 부당이득에 해당함.	등록 표준약관 상의 가격기준은 그 적법성이 추정되므로, 그에 기하여 수령한 통신요금은 부당이득에 해당하지 아니 한다(청구기각).
민사	CCI v. AT&T	피고의 불법행위에 대한 손해배상을 청구	피고의 장래 고객에 대한 고의적인 방해, 계약방해 등의 행위(practice)는 불법행위이므로 그 손해를 배상하여야 한다.	인가약관 적법성 추정의 원칙은 요금 기준에 적용 될 뿐, 그 행위에는 적용되지 아니하는 바, 위 원칙을 이유로 피고의 행위가 적법하다고 할 수 없다(청구인용).

1) MCI 대 AT&T (1983) 사건

[그림 16] MCI v. AT&T 사건 개요



본 사안은 신흥 장거리전화사업자 MCI가 AT&T가 보유한 시내통신망으로의 접속을 구한 민사소송이다. MFJ 체제에서 가장 중요한 사업법 상 규제는 상호접속 규제로서 기간통신사업자에 대하여 재판매를 의무화하고, 접속에 있어서의 차별을 금지하는 것을 골자로 한다.

이에 의하면 ① 독점적 사업자인 AT&T가 필수 설비인 시내통신망을 보유하고, ② 경쟁자인 MCI가 실제상 또는 합리적으로 해당 시설을 조달할 수 없으며, ③ MCI에 대해서 AT&T가 시내통신망으로의 접속을 거절하였고, ④ 시내통신망을 공동이용이 실제상 가능한 것이므로, 법원은 원고 승소 판결을 통하여 피고는 필수설비인 시내통신망으로의 접속의무를 이행하라는 판결을 명하였다.

2) AT&T 대 FCC 사건

[그림 17] AT&T v. FCC의 사건 개요

본 소송은 AT&T가 FCC를 상대로 비대칭규제 처분의 취소를 구한 행정소송이다. 「연방통신법」 Section 203(a)에 따르면 모든 전화회사는 FCC에 요금표를 제출하고 인가를 받기 위해 요금, 규정, 조건 등 모든 정보를 공개해야 하는데, 1979년 FCC는 이 요건이 전화회사에 부담을 줄 수 있다는 점을 인지하고 규제완화를 위하여 요금을 불합리하게 높거나 낮게 책정할 수 있는 시장지배력이 부족한 비지배적 사업자에 한해서 요금표 인가 규칙을 간소화하고자 하였다.[49]

이에 따라 FCC는 AT&T를 제외한 모든 장거리 전화회사가 시장지배력이 부족한 비지배적 사업자라고 판단하고, MCI, Sprint 등 비지배적 사업자로 분류된 장거리 전화회사는 간소화된 요금표 인가 규제를 받도록 하였다. FCC는 비지배적 사업자에게까지 지배적 사업자와 동일한 수준의 규제를 적용한다면 서비스 혁신을 저해하고, 가격 경쟁을 막으며, 담합을 부추기게 된다고 믿었다.[50] 그러나 FCC는 비지배적 사업자가 간소화된 규제를 받는다고 해서 「통신법」의 다른 조항으로부터 자유로워지는 것은 아니라는 점을 강조했다. 즉, section 201(b)의 불합리한 요금 책정 금지나 section 202(a)의 불합리한 차별행위 금지 등은 앞으로도 모든 회사에 적용된다는 것이다.

그러나 이에 대하여, 미 연방 DC 순회항소법원(Court of Appeals for

49) May, Randolph J. and Richard S. Whitt, "Permissive Forbearance," *Policy Impact, Communications Lawyer*. Summer 1993.
50) 실제로도 많은 통신 시장 전문가들은 비지배적 사업자에 대한 요금표 인가 규제완화가 가격하한, 보다 융통성 있는 서비스 제공, 장기 요금 안정 등 긍정적인 효과가 있었다고 본다.

the D.C. Circuit)은 1992. 11. 13. FCC가 AT&T를 제외한 장거리 전화회사에 요금표 인가 규제를 완화하는 것(permissible forbearance), 즉 FCC가 「통신법」상 정해진 요금의 신청을 AT&T에만 부과한 것은 위법이라고 판단하였다. 이로 인하여 모든 전화회사는 FCC가 인가한 요금, 규정 및 조건에 의해 서비스를 제공해야 하며, 「통신법」에서 정해진 요금의 인가를 면제하는 것은 부당하다는 원칙이 확립되었다.

3) Marco Supply 대 AT&T 사건[51)]

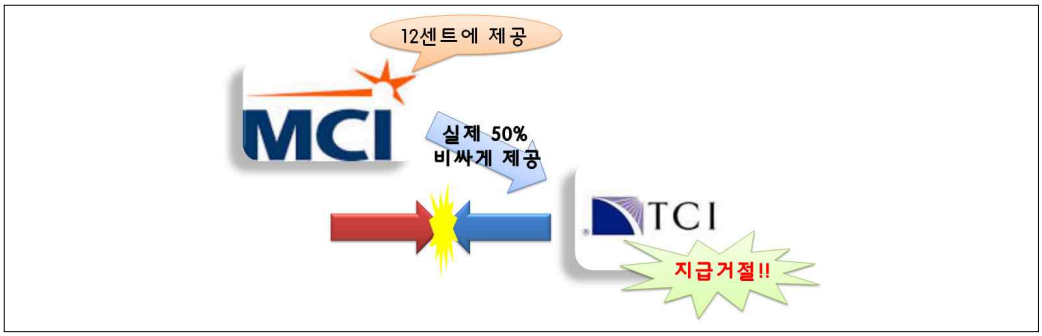
[그림 18] Marco v. AT&T 사건 개요

본건은 Marco가 AT&T에 대하여 등록된 표준약관 상의 통신요금 지급의무의 부존재 확인을 청구한 민사소송으로, 법원은 위 표준약관과는 별개로 AT&T가 고객유치를 위하여 등록된 표준약관보다 낮은 요금을 책정하여 통신서비스 제공 계약을 체결하였다는 점에 관한 입증이 없다고 판단하였다. 이 판결은 통신서비스 제공계약의 경우 당사자 사이의 개별계약에 앞서 "통신위원회에 등록된 표준약관의 조건이 우선한다"는 「통신법」을 근거로 한 '인가약관 적법성 추정원칙'을 재확인한 것으로, 이용 약관에 정해진 등록요금에 적법성을 부여한 것은 사업자가 이용자를 유인하기 위하여 부당하게 낮은 요금을 책정하는 것을 금지함으로써 공정 경쟁을 유인하기 위한 목적으로 제정된 것이다.

51) 875 F.2d 434(4th Cir. 1989)

4) TCI Mail 대 MCI 사건[52]

[그림 19] TCI Mail v. MCI 사건 개요



① 본건은 TCI Mail(이하 'TCI')이 MCI에 대하여 피고가 청구한 요금이 부당하다고 주장한 사안에 대하여 법원이 청구를 기각한 민사소송이다.[53] MCI는 세계적인 장거리 전화회사이고, TCI는 모금 전문 컨설턴트로 자선단체와 시민단체를 대표하는 회사인데, TCI가 전화 마케팅 센터에서 사용할 장거리 전화 회사를 물색하자, MCI는 TCI가 MCI를 사용하게 되면 장거리 전화 요금이 분당 평균 12센트에 불과할 것이라고 약속을 했다. 이에 그 수치를 사용해서 재무계획을 세운 TCI는 여러 장거리 전화회사 가운데서 MCI를 선택하였는데 막상 청구된 요금은 약속되었던 금액보다 50%이상 비싸서 TCI의 전화마케팅센터가 수익을 내지 못하게 되었다. 결국 TCI는 MCI에 대하여 요금을 지불하지 않았고, 1991년 3월 MCI가 위 요금 $80,774.39와 이자를 청구하자 'TCI가 MCI의 이러한 요금청구가 부당하다고 주장하며 소송에 나서게 된 것이다.

법원은 계약이 성립할 당시 FCC에 제출된 등록가격조건이 적용되어야 하며, 이 등록가격조건은 이용자들이 "불공정하고 불합리한" 차별을 받지 않게 하려는 것이므로 그 적법성이 추정된다고 하면서, TCI는 위 등록가격조건에 의한 MCI의 청구요금을 지급할 의무가 있다고 판시하였다.

52) 772 F. Supp. 64 (D.R.I. 1991)
53) 실제로는 MCI가 TCI를 상대로 인가약관에 의한 전화요금을 청구한 사안이나(772 F. Supp. 64 D.R.I. 1991), 사업법 적용의 민사소송에 있어 당사자가 통신사업자 행위의 위법성을 입증하는 것이 매우 어려워 승소하기 어렵다는 본고의 논지를 명확히 하기 위하여 위와 같이 구성한다.

5) Wegoland 대 NYNEX 사건[54]

[그림 20] Wegoland v. NYNEX 사건 개요

본건은 Wegoland가 NYNEX에게 지급한 통신요금이 부당이득에 해당하여 반환을 구하는 민사소송으로, 법원은 인가요금을 수령한 것이 부당이득에 해당되지 않는다고 하여 원고의 청구를 받아들이지 않았다. 원고는 모회사인 NYNEX가 NETel(New England Telephone and Telegragh Co.) 등 여러 자회사에 상품 및 서비스를 의도적으로 비싼 가격에 공급했고, NYTel과 NETel은 그 가격을 바탕으로 소비자에게 비싼 값에 서비스를 제공하는 것을 정당화했는데 NYTel과 NETel 등이 모두 NYNEX의 계열사이기 때문에 NYNEX는 소비자를 착취해 부당이득을 올렸다고 주장하며 위 소를 제기하였다. 이에 대해 피고는 NYNEX의 가격정책은 '인가약관 적법성 추정 원칙'에 의해서 보호받는다고 주장하였는데, 법원은 인가약관 적법성 추정의 원칙은 소제기를 막으며, NYNEX가 인가요금을 수령한 것은 부당이득에 해당하지 아니한다고 판시하였다.[55]

54) 27 F. 3d 17
55) 同旨, Maislin Indus. U.S. v. Primary Steel, Inc., 497 U.S. 116, 135(1990)

6) Cooperative Communications, Inc.(CCI) 대 AT&T 사건[56]

[그림 21] CCI v. AT&T 사건 개요

1989년 Edwin B. HerrNeckar와 Ann Smith HerrNeckar는 Cooperative Communications, Inc.(CCI)라는 모집회사를 세웠다. 본 건은 CCI가 AT&T를 상대로 CCI의 영업을 방해한 불법행위에 대한 손해배상을 청구한 민사소송이다. 당시 AT&T는 대량의 장거리 전화 서비스를 할인된 가격에 파는 마케팅을 하고 있었는데, 모집인(aggregator)이라고 불리는 회사들이 AT&T로부터 장거리 전화 서비스를 할인된 가격에 대량으로 구입하여 자신들이 산 이 장거리 전화 서비스의 소량을 필요로 하는 개인이나 기업에 파는 형태의 거래가 이루어졌다. 이러한 거래는 소량을 필요로 하는 개인이나 기업이 AT&T로부터 직접 장거리 전화 서비스를 구매하는 것보다 저렴한 가격에 구매할 수 있었기 때문에 윈-윈(win-win)이 가능했다.

CCI의 설립자인 Edwin B. HerrNeckar는 AT&T 솔트레이크 사무실의 직원이었는데, CCI의 설립 직후 AT&T는 자신을 해고하고, 의도적으로 CCI의 고객에게 접근하여 CCI가 장거리 전화 서비스를 제공할 능력이 없다고 하는가 하면, CCI 고객의 기밀 청구서 정보 등을 빼내어 CCI의 고객층을 파괴하는 등 지속적으로 CCI를 폐업시키려는 시도를 하였다고 주장했다.

이 사건에서 원고는 피고의 위와 같은 행위가 ① 장래의 고객에 대한 고의적 방해(intentional interference with prospective economic relations), ② 계약방해(interference with contract), ③ 사업비난

56) U.S. District Court for the District of Utah, Central Division, 31 F. Supp. 2d 1317; 1999 U.S. Dist. LEXIS 430; 51 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 157

(business disparagement), ④ 신의성실과 공정거래 원칙 위반(Breach of the covenant of good faith and fair dealing), ⑤ 불공정경쟁(Unfair competition), ⑥ 유타주 통일영업비밀법 위반(Violation of Utah Uniform Trade Secret Act) ⑦ 연방통신법 위반(Violation of the Federal Communications Act), ⑧ 랜햄법 위반(Violation of the Lanham Act)에 해당한다고 주장하였다.

법원은 '인가약관 적법성 추정 원칙'이 요금 기준에는 적용되지만, 행위(practice)에는 적용되지 아니하는 것인바, AT&T의 위와 같은 행위는 동 원칙의 대상에 포함되지 아니하므로 위 원칙을 이유로 피고의 행위가 적법하다는 판단을 받을 수는 없다고 판시하였다.

다. 「통신법(Telecommunications Act of 1996)」적용의 사례

[표 6] 1996년 통신법 하의 사례 요약

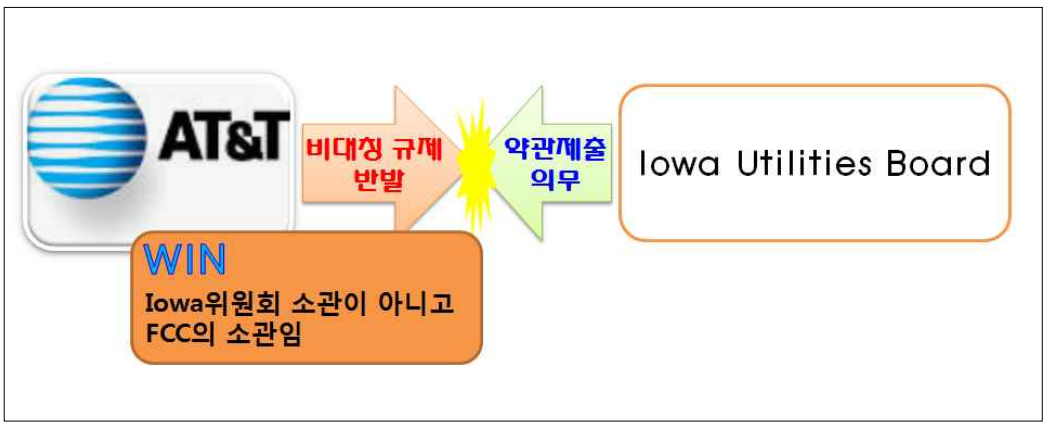
소의 종류	사안	청구취지	청구원인	판결의 요지
행정	AT&T v. Iowa Utilities Board	피고가 부과한 시내상호접속 약관 제출명령에 대한 취소 청구	시내 상호접속 의무의 이행은 주 정부의 소관이 아니다.	「96년 법」상 시내경쟁규정을 집행하는 일반적인 권한은 FCC가 갖는다(청구인용).
행정	Verizon v. FCC	피고의 상호접속요금 시정권고의 취소를 청구	피고가 가상적인 네트워크를 전제로 하는 장기증가비용방식(TELRIC)을 사용하여 비용을 산정, 권고하는 것은, 경영상의 침해에 해당한다.	TELRIC이 원고의 재정건전성을 위태롭게 하였거나, 투자자들에게 적절한 보상을 하지 아니하여 몰수에 해당한다고 볼 수 없고, 위 접속요금 산정방식이 합리적이지 않

				다고 결론지을 수 없다(청구기각).
행정	U.S. Telecom Ass'n v. FCC	피고가 각 주에 UNE 사용료 책정 책임을 위임한 것을 취소 청구	피고가 가이드라인을 통해 UNEs 제공을 정하고 각 주에 UNE 사용료를 정할 책임을 위임한 것은 망요소를 헐값에 팔도록 강요하는 것으로 위임할 권리가 없다.	가이드라인을 만든 것은 잘못된 것이 아니나, 주정부에 FCC의 결정을 따르도록 지시한 것은 잘못되었다(청구인용).
행정	AT&T v. Portland 시	피고의 케이블 방송 회선망에 대한 개방명령의 취소를 청구	원고가 TCI를 인수하는데 있어, 피고는 그 승인의 조건으로 오픈 액세스를 강제하는 조건을 채택할 권한이 없다.	케이블 모뎀 서비스는 그 법적 성질이 정보서비스에 해당하므로, 「96년 법」제1편에 의해서 FCC의 감독권한에 따라 보다 완화된 규제에 따르게 된다(청구인용).
행정	Comcast v. FCC	피고의 원고에 대한 차별적 네트워크 운영 실무 종요를 명하는 시정조치의 취소를 청구	Comcast가 일정한 소비자들의 P2P트래픽에 간섭한 행위에 대한 피고의 시정조치는 위법하다.	본건의 시정조치가 「96년 법」제1편의 관할권에 포함된다는 것에 대한 입증에 실패하였다(청구인용).
민사	Brand X v. NCTA	피고에 대하여 인터넷망 접속 의무의 이행을 청구	피고는 피고 소유의 동축케이블에 대하여 원고가 사용할 수	-법원은 케이블 회사 업무의 법적성질은 FCC가 결정한

			있도록 허락할 의무가 있다.	다고 판시하여 그 판단을 FCC에게 판단을 유보하였고, -FCC는 케이블회사는 정보서비스 산업에 해당한다고 보아, 경쟁자에게 동축케이블의 사용을 허락할 이유가 없다고 판시함(청구인 용).

1) AT&T 대 Iowa Utilities Board 사건

[그림 22] AT&T v. Iowa Utilities Board 사건 개요



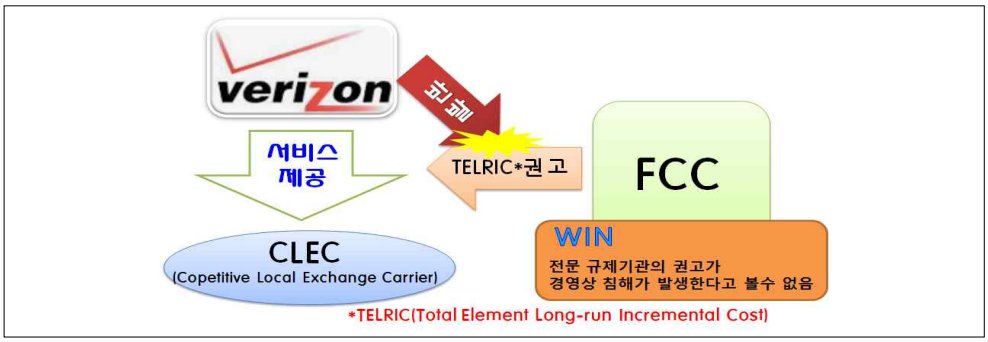
본 사안은 AT&T가 Iowa Utilities Board를 상대로 Board가 부과한 시내상호접속 약관 제출명령의 취소를 구한 행정소송이다. 연방대법원은 「96년 법」에 근거하여 **시내상호접속 의무의 이행은** FCC의 규제 권한이며, 주 정부의 소관이 아니라는 이유로 원고의 취소청구를 인용하였다. 법원은 위 판결에서 FCC는 지역경쟁을 달성하기 위하여 「96년 법」의 시내경쟁규정을 집행하는 일반적인 관할권을 갖는다고 판단하였다.

이에 따라 FCC는 ① 전미 정보통신시장에서의 경쟁의 조기도입, ②

시설베이스에서의 경쟁, 투자, 기술혁신의 촉진, ④ 규제완화 등을 고려하여 요소별 접속 의무의 판단기준을 강조하였다. 2001년 FCC는 '3개년 평가 규범제정안건'(Triennial Review NPRM)을 발표하였고,[57] 여기서는 요소별 접속 의무의 의미를 시설베이스 경쟁의 활성화로 삼고, 특히 브로드밴드 서비스의 제공에 관련된 ILEC와 신규참여자의 경쟁을 촉진함을 강조하였다.

2) Verizon 대 FCC 사건[58]

[그림 23] Verizon v. FCC 사건 개요



본건은 Verizon이 FCC를 상대로 상호접속요금 시정권고의 취소를 구한 행정소송이다. 법원은 FCC가 ILEC가 CLEC에 대해 시내 상호접속 및 UNE 접속 요금에 관해서, '가상의 효율적인 네트워크'(hypothetical most efficient network)를 전제로 하는 '장기증분비용'(total element long-run incremental cost: TELRIC) 방식을 채용하고 있는 것은 적법하다고 판단하여 원고의 청구를 받아들이지 않았다. FCC의 요금설정은 법률 상 가능한 범위에서 합리적인 결정을 한 것으로 추정되고, 요금설정방식의 결과 사업자에게 나타난 손해를 수용문제로 다룰 수 없다는 것이다.

FCC는 CLEC의 지역 통신시장 진입을 위해 시장지배적 사업자인 ILEC가 차별을 하지 않도록, 상호접속 및 UNE 접속 관련 요금의 설정 시 '미래가치반영 비용설정방식'(forward-looking economic cost-pricing

57) NPRM(notice of proposed rule-making, 규범제정안건)은 미 행정법에서 규칙 제정의 절차로서, 독립된 정부기관(independent agency)이 규제 혹은 규칙의 제정, 개정 등 변동이 있을 경우 의견청취를 위해 공시하도록 되어 있음.

58) FCC, "Verizon/MCI, Memorandum Opinion and Order," FCC 06-184 (2005); 535 U.S. 467(2002)

methodology)을 사용하여야 한다고 판단했다. 이 가격설정 방법은 총요소의 장기증가비용을 포함하는 것으로서 가상의 효율적인 네트워크를 가정하여, 다음의 네 가지의 합으로 가격이 계산된다. 즉, CLEC의 사용량이 직접 원인이 되는 비용, 네트워크 요소의 감가상각비용, 네트워크 생성에 투자한 비용, 인건비 등 간접비용이 그것이다.

미 연방대법원은, ① 비용이라는 단어 자체가 카멜레온과 같이 여러 가지를 의미할 수 있는 바, 역사적으로 규제기관은 요금설정 방식의 선택에 있어서 충분한 재량권을 보장받았고, ② 비용의 해석이 실제적이거나 역사적일 필요가 없는 것과 마찬가지로 문제가 되는 가상의 효율적인 네트워크 역시 실제의 네트워크일 필요가 없으며, ③ 1996년과 2000년 사이에 CLEC는 설비투자에 550억 달러를 사용하였는데, 이는 설비기반 경쟁이 줄어들지 않았다는 것이고, ④ TELRIC이 헌법에 위배되는지를 판단하기 위해서는 계산방식보다는 그것이 미친 결과로 판단해야 한다고 보았다. 즉, 법원은 TELRIC이 ILEC의 재정건전성을 위태롭게 했거나, 투자자들에 적절한 보상을 하지 못하여 몰수(confiscation)에 해당한다고 볼 수 없으며, 해당 접속요금 산정방식이 합리적이지 않다고 결론지을 수 없다고 판단한 것이다.

(3) U.S. Telecom Association 대 FCC 사건[59)]

[그림 24] U.S. Telecom Association v. FCC 사건 개요

본건은 ILEC가 FCC를 상대로 FCC가 가이드라인을 통해 7가지 UNEs를 제공할 것을 정하고, 각 주에 UNE 사용료를 정할 책임을 위임한 것에 반발하여 FCC가 위임할 권리가 없음을 주장하였다. 이와 관련하여 CLEC

59) 359 F.3d 554(2004)

는 FCC가 정한 UNE가 지역통신시장에 큰 도움을 주고 있다고 주장하는 반면, ILEC는 FCC가 자신들이 소유한 망 요소를 헐값에 팔도록 강요하는 것이라고 주장했다.

2004년 3월 2일, 미 연방 DC 순회항소법원은 FCC가 각 주에 UNE 사용료를 정할 책임을 위임할 권리가 없다고 판시했다. 법원은 FCC가 정부의 도움 없이는 지역전화시장에서 경쟁이 손상된다는 것을 증명하지 못했다고 판단했다. 여기서 주목할 점은 DC항소법원은 세 판사 모두가 FCC가 연방 가이드라인을 만든 것이 잘못된 것이 아니라 주정부에 FCC의 결정을 따르도록 지시한 것이 잘못되었다고 본 것이다.

워싱턴 DC 연방항소법원의 이 판결은, 우선 ILEC에 대한 요소별 분리접속 의무 완화를 인정한 것이다. 즉, 주의 공익사업위원회는 재량으로 요소별 접속의무를 발동할 수 없음을 확인하였다. 그 후 FCC는 해당 판결을 연방대법원에 상고함을 단념하였고, 파웰 위원장도 조기에 새로운 접속 규칙(access rule) 작성에 착수한다고 표명하였다.

4) AT&T 대 Portland시 사건

[그림 25] AT&T v. Portland시 사건 개요

본 소송은 AT&T가 Portland시를 상대로 케이블 방송 회선망 개방명령의 취소를 구하는 행정소송으로, 법원은 Portland시에게 개방명령을 부과할 권한이 없음을 이유로 원고의 청구를 받아들였다. 이는 AT&T가 당시 제2위 케이블 방송사업자였던 Tele-Communications, Inc.(이하 'TCI사')에 대한 매수 공표로부터 출발했다. 미국에서는 케이

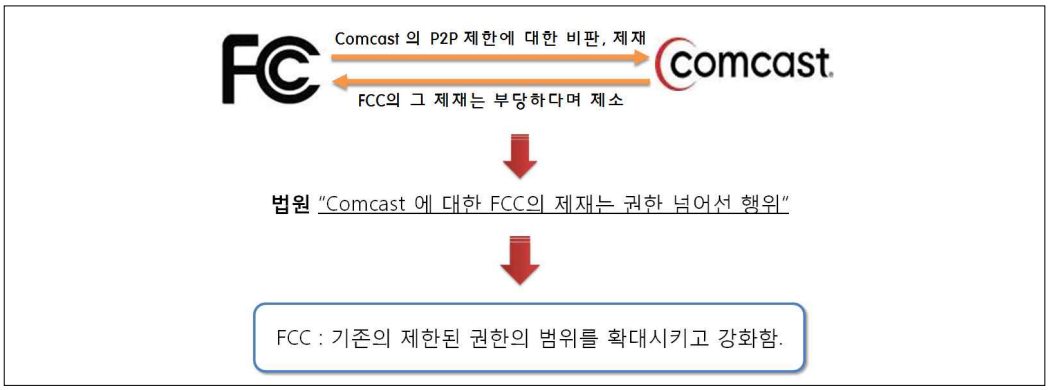
블 방송사업의 이전(transfer)에 FCC 외에도 지방정부의 승인을 얻어야 하는 바, FCC는 최종적으로 당해 매수를 승인했으나, Portland시는 케이블 방송사업의 프랜차이즈 인가당국으로서 비계열 ISP에 대한 오픈 액세스를 강제하는 조건을 채택하였다. 이에 AT&T 및 TCI사는 Portland시는 그러한 권한이 없다고 주장하며 소송을 제기한 것이다.

당해 법적 분쟁 결과는, 케이블 모뎀 서비스의 법적 성질에 크게 의존하는 것으로 당해 서비스가 케이블 방송서비스로서 법적성질을 갖는다면, 「연방통신법」 제6편을 바탕으로 지방정부의 광범위한 감독권한을 따르게 되는 반면, 전기통신서비스로서의 법적성질을 가진다면 동법 제2편을 바탕으로 FCC에 의해 엄격한 기간통신사업자 규제에 따르는 것이 되어 오픈 액세스 명령을 받으나, **정보서비스가 된다면 동법 1편에서 오로지 FCC의 감독권한에 따라서 보다 완화한 규제에 따르는 것이 된다.**

법원은 케이블 모뎀 서비스 쌍방향성을 근거로 들어 당해 서비스는 케이블 방송서비스에 해당되지 않으며, 그것은 정보서비스와 전기통신서비스의 요소를 포함하고 있다고 판시(判示)하여, 지방당국의 감독권한을 부정했다.

5) Comcast 대 FCC 사건[60]

[그림 26] Comcast v. FCC Case 사건 개요



본건은 미국 최대의 케이블 방송사업자인 Comcast가 FCC를 상대

60) 松宮広和, 『最近米国の情報サービス規制をめぐる論議、再論』, 群馬大学社会情報学部研究論集, 第18券, 97-129頁. 2011. 3. 31.

로 2008년 8월 Comcast에 의한 차별적인 네트워크 운영 실무 종료를 명하는 본건 시정조치에 관하여 취소를 구하는 행정소송으로, 법원은 FCC의 Comcast에 대한 제재는 권한을 넘어선 행위로 위법하다는 이유로 Comcast의 청구를 인용하였다.

Comcast는 자신이 보유한 케이블 방송망을 통해 음성통화 서비스인 '인터넷 전화통화 규약'(voice over Internet protocol: VoIP), 광대역 ISP 서비스 및 웹사이트를 통해 일정한 범위에서 쌍방향성이 있는 '주문형 비디오 시스템'(video on demand: VOD) 서비스 등을 제공하여 왔다. 그런데 소비자들이 BitTorrent(오픈 소스로서 서버를 필요로 하지 않는 순수형 'Peer to peer: P to P:P2P' 형 네트워크 프로토콜)와 같은 P2P 응용 프로그램을 사용하여 온라인으로 파일을 공유하자 특정 시점의 전체 네트워크 혼잡 정도에 관계없이 또한 하루 중 시간에 관계없이 가입자의 P2P트래픽 간섭하여 위와 같은 소비자들의 시도를 방해하였다.

2007년 11월 1일 Free Press라는 미디어 개혁단체가 FCC에 대하여 Comcast에 대한 당해 행위 금지 명령을 요구했고, FCC는 금지조치를 내렸는데, 법원은 다음의 이유로 위 금지조치를 취소하였다. FCC의 본건 시정조치가 「96년 법」 Ⅰ편의 관할권의 범위에 포함된다고 하는 것은 지나친 확장해석이며, 본건 시정조치가 해당 권한의 범주에 들 것인가는 CATV를 규제하는 FCC의 권한의 한계를 인정하는 것으로 고도의 신중함이 요구되어 고도의 입증이 필요하다고 할 것인데, 그 입증책임을 다하지 못하였다고 판단한 것이다.

6) 전미 케이블통신연합 대(NCTA) 대 Brand X 사건

[그림 27] NCTA v. Brand X 사건 개요

본건은 Brand X가 전미케이블통신연합(National Cable & Telecommunications Associations: NCTA)에 대하여 인터넷망 접속의무 이행을 청구한 민사소송으로, 법원은 FCC에게 판단을 위임하여 BrandX의 청구를 받아들이지 않았고, FCC는 인터넷은 망중립성 규정이 적용되지 않는다고 확인하였다.

NCTA는 MVPD, 음성전화 서비스 및 케이블 모뎀 서비스 등을 제공하는 전미 케이블 방송사업자가 주요한 구성원인 사업자단체이고, Brand X사는 1994년 이래 캘리포니아 주 남부를 중심으로 Brand X Internet Services의 명칭으로 인터넷 관련 서비스를 제공해 왔던 통신사업자인데, 본건에서는 케이블 모뎀 서비스와 그 밖의 브로드밴드 인터넷 액세스 서비스 제공사업자를 「연방통신법」 제2편에서 전기통신서비스로써 규제할 수 있는가가 문제가 되었다. 전화 모뎀을 통한 인터넷을 사용하던 시대에는 소규모 인터넷 서비스 제공자(small Internet service provider: SISP)들이 기간통신사업자의 전화선을 사용했기 때문에 모두가 동등한 접근권을 누렸으나, 케이블의 시대가 도래 하면서 동축 케이블을 통하여 빠른 인터넷 접속이 가능하게 되었다.

SISP의 하나인 Brand X는 케이블 회사가 소유하고 있는 동축 케이블을 사용하고 싶었으나, 동축 케이블은 망 중립성에 해당되지 아니하여 기간통신사업자로 분류되지 않았기 때문에 동등한 액세스가 요구되지 않는다는 이유로 NCTA는 Brand X의 신청을 거절했고, 이에 Brand X가 소송에 나선 것이다.

미 연방대법원은 6 : 3으로 통신산업과 정보산업 간의 구분이 애매모호하기 때문에 FCC에 결정권이 있다고 판결하여 BrandX의 주장을 받아들이지 않았고, FCC는 케이블 회사는 정보산업에 해당하므로 경쟁자에 동축 케이블망 접근을 허용할 필요가 없다고 결정하였다.

3. 미국 사업법 판례분석

가. 사업법 위반의 민사 사건

사업법 위반 민사 사건의 경우, 통신사업자와 수직적 착취 관계에 있는 사업자가 약관요금이 지나치게 높다는 이유 등으로 민사소송을 제기하는 사안들이 대부분이다. 이 경우 법원은 통신사업자 승소 판결을 선고하면서, 인가약관 적법성 추정의 법리 등을 원용한다. 인가권 행사에서 폭넓은 재량행사가 인정되는 사업법 당국의 심사를 통과한 약관의 효력을 부인하는 것은 어렵다고 할 것이다.

[표 7] 사업법 위반 민사사건 요약

소송물	원고	피고	관계	결과	쟁점
약관요금	Marco	AT&T	수직관계	청구기각	인가약관 적법성 추정 원칙
약관요금	TCI	MCI	수직관계	청구기각	인가약관 적법성 추정 원칙
약관요금	Wegoland	NYNEX	수직관계	청구기각	인가약관 적법성 추정 원칙
접속의무	Brand X	NCTA	수직관계	청구기각	케이블망 중립성

나. 사업법 위반의 행정 사건

사업법 위반 행정 사건은, 통신사업자의 인가권자가 그 재량을 일탈, 남용하여 권한을 행사하는 경우 그 위법성을 다투어 행정소송을 제기하는 사안들이다. 이 경우 법원은 통신사업자 승소판결을 선고하면서, 「연방통신법」 우선적용의 법리를 원용한다. 「연방통신법」에 반하는 주법, 혹은 하위 규정들의 효력은 부인된다.

[표 8] 사업법 위반 행정사건 요약

소송물	원고	피고	관계	결과	쟁점
약관 요금	AT&T	FCC	수평 관계	청구인용	비대칭적 규제
약관 요금	AT&T	Iowa Utilities Board	지방	청구인용	약관규제
접속 의무	AT&T	Portland 시	지방	청구인용	케이블망 중립성
접속 의무	Comcast	FCC	수직 관계	청구인용	케이블망 중립성

Ⅳ. 미국 통신시장에 대한 경쟁법 규제

1. 미국 경쟁법의 규제 형식

가. 중복 규제

독점적 통신사업자의 사업법 위반을 청구원인으로 하는 민사소송 내지 행정소송에서 승소하기란 대단히 어렵다. 「연방통신법」이라는 엄격한 경성법 시스템을 토대로, 실체법적으로는 우선적용(preemption), 절차법적으로는 추정(presumption)이라는 법기술을 통해 독점적 통신사업자에게 우월적 지위가 부여되기 때문이다. 따라서 이를 극복하기 위하여 사업법 위반 대신 경쟁법 위반을 청구원인으로 하여 권리구제를 모색하는 방안이 강구되어 왔다.

현재 미국에서는 규제산업에 대한 경쟁법의 적용에 있어서의 문제는 경쟁법과 사업법의 중복적용이나 경쟁법의 적용에서의 특정 산업이나 특정사업법의 존재의 고려 방식이다. 앞서 본 바와 같이 인가약관의 적법성 추정과 정보서비스 사업자에 대한 FCC의 협소한 규제관할권 때문에 권리구제가 미흡하다는 지적이 있어 경쟁법의 역할이 기대되어 왔다.

미국 「통신법」은 제601조(b)항(1)호에서, '본 법 또는 본 법에 의한 수정조항 모두는 「독점금지법」의 어떤 적용도 변경 또는 저해하거나 대체하는 것이라고 해석되어서는 아니 된다'고 규정하여 통신시장에 대한 경쟁법 적용 원칙을 인정하고 있다. 또 601조(c)항(1)호에서 '본 법 또는 본 법에 의한 수정조항 모두는 해당 법 또는 수정조항이 그 취지를 명시적으로 정하지 않는 한, 어떠한 연방, 주 또는 지방단체의 법도 변경 또는 저해하거나 대체하는 것으로 해석되어서는 아니 된다'고 규정하고 있다(이하, '독점금지 유예조항'(antitrust savings provision)).

경쟁당국과 규제당국 사이의 관할권에 관한 대립·긴장관계를 전제로 한 경쟁법과 통신법의 형식적·원리적인 상호관계 설정의 문제와 관

련하여, 「96년 법」은 「독점금지법」을 명확하게 적용제외라고 하지 않고 있는데, 이것이 「96년 법」에 있는 소위 유예조항(saving clause)이다. 특히 사업법에서 규제를 받고 있는 특정시설로의 접속거절에 대하여 경쟁법 상의 규제가 가능한지 여부가 그 문제의 초점이 되고 있으며, 이는 사업자의 이익과 경쟁 보호로 인한 소비자 이익의 보호의 충돌과 연장선상에 있는 문제이다.

나. 통신법의 진화

1) 상호보완적 규제

사업법 상 규제에 관하여 먼저 경쟁이라는 관점에서 심사하는가가 검토되어야 하는데, 통신사업에서, 사업법 규제와 경쟁법 규제는 일단 형식적으로는 병존하고 있지만, 실질적으로 볼 때 사업법 규제가 실효적으로 기능하고 있는 사항에 관해서는 경쟁법 규제를 추가적으로 시행하지 않는다. 그러나 경우에 따라서, 사안을 둘러싼 경쟁침해의 실질에 비추어, 경쟁법의 적용가능성을 완전히 배제하지 않고 있다. 사업법 규제의 대부분은 경쟁 이외의 별도의 공공정책 목적을 가지는 바, 사업법 규제 중에는 경쟁도입 및 촉진이라는 측면에서 공공정책으로서의 경쟁법적 지향 목표도 포함되어 있다. 경쟁촉진 목적에 이바지하는 사업법 규제에 관해서는, 그것이 실효적으로 기능하고 있다면 일단 사업법 규제에 의존하고, 경우에 따라서 경쟁법 규제가 작용할 여지를 남긴다는 상호보완적 규제 체제로 이해하는 것이 바람직하다.

미국법에서 사업법 규제와 경쟁법 규제의 조정이 쟁점이 되는 배경의 하나에는, 손해배상이나 금지청구소송 등 민사소송에서 통신법과 경쟁법의 어느 조항을 청구의 취지 및 원인으로 할 것인지의 문제가 있다.[61] 전기통신사업에 관해서도, 현시점에서 미 법원은 확실히 경쟁법의 운용에 신중하고 엄격한 태도를 견지하고 있다. 경쟁법 위반으로 인정되기에는 아직도 논란의 여지가 있는 필수 설비에 대한 공정한 접속

61) 「독점금지법」 상의 시정조치의 다양성은 존치의 정당성을 나타낸다. 시정조치로서 업무나 회계의 분리 및 정보차단 등의 적극적 작위·부작위 의무 부과 등이 활용될 수 있다.

보장 문제를 통신법 위반으로 유효하게 인정하고 있는 것이다. 이는 법원의 현시점에 대한 판단으로서, 사업법에 의한 별도의 구제방안이 마련되어 있는 부분에 대한 민사소송에 의한 경쟁법의 이용을 제한한 것에 지나지 않는다고 할 것이다. 이상과 같이 미국법의 경쟁촉진형의 사업법 규제를 적용하는 분야에 있어서, 사업법 규제와 경쟁법 규제가 상호 보완적 체제라는 철학으로 운용되고 있다고 판단된다.

2) 네트워크 중립성 규제

네트워크 중립성 이슈는 네트워크 사업자에 대한 통신서비스의 비차별적이고 중립적인 제공의무의 존부에 관한 문제이다[62]. 최근 미국에서의 네트워크 중립성은 인터넷을 위한 브로드밴드 시장에서 길목 설비를 보유하는 전기통신사업자나 케이블 텔레비전 사업자 등 네트워크 사업자의 시장지배력을 공적 규제를 통해서 어떻게 규제해야 할 것인지에 관해 논의의 초점이 모아진다.

네트워크에 대한 설비투자의 확보라는 문제는 브로드밴드 시장에서의 가장 중요한 과제의 하나로서 인식되고 있는데, 이는 인터넷을 통해 제공되는 콘텐츠나 어플리케이션의 품질이 네트워크 품질에 크게 의존하기 때문이다. 브로드밴드 시장이 발전함에 따라, 앞으로의 최적의 네트워크 용량을 적확하게 예측하고 시기적절하게 충분한 설비투자를 확보하기 위하여, 사업자에 의한 투자 및 혁신에 대한 인센티브를 마련하고 동시에 현존하는 네트워크의 효율적 활용을 저해하지 않도록 하는 규제상의 고려가 중요할 것이다.

요금차별화에 관하여는 최종소비자와 C/A(Contents/Application) 사업자에 대한 요금차별화라는 문제를 중심으로 논의가 전개된다. 최근 급성장하는 인터넷 시장에서 구글, 애플, 아마존 등 세계적인 유력 C/A사업자가 출현하면서 이들 거대 C/A사업자에 의한 네트워크 전송로의 무임승차론이 주장되었고, C/A사업자 측에서도 자신의 C/A 서비스에서 보다 고품질의 전송서비스를 추구하게 되었다. 유한자원인 네트워크 용량의 효율적 이용이라는 관점에서 C/A사업자에 대한 유상의

62) 東條吉純、『米国連邦通信委員会によるネットワーク中立性規則 - 差別行為の規範的分類の試し-』, 立教大学. 2012. 1. 15.

우대서비스가 허용되어야 한다면, 이는 네트워크 이용의 공평성 내지 네트워크 중립성이라는 가치와 출동할 가능성을 내포한다.

FCC는 2010. 12. 23. 새로운 네트워크 중립성 규칙(이하 'FCC 신규칙')인 '오픈인터넷 지침'을 채택하였고, 이는 2011. 11. 20. 발효되었다. FCC 신규칙에서 제시한 규제의 틀과 사고는 네트워크 사업자에 의한 차별행위에 관한 규범적 분류를 시도한 것이다. 규제 대상이 네트워크로 규정된 것은 통신시장의 융합과 변동성에 기인한다.

2011년 현재 미국 유선전화 시장구조는 AT&T(SBC)가 40%, Verizon이 25%, CenturyLink가 10%이며, 휴대전화 시장구조는 2013년 현재 AT&T가 35%, Verizon이 30%, Sprint 20%, T-Mobile 15%를 차지하고 있다. 최종소비자에 대한 라스트마일 회선에 관해서는 ISP 서비스를 포함한 브로드밴드 서비스 일체가 길목 시설을 보유하는 네트워크 사업자인 지역전화회사와 케이블 텔레비전 회사의 2대 진영에 의해 제공되는 복점구조가 성립되어 있다.

3) 경쟁 환경 향유권

FCC는 2005년 광대역 통신망 시장에서 소비자의 지위로서 다음의 4가지 원칙을 제시하였다. ① 그 선택에 근거하여 합법적인 콘텐츠에 접속할 지위, ② 그 선택에 근거하여 어플리케이션이나 서비스를 이용할 지위, ③ 그 선택에 근거하여 적법한 단말을 접속할 지위, ④ 네트워크 사업자 간, 어플리케이션 사업자 간, 콘텐츠 사업자 간 경쟁을 향유할 지위가 바로 그것이다.

이 네트워크 중립성 4원칙의 정책성명은 소비자의 법적 권리를 확장하였고, 이후 FCC에 의한 규제정책 상의 지침이 되는 동시에, 법적 구속력을 갖는 네트워크 중립성 규칙의 제정으로 이어지는 첫걸음이 되었다.

4) 수문 규제

2010년, FCC가 채택한 새로운 네트워크 중립성 규칙(신규칙)인 '오픈인터넷 지침'은 그 목적이 소비자의 선택과 표현의 자유, 최종소비자에 의한 컨트롤, 경쟁 및 혁신의 자유를 가능하게 하는 오픈 플랫폼으로서의 인터넷을 유지하는 것이다. 이 지침의 3가지 기본 규칙은 투명성의무, 차단금지의무, 부당한 차별금지의무이고, '합리적인 네트워크 관리'의 개념이 이들 의무에 대한 적용제외영역으로서 규정되었다.

특징적인 것은 브로드밴드사업자의 금지의무의 범위를 부당한 차별행위에 한정하고 있는 것이다. 또 합리적인 네트워크 관리행위가 비차별 취급 의무의 적용제외가 된 것은 브로드밴드 사업자에 의한 트래픽의 차별적 취급 중 일정 범위를 합리적인 차별로 용인함을 의미한다.

신규칙은 적어도 차별행위에 관해서 일률적인 금지의무를 설정하는 것을 피하고, 차별의 부당성이나 네트워크 관리행위의 합리성 같은 규범적 개념을 매개로 하여 그 구체적인 판단기준은 소송 프로세스를 통해서 형성해 가는 접근을 취한 것으로 보인다. 트래픽 차단행위 및 그와 동일시할 수 있는 전송지연행위에 관해서는 합리적인 네트워크 관리의 경우를 제외하고는 일률적인 금지의무가 부가되어, 동 원칙에 있어서 경쟁법에 의한 규제와의 차이는 명백하다고 생각된다.

가) 경쟁자 보호

FCC의 신규칙은 일률적인 금지의무는 트래픽 차단행위에만 적용되고, 차별행위에 관해서는 부당한 경우만을 금지하며 그 구체적인 판단은 개별적인 사례의 판단을 통해 명백하게 한다는 규제의 구조를 채택했다.

신규칙과 경쟁법 규제와의 차이를 살펴보면, 신규칙은 「연방통신법」 상의 보호법익인 '공공의 이익'에 반하는 차별행위가 규제되어야 하며, 동 이익개념 안에는 경쟁촉진이나 설비투자에 대한 장애제거와 더불어 소비자의 선택의 자유와 표현의 자유, 최종소비자에 의한 컨트롤 및 혁신의 자유가 포함된다는 점에서 경쟁법적 규제와 다르다. 따라서 반경쟁 효과의 입증을 필요로 하는 경쟁법 규제와는 달리, 브로드밴드 사업자가 인터넷 정보통신산업에서 승자와 패자를 만들어내지 않도

록 하는 공적규제의 틀을 요구하고 있는 것이다.

따라서 이에 관련된 신규칙의 철학은 브로드밴드 사업자가 '게이트키퍼' 또는 업종 종단 독점자로서 행동하는 능력을 지닌다고 규정하고, 규제의 초점을 통신망 수문을 적절히 규율하는데 맞춘다. 이는 C/A사업자가 특정 최종소비자에게 서비스를 제공하기 위해서는 반드시 해당 최종소비자가 계약하는 브로드밴드 사업자에 의한 트래픽 전송이 필요하기 때문이며, 브로드밴드 사업자가 게이트키퍼로서 행동하기 위해서는 반드시 시장지배력까지는 필요하지 않는다고 볼 것이다.

신규칙 상의 차단금지의무는 특히 브로드밴드 사업자에게 부과되는 의무로서 차단행위에는 이와 유사한 효과를 갖는 전송지연행위도 포함되는 점과 제공되는 서비스에 따라서는 트래픽 전송지연이 치명적인 것도 다수 존재함을 감안하면, 차단금지의무는 상당히 엄격한 중립성규제로서 기능할 가능성도 있다. 이 때문에 차단금지의무의 적용제외영역으로서 '합리적인 네트워크 관리' 개념의 외연이 지극히 중요해지는 것이다.

이상과 같이 경쟁법 규제와의 비교에서는, 일률적인 차단금지의무는 물론, 부당한 차별금지의무의 적용도 경쟁법이 요구하는 레벨에서의 시장지배력 분석 내지 반경쟁 효과의 분석은 불필요하게 된다. 본래 미국에서는 브로드밴드 접속서비스를 포함하는 통신 레이어에서, 케이블 텔레비전 회사와 지역전화회사에 의한 복점구조가 성립되어 있으며, 신규칙은 "시장지배력까지는 필요하지 않다"고 기술하고 있다.

나) 차별행위의 부당성 식별 요소

반경쟁 효과분석을 대신하여 신규칙이 차별행위에서 정당성/부당성을 식별하기 위한 고려요소로서 열거하는 것은, ① 정보개시의 정도, ② 최종소비자에 의한 선택의 자유도, ③ 특정 이용구분에 중립적인 취급의 차별화, ④ 표준화기관의 모범사례 등으로서의 적합성 등 모든 사항이다.

우선 트래픽 전송과 관련된 차별적 취급에 있어서, 최종소비자에 대한 정보개시의 정도가 높으면 높을수록, 차별적 취급이 정당한 것이라

고 판단되기 쉽다. 역으로 차별적 취급과 관련된 정보가 최종소비자에게 개시되지 않는 것 그 자체가 해당 차별행위의 부당성의 근거가 되는 경우도 있다. 이는 최종소비자에게는 트래픽 전송지연의 원인을 특정하는 것이 곤란한 경우가 많아, 브로드밴드 사업자에 의해 트래픽 전송의 차별적 취급에 관한 정보가 개시되는 것은 브로드밴드 시장에서 경쟁이 기능하기 위한 중요한 전제조건이기 때문이다. 또 최종소비자에 의한 선택 및 컨트롤의 자유의 크기도 차별의 정당성을 평가할 때 중요한 사항이라고 여겨진다.

반대로 대역이나 품질에 근거한 가격차별을 금하고, 최종소비자에게 획일적인 요금을 의무화하는 것이 라이트 유저의 희생 하에 헤비 유저를 우대함을 의미하고, 네트워크의 효율적 이용에 해당하는 행위를 저해하는 바, 여기서 네트워크 품질에 따라서 최종소비자에 대한 요금을 차별화하는 행위가 합리적인 차별행위임이 나타나고, 이는 신규칙에서 정당화된다.

브로드밴드 사업자에 의한 차단행위나 차별행위가 '합리적인 네트워크 관리'에 해당하는 경우, 해당 행위는 정당한 행위로서, 차단금지의무 및 부당한 차별금지의무에서 면제된다. 이들 금지규범은 그 운용에 따라서는 상당히 엄격한 중립성 규제가 될 가능성도 있어, 대상 행위가 '합리적 네트워크 관리'에 해당하는지 여부는 지극히 중요하다고 할 것이다.

'합리적 네트워크 관리' 목적에는 네트워크를 해하는 트래픽에 대한 대처 등 네트워크 안전성 및 통합성 확보, 최종소비자의 바람직하지 않은 트래픽에 대한 대응, 네트워크 혼잡의 완화 등이 포함된다. 네트워크 관리행위의 합리성을 평가하기 위한 지침으로서 예시되는 고려요소는 차별행위의 정당성을 평가할 때와 동일하며, 정보개시의 정도 및 최종소비자에 의한 선택 및 컨트롤의 자유도 등이 중요한 지표라고 여겨진다.

FCC 신규칙은 브로드밴드 사업자의 차별행위에 관하여 사회적으로 유익하면서 합리적인 차별행위를 유해하면서 부당한 차별행위로부터 구별해야 한다는 판단에 근거하여, 차별행위의 규범적 분류를 시도한 것이다. 즉 엄격한 네트워크 중립성 규제로서의 일률적인 비차별 취급 의무는 도입하지는 않는다는 자세를 보인 것이라고 평가할 수 있다. 또

신규칙은 규칙으로서의 명확성·예측가능성을 희생하면서, 차별행위의 '부당성'이나 네트워크 관리의 '합리성'과 같은 불확정개념의 구체적인 위법성 기준에 있어서는 개별적 판단 사례를 쌓아가면서 명백히 하는 구조를 취하였다.

본래 차단행위에 관해서 일률적인 금지의무를 부과하고 있는 점, C/A시장에서의 경쟁자 배제에 관해 시장지배력 분석 및 반경쟁 효과 분석을 불필요하다고 하는 점에서, 적어도 단기적인 사회후생 내지 효율성의 관점에서만 정당화하는 것은 곤란하다고 할 것이다.

2. 미국 경쟁법 적용의 구체적 사례

가. 요약

[표 9] 미 경쟁법 적용의 사례 요약

소의 종류	사안	청구 취지	청구 원인	판결의 요지
민사 (소비자)	Goldwasser v. Ameritech	피고의 접속의무 등 위반에 대한 3배액 손해배상(집단소송) 및 금지청구	피고가 부당하게 경쟁자에 대한 액세스를 거절하여, 소비자인 원고에게 손해를 입혔다.	① 인가를 거친 요금에 대하여는 「독점금지법」 및 「전기통신법」상의 손해배상 청구권이 인정되지 않고, ② 「96년 법」위반 행위가, 반드시 「독점금지법」이 규제해야 하는 배타적 행위로서 파악하는 것은 바람직하지 않다③ 소비자에게는 금지청구의 원고적격이 인정되지 않는다(청

				구기각).
민사 (경쟁자)	Covad communication v. BellSouth	원고가 피고에 대하여 공정한 접근을 허용할 것을 청구	원고의 서비스 제공을 위해 필요한 적절한 액세스를 피고가 거절하였다.	「통신법」 상의 의무위반과 「독점금지법」 상의 반경쟁 행위여부는 법원에서 함께 심리될 수 있으며, 필수설비이론 등은 「독점금지법」 제2조에 의하여 독립한 청구원인이 된다(청구인용).
민사 (경쟁자)	MetroNet v. U.S. West Communication	피고의 공정 접속 의무 위반이 경쟁법상의 의무 위반에 해당함	피고가 원고가 사용하는 서비스에 대한 할인 가격지침을 변경하여 가격이 400%이상 상승함으로 인해 원고가 더 이상 고객에게 위 서비스를 판매하지 못하게 됨.	원고가 피고의 고도화된 정보통신산업의 시장지배력이나 배타적 행위로 인하여 손해를 보았다고 인정함(청구인용)
민사 (소비자)	Law office Trinko v. Bell Atlantic	피고의 「독점금지법」 제2조 위반 행위에 대하여 3배의 손해배상(집단소송)청구	Bell Atlantic의 경쟁자인 AT&T의 고객이었던 원고가, 필수설비이론이나 독점의 지렛대 이론 등을 들어 피고의 행위가 경쟁법인 「독점금지법」 위반과 사업법인 「전기통신법」 위반한다고 주장	UNE는 일반 고객이 아니라 경쟁자에 대해서만 판매되는바, 소비자인 Trniko가 사업법 위반을 이유로 본건 청구를 하는 것은 받아들일 수 없다(청구기각).
민사	LinkLine v. AT&T 등	피고의 약탈적 가격 설정 등의	원고가 서비스를 제공하기 위해서는 피고의	피고가 인터넷 사업자인 원고와 도매 단계에서

(소비자)		행위가 경쟁법에 위반된다고 청구	통신망을 이용하는 것이 필요했는데, 피고가 「독점금지법」 제2조에 반해서 지역DSL시장을 독점화 하거나, 혹은 당해시장의 독점화를 기도했다고 주장	거래해야 하는 의무가 「독점금지법」 상 없는 경우에, 단독거래거절 자체를 「독점금지법」 제2조 위반으로 볼 수는 없는 것이다(청구기각).
민사 (소비자)	Bell Atlantic v. Twonmbly	기존의 지역전화사업자 4사인 피고들이 공모해서 지역전화 서비스 시장에 있어서 거래를 제한한 행위에 대한 금지와 3배액 손해배상(집단소송)을 청구	① 피고들은 경합지역전화사업자의 급속한 진출을 방지하기 위해 각 지역에서 '병행행위(parallel conduct)'를 실시하고, ② Y는 다른 기존의 전화사업자가 맡고 있는 지역에서 진입을 상호간에 회피하고, 경쟁우위의 인접시장에서 '매력적인 사업기회'를 모두 회피 하고 있다.	① 사업 활동에 있어서 병행행위는 '합의(agreement)'를 추인하는 간접증거이기는 하나, 이것을 가지고 바로 '합의'를 입증하고 「독점금지법」 위반을 구성하는 것이라고 말할 수는 없고, ②'의식적인 병행 행위 '(conscious parallelism)의 경우 그것이 당연하게 위법이라고 말할 수 없으며, ③ 사실심리(trial)에 있어서도 「독점금지법」 제1조의 공모를 주장하는 원고는 병행행위 이상의 증거를 제시하지 않으면 평결(verdict)을 요구할 수 없는 것이다(청구기각).

나. 구체적인 내용

1) Goldwasser 대 Ameritech 사건[63)]

[그림 28] Goldwasser v. Ameritech 사건 개요

본건은 Goldwasser가 Ameritech를 상대로 적정, 합리적, 비차별 조건의 경쟁자 접속을 거절하여 소비자에게 피해를 주었다는 이유로 민사소송을 제기한 사안으로, 법원은 Godwasser의 청구를 받아들이지 않았다. 본 사건은 「96년 법」과 경쟁법의 관계를 특히 이론적인 면에서 명시적으로 해석한 출발점으로 꼽힌다.

지역전화를 이용하고 있는 최종사용자인 원고 Goldwasser는 「96년 법」에 규정한 CLEC과의 비차별적 거래 의무를 준수하지 않은 ILEC, 피고 Ameritech에 의해 피해를 입었다고 하면서 피고가 「전기통신법」상의 기존 사업자의 의무에 위반하는 동시에, 「독점금지법」 제2조에 위반하여 위법한 독점행위를 하였다고 하여 1997년 9월, 집단소송으로서 그 3배액에 해당하는 손해배상 및 금지청구소송을 제기하였다.

원고는 피고의「독점금지법」 및 「통신법」 251조 위반의 구체적 행동에 대해, 피고가 관련 지역전화서비스 시장의 90% 이상을 점유하고, 실질적으로 신규참여를 저해했다고 주장했다. 즉 ① Ameritech는 경쟁자에게 자기와 동일 품질의 서비스를 제공하지 않고, ② OSS(operation support systems: 서비스 제공 상 지극히 중요한 일정

63) 222F. 3d 390(2000)

종류의 고객 관리 데이터베이스)로의 개별화된 비차별 접속을 인정하지 않고, ③ 개별화된 네트워크 구성요소로서 덕 화이버를 제공하지 않고, ④ 전신주에 대한 경쟁자의 접근을 인정하지 않고, ⑤ 로컬 루프 등을 포함하는 네트워크 구성요소를 완전하게 개별화하지 않고, ⑥ 경쟁자는 개별화된 네트워크 구성요소의 취득에 관하여 필시 의도적이지만 어쩔 수 없이 지연되도록 하고, ⑦ 개별화된 루프로의 접속을 구했을 때 지연으로 인한 차별적 취급을 받도록 하고, ⑧ Ameritech는 비차별 베이스에서 지역오피스 간 전송설비에 대한 요소별 접속을 제공하지 않고, ⑨ 경쟁자에 대해서 지역 교환 서비스를 제공하지 않고, ⑩ 주(州) 간 접속비용을 징수할 수 없는 경우에도 경쟁자 등에 대해서 접속비용을 요구함으로써 경쟁자를 차별적으로 취급하고, ⑪ 개별화된 지역 교환 서비스의 일부로서 제공해야 하는 상업화된 라우팅을 제공하지 않고, ⑫ 0번이나 411번 등 다이얼 패리티를 경쟁자에게 제공하지 않고, ⑬ 비차별 베이스에서 911번 등의 긴급 서비스로의 접속을 제공하지 않고, ⑭ 자신이 사용하는 상호접속과 동등하게 자신과 경쟁자의 네트워크 간 상호접속을 제공하지 않고, ⑮ 「통신법」 272조(b)항(5)호에 정하는 관련 회사 간 모든 거래를 공개하지 않고, ⑯ UNE 베이스에서 적정·합리적·비차별 조건에서의 네트워크 구성요소에 대한 경쟁자의 액세스를 거절하고, ⑰ 적정·합리적·비차별 조건의 도매가격에서의 경쟁자에 대한 지역전화서비스의 판매를 거절하고, 경쟁자에 의한 매력적인 재판매 서비스 제공을 저해하고, ⑱ 적정·합리적·비차별 조건에서의 경쟁자에 의한 지역전화 네트워크로의 접속을 거절했다 는 것이다.

이에 대해 법원은, ① 적정한 인가절차를 거친 요금에 대해서는 고액 내지 반경쟁적임을 이유로 공익 사업자에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다는, 즉 인가요금이론에 근거하여, 「독점금지법」 및 「전기통신법」 상의 손해배상청구권을 인정하지 않았고, 또 ② 소송이 복잡한 규제제도를 혼란시키는 경우에는 원고 적격이 없다고 한 법리에 따라서 금지구제를 인정하지 않았으며, ③ 고객에게는 「전기통신법」 상 ILECs에 부과시키는 의무의 이행을 구하는 권리가 인정되지 않는다고 하여 원고 청구를 기각하였다.

법원에서는 「96년 법」에 규정되어 있는 ILEC에 대한 의무는 배타적 행위를 금지하고 있는 독점사업자의 의무와 동일하지 않고, 위 법에 위반하는 행위를 자동적으로 「독점금지법」 2조의 목적에 비추어 규

제해야 하는 배타적 행위로 파악하는 것은 바람직하지 않다고 하였다. 그리고 「96년 법」에 규정되어 있는 ILEC에 대한 의무는 경쟁법에는 존재하지 않으며, 동법은 「독점금지법」보다도 상세하고 광범위한 의무를 부과하고 있다는 사정을 지적하였다.

법원은 이러한 분석을 「독점금지법」 2조의 개관에서 시작하였다. 법원에 따르면, 본조 위반이라고 하기 위해서는 ① 행위자가 관련 시장에서 독점력을 가질 것, ② 그 힘은 특정 상품 경영상의 통찰·역사적 우연 등의 귀결로서, 성장이나 발전과는 구별되는 형태로 의도적으로 형성·유지될 필요가 있는 바, 독점적인 힘의 단독 행사만으로는 위법에 해당하지 않고, 의도적으로 잠재적 혹은 현재의 경쟁자를 배제하여 시장경쟁을 저해하기 위한 힘의 행사일 것이 인정되어야 한다고 보았다.

법원은 원고 주장의 근본적 오류가 「전기통신법」 상 ILECs에 부과되는 의무를 「독점금지법」 상 독점사업자에 대해서 부과시켜야 하는 의무의 연장 상에서 고려하고 있는 점에 있다고 보았다. 전기통신시장을 개방하는 것만이 문제였다면, 의회는 단지 1934년「통신법」 등에 의한 규제를 철폐하면 되었을 터인데, 그것만으로는 해당 시장으로의 신규참여가 실질적으로 대단히 곤란할 것이므로, 단순한 반트러스트법 규제에 의한 개별적 대처의 누적에 의하지 않고, ILECs에 대한 일련의 규제 및 FCC와 각 주 공익사업위원회에 의한 감독 및 특별한 상호접속 교섭절차에 의해 급속한 경쟁적 개방을 선택한 것이다. 이러한 규제는 실로 통상적인 경쟁법에 의존하지 않는, 경쟁자를 조력하는 일종의 적극적 의무이다. 이 때 의회의 입법조치 적합여부를 심사하는 것은 법원의 임무가 아니라, 이러한 사업법 규제가 경쟁법이 단독으로 할 수 있는 모든 것을 초월하여 잘 기능함을 인정할 뿐이다. 「통신법」 위반을 「독점금지법」 위반과 동일시하는 것은 논리적이 아니며, 또 바람직하지도 않다. 「통신법」에 관한 분쟁은 사업법 규제의 틀 안에서 처리되어야 하며, 실제로도 그러하였고, 경쟁법이 추가적으로 이룰 수 있는 것은 없다. 따라서 원고들의 경쟁법 상의 청구는 기각되었다는 것이 법원의 입장이다.[64]

즉, 법원에서는 「96년 법」에 규정되어 있는 ILEC에 대한 의무는 배타적 행위를 금지하고 있는 독점자의 의무와 동일하지 않다고 하고. 동법에 위반하는 행위가 자동으로 「독점금지법」 제2조의 목적에 비

64) 토사 카즈오, “사업법 규제와 독점규제법 규제의 배타제어”, 입명관법학, 2005년 2,3호(300,301호)

추어 규제해야 하는 배타적 행위로서 파악하는 것은 바람직하지 않다고 판단한 것이고, 「96년 법」에 규정되어 있는 ILEC에 대한 의무는 경쟁법에는 존재하지 않는 점, 동법은 「독점금지법」보다도 상세하고 광범위한 의무를 부과하고 있다는 사정을 지적하였다. 이 사건은 경쟁법 위반을 이유로 대량판매 이용자가 제기하는 사적인 소송은 패소한다는 이론을 정립한 선도적 사례로 인용된다.

2) Covad Communications 대 BellSouth Corp. 사건[65)]

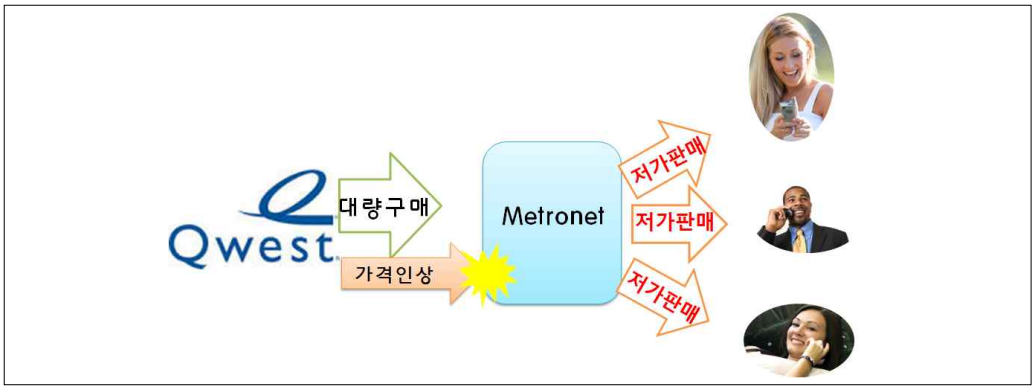
[그림 29] Covad v. BellSouth Corp. 사건 개요

본건은 Covad가 BellSouth에 대하여 공정한 접속을 허용할 것을 청구한 민사소송으로, 법원은 원고의 청구를 받아들였다. 원고 Covad는 자기 서비스제공을 위하여 요구한 적절한 접속을 경쟁자 CLEC으로서 피고 BellSouth가 거절하였다고 주장하면서 소를 제기하였는데, 법원은 ① 「96년 법」에 규정되어 있는 의무위반과 반경쟁적 행위의 주장에 근거한 경쟁법 상 의무위반은 법원에서 함께 심리될 수 있으며, ② 필수설비이론, 거래거절, 가격압력에 근거한 「독점금지법」 제2조에 의한 신청은 독자적인 청구원인이 된다는 점을 이유로 원고의 청구를 인용하였다. 소비자 소송과는 달리 경쟁자에 의한 사적 소송으로의 권리구제 길을 열어 놓은 것이다.

65) 299 F. 3d 1272 (2002)

3) MetroNet Service 대 U.S. West Communications 사건[66)]

[그림 30] MetroNet v. U.S. West Communication 사건 개요



본건은 MetroNet이 U.S. West Communications를 상대로 하여 공정 접속 의무 위반을 경쟁법 위반으로 적용하여 제기한 민사소송으로, 법원은 MetroNet의 청구를 받아들였다. MetroNet은 U.S. West Communications가 운용하는 Qwest에서 Centrex 서비스를 그 수량에 의해 할인구입하고, 또한 그 자격이 없는 소규모고객에게도 할인하여 전송하여 왔는데, Qwest가 1997년에 할인가격 지침을 변경하여 이 가격지침에 의하면 서비스비용이 400%로 상승하기 때문에 MetroNet는 다른 사업자와는 달리 더 이상 고객에게 할인판매를 할 수 없게 되었다. 법원은 원고가 피고의 고도화된 정보통신산업의 시장지배력이나 배타적 행위로 인하여 손해를 보았다고 판단하였는데, 소위 유예 조항(saving clause)의 명확한 문언이 결여되어있다고 하더라도 거래처별 가격차별행위가 경쟁법 적용제외의 대상은 아닌 것이고, 「독점금지법」에 근거하여 청구대상이 된 행위가 독립적인 유인과 선택에 근거한 규제산업의 상품인 경우에는 그 행위는 「독점금지법」의 엄격조사로 적절하게 심사된다고 하여, Qwest의 시장지배력, 행위의 반경쟁적 효과, 그리고 경쟁법 상의 손해 및 필수설비이론은 본안심사 대상임을 명백히 하였다.

66) 325 F. 3d 1086 (2003)

4) Law Offices of Trinko 대 Bell Atlantic 사건[67]

[그림 31] Trinko v. Bell Atlantic 사건 개요

본건은 Trinko 법률사무소가 「96년 법」제 251조 및 「독점금지법」 2조 등에 위반하는 Bell Atlantic(후에 합병으로 Verizon이 됨)의 행위에 의해 손해를 입었다고 하여 제기한 집단소송으로 3배액 손해배상을 청구한 것이다. 법원은 「독점금지법」 2조 위반의 주장에 대해서 원고 청구를 받아들이지 않았다. 또 전기통신법 상의 청구에 관해서도 원고가 Bell Atlantic의 직접 고객이 아님을 이유로 당사자 적격을 부인하여 청구를 기각했다.

2000년 3월, Bell Atlantic에 대해 경쟁자에 대한 부적절한 접속저해 행위를 개선하기 위한 FCC의 동의심결이 내려져 사업법 상 업무개선이 지시되었는데 그 다음날, Bell Atlantic의 경쟁자인 AT&T의 고객이었던 원고가 필수설비이론이나 독점의 지렛대 이론 등을 들어 피고에 대하여 경쟁법인 「독점금지법」 위반과 사업법인 「전기통신법」 위반을 청구원인으로 소송을 제기한 것이다.

먼저 「전기통신법」 위반의 점에서 보면, 피고가 원고에게 거래를 거절한 것은 일반용으로 소매로 판매되던 서비스가 아닌, 이른바 UNE 서비스로, 사업법 규제에 의한 상호접속 의무는 '네트워크 구성요소의 리스에 관련된 도매시장'에서 발생되는 것이며, 제공되는 UNE는 일반 고객이 아니라 경쟁자에 대해서만 판매되는바, 소비자인 Trniko가 사업법 위반을 이유로 본건 청구를 하는 것은 받아들일 수 없다.

다음으로 경쟁법 위반의 점에서 보면, 연방의회가 ILECs에 대해서

67) 305 F. 3d 89(2002)

네트워크 구성요소에 관련된 UNE 의무를 부과하는 「전기통신법」을 제정했다 하더라도 연방의회는 유보조항이라는 형태로 적용제외 해석을 배제하고 있는바, 「독점금지법」 제2조의 적용에 있어서는, ① 관련 시장에서의 독점력 획득 여부, ② 그 힘이 특정 상품의 경영상 전략이나 역사적 우연 등에 의한 성장이나 발전과는 구별되는 형태로 의도적으로 형성·유지되었음을 증명하여야 한다. 단순한 독점력의 획득이나 그에 부수되는 고가격 설정은 위법이라고 하기에는 부족한 것이다. 기업은 이러한 독점력을 특수한 형태로 고객에게 봉사하는 인프라 구축에 의해서도 획득하는 경우가 있다. 본 건에서는 피고의 거래거절이 여기에 해당하는지 여부가 문제가 되는데, Bell Atlantic의 부적절한 접속이라는 행위에서만 본다면 그 의도가 반경쟁적인지 경쟁적 열의에서 나온 것인지를 판별할 수 없다.

이에 따라 연방대법원은 상고인의 부적절한 접속거절 행위를 「독점금지법」 제2조 위반이라고 할 수 없다고 판시하였고, 필수설비에 대한 접근은 사업법 위반으로 보아야 하고, 추가적인 경쟁법 위반의 이론을 구성하는 것은 불필요하다고 보았다. 사업법의 규제틀이 존재하는 경우, 「독점금지법」 집행에 의한 추가적 이득은 감소하고, 법원이 「독점금지법」 위반으로 추가적인 심사를 하는 것도 설득력이 떨어지는 것이다. 사업법 상 공적 규제의 존재가 묵시의 적용제외를 인정하는 기초가 된다는 종래의 견해가 여전히 유효하지는 않다 하더라도, 사업법 상 공적 규제에서 경쟁을 다루는 요소가 있는지 없는지는 「독점금지법」 2조의 책임범위의 확장을 인정하는지 여부의 판단 시에 고려요소가 된다고 할 것이기 때문이다.

그렇다면, 「통신법」 상 규제에 경쟁을 다루는 요소가 존재하는가를 보면, 「통신법」 상 사업법으로서의 규제 틀은 수익적인 장거리 통신시장에 대한 Verizon의 진입제한을 주요한 위험으로 통제하고 있는 것으로 보인다. 실제로 이 점에서 Verizon은 FCC와 뉴욕주 공익사업위원회에 의해서 각종 제한을 부과받아 왔으며, 전기 OSS 개방에 관하여 FCC 및 주 공익사업위원회에 의해서 시정조치를 받아 왔다. 요컨대 사업법 상 공적 규제의 틀은 「독점금지법」 기능의 유효한 대행자인 것이다.

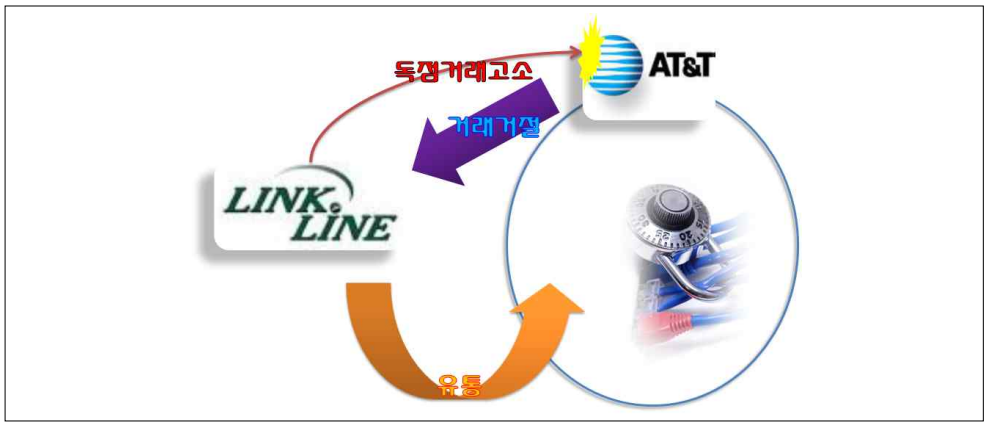
「전기통신법」제251조(c)항(3)호에 근거한 UNE의무의 위반에 관한 주장을 경쟁법 위반으로 이론을 구성하여 제소하는 것은, 고도로 기술

적이며, 또한 상호접속을 구하는 경쟁자와 ILECs 사이의 다수·계속적·복잡한 교섭 때문에 곤란하다. 더구나「독점금지법」에 의한 소송의 진행은 투자를 왜곡하고, 끝없는 소송전을 일으킬 것이다. 또한 동법 제251조 위반의 행위는, 가격설정행위의 적정성을 판단하는 것으로서 법원의 실제적 처리능력을 넘어서며, 위법행위에 대한 유효한 구제조치는 고도로 상세한 계속적 감시 시스템을 요구하는 것으로 경쟁당국은 이러한 UNE 의무의 일상적 집행자로서 유효하지 않다고 할 것이다.

한편으로 「통신법」은 경쟁도입과 촉진이라는 부분에서 경쟁법보다도 보다 한층 적극적 의무를 사업자에게 부과하는데 반하여, 「독점금지법」제2조는 단지 불법인 독점행위를 금지하는데 지나지 않는다. 따라서 양자의 목적을 합성하는 것은 큰 잘못이다. 확실히 경쟁법은 자유경제체제의 대헌장이지만, 그것은 경쟁을 만들어내는 하나의 접근일뿐, 사업 활동의 방법을 바꾸도록 하는 권한을 법원에 부여하는 것은 아니기 때문이다.

5) LinkLine v. AT&T사 등 사건

[그림 32] LinkLine v. AT&T사 등 사건 개요



본 건은 인터넷 서비스 제공자인 LinkLine사가 원고가 되어 기존 지역 전기통신사업자인 SBC California사 및 인터넷 접속서비스를 사용자에게 제공하는 자회사 등(이하 'AT&T사 등')을 제소한 사안이다. 원고는 피고가 소유하고 있는 지역통신망을 도매로 구입하고 그 통신망을 통해서 인터넷 접속서비스를 제공해 왔다. 원고가 서비스를 제공하

기 위해서는 피고의 통신망을 이용하는 것이 필요했는데, 원고는 AT&T사 등이 「독점금지법」제2조에 반해서 지역DSL시장을 독점화하거나, 혹은 당해시장의 독점화를 기도했다고 주장했다.

캘리포니아 연방 중부지방법원은 원고의 청구를 인용하였고, 제9순회연방항소법원은 피고의 항소를 기각하였다. 피고는 이것을 불복함으로써 연방대법원에 상고하였다. 연방대법원은 원심 판결을 파기, 환송하였다.

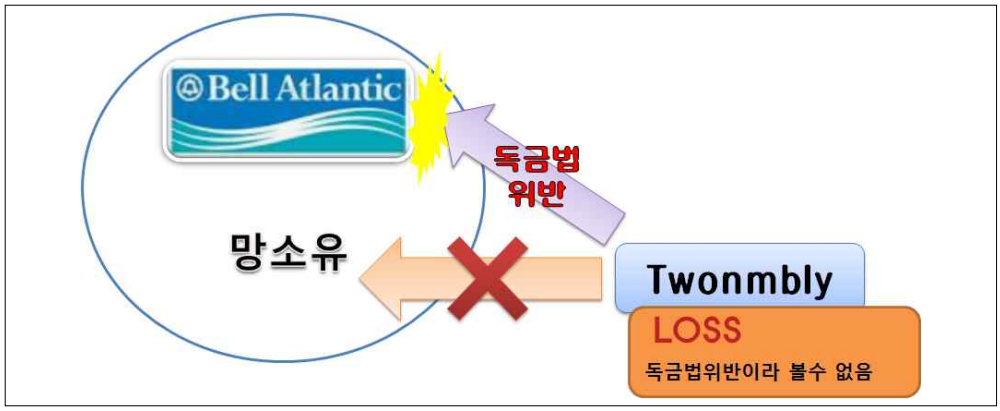
피고가 인터넷 사업자인 원고와 도매 단계에서 거래해야 하는 의무가 「독점금지법」 상 없는 경우에, 단독거래거절 자체를 「독점금지법」 제2조 위반으로 볼 수는 없는 것이다. 사업자는 예외적인 경우를 제외하고, 일시적으로 가격이나, 거래조건과 마찬가지로 거래상대를 선택할 자유가 있고, 또 사업자의 경쟁자에 대한 단독의 거래거절이 반독점적 기업 활동의 책임을 야기하는 예외적인 경우도 있다.

독점적 사업자가 약탈적 가격설정과 같이 순수하게 단독행위에 의해 반 독점적 기업 활동의 책임을 지는 경우가 있는데, 원고는 약탈적 가격설정의 주장입증을 다하지는 못하였다. 피고의 소매가격이 “너무 싸다”라는 것이지만, 적극적인 가격경쟁에 찬물을 끼얹지 않기 위해서 ‘약탈적’ 가격설정에 의한 소송을 인정한 것 이므로, 이에 해당하지 않는 한 가격결정권은 계약 당사자에게 맡겨져 있는 것이다.

원고는 또 사업자가 경쟁자의 이익을 착취한 것이라고 하여 이윤압착(price squeeze) 유형의 단독행위를 청구원인으로 하였는데, 도매단계에서 거래의무가 없고, 소매단계에서 약탈적 가격설정이 없는 경우에, 사업자가 양시장에서의 가격을 경쟁자의 이익마진이 남을 수 있도록 설정하는 의무를 지지는 않으므로, AT&T사 등의 도매가격에 대해서 원고의 주장은 받아들여지지 않은 것이다. 시장에 있어서 반독점적 기업 활동의 거래의무를 가지지 않는 사업자는 경쟁자에 대해서 유리한 조건으로 거래하는 의무도 가지지 않는다. 따라서 원고가 희망하는 도매가격으로 피고가 서비스를 제공하는 것도 의무를 가지고 있지 않는 것이다.

6) Bell Atlantic 대 Twonmbly 사건[68)]

[그림 33] Bell Atlantic v. Twonmbly 사건 개요



본건은, 기존의 지역전화사업자 4사가 공모해서 지역전화서비스 시장에 있어서 거래를 제한한 사안으로, 「독점금지법」 제1조 위반에 근거하여 거래제한에 관한 금지와 3배액 손해배상을 요구했던 집단 민사소송사건이다.[69)] 이에 대해 법원은 원고의 청구를 기각하였다.

Twonmbly와 L. 마카스 2인(X: 원고, 항소인, 피상고인)은 1996. 2. 8. 지역전화와 고속인터넷 서비스의 계약자를 대표해서 지역전화사업자 4사(Y: 피고, 피상소인, 상고인)에 대해서 집단소송을 제기했는데, 그 내용은 기존의 지역전화사업자인 Y가 담합하여, 지역전화요금과 고속 인터넷 서비스요금을 올리고 있다는 것이었다. 즉, ① Y는 경합지역전화사업자의 급속한 진출을 방지하기위해 각 지역에서 '병행행위'(parallel conduct)를 실시하고, 구체적으로는 신규사업자에 대해서 통신접속에 관한 부당한 합의, 열등한 통신망으로 접속, 접속요금의 과대청구, 신규사업자와 고객과의 관계를 방해하는 행위를 하고 있으며, ② Y는 다른 기존의 전화사업자가 맡고 있는 지역에서 상호간에 진입을 회피하여, 경쟁우위의 인접시장에서 '매력적인 사업기회'를 모두 회피하고 있다는 것이다.

이에 대하여 미 연방대법원은 담합을 인정하지 않았고, Souter 대법관은 7대2 다수결 판결을 다음과 같이 정리하였다. 「독점금지법」 제1

68) 550 U.S.544 (2007)
69) 미국법판례연구회, "<판례연구> 미국 반(反) 독점적 기업 활동(Trust)집단소송에서 병행행위에 관한 변론기준을 엄격히 한 연방최고재판소", 제5회 미국법판례연구회. 2008.

조는 부당한 거래제한을 모두 금지하는 것은 아니고, 계약, 결합, 혹은 공모에 의한 제한을 금지하고 있어, 중요한 문제는 경쟁제한행위가 '독립한 의사결정에 의한 것인가, 암묵적 혹은 묵시적 합의에 의한 것' 인가라는 점으로, ① 사업 활동에서의 병행행위는 '합의'를 추정하는 간접 증거이기는 하나, 이것을 가지고 바로 '합의'를 입증하고 「독점금지법」 위반을 구성하는 것이라고 말할 수는 없고, ② '의식적인 병행행위'(conscious parallelism)의 경우 즉, 과점기업(寡占企業)이 마찬가지로 경제적 관심을 갖고 가격이나, 생산수량에 관한 의사결정에 대해서 '상호의존관계'가 있는 것을 인식하고 동일 행동을 따르는 경우에서는 그것이 당연하게 위법이라고 말할 수 없으며, ③ 사실심리에 있어서도 「독점금지법」 제1조의 공모를 주장하는 원고는 병행행위 이상의 증거를 제시하지 않으면 유리한 평결을 요구할 수 없다는 것이다.

본건에서 법원은 '사실상 있을만한 정도의 공모'(plausible conspiracy)는 없다고 판단하였다. 신규진입자에 대한 기존사업자의 저항은 자연스러운 것이고, 지역독점을 계속하려는 것도 각 회사 단독의 대응으로, 만약 실제로 경쟁에 저항하도록 하는 의사결정만으로 담합이 추정된다면 대부분 사업자가 거의 「독점금지법」 제1조 위반을 구성하게 되는 것인 바, 이는 부당하다는 것이다.

통신사업분야에서 지역독점이 존재하는 것이 보통이고, 정부가 인가하고 있던 요금이 기준이 되어 인접 지역의 다른 독점기업도 요금에 대하여 동일한 태도를 취한 결과, 타 지역으로의 진입을 추진하고 있지 않은 것만을 가지고 "현실적으로 있을만한 정도의 공모가 있다"고 담합을 단정할 수는 없는 것이다.

미국 민사소송은 거래나 불법행위로 인한 자신의 손해에 대한 보전에 그치지 않고, 다른 이해관계자를 대표해서 제소하는 집단소송 제도도 두고 있다. 특히, 「독점금지법」에서는 연방 정부, 주(州) 정부의 제소 이외에도 사인(私人)이 제기하는 집단소송이 경쟁질서유지에 의해 소비자의 이익 확보에 커다란 공헌을 하고 있고, 이에 따라 '법의 실현에서 사인의 역할'로서 주목받아왔다.

그럼에도 불구하고「독점금지법」제1조가 금지하는 복수의 사업자에 의한 '합의'를 통한 공동의 거래제한행위를 입증하기 위해서는 복수 사업자에 의해 외형적인 병행행위만으로는 부족하고, 공동성을 표시한

‘플러스 요인’을 제시해야만 하는 것이다.

규제산업은 인가권 행사에 의한 복수사업자의 공동행위가 이미 시장의 폐쇄성을 나타내고, 쉽게 경쟁이 촉진되지 않는다는 배경이 있어, 사인에 의한 경쟁법 실현의 긍정적 측면이 인정될 수 있으나, 독점금지 소송에서도 법률요건의 사실심리에서 입증책임이 원고에게 부여되는 부담은 불가피한 바, 바람직한 경쟁을 촉진한다는 이유로 소송을 무한정으로 지나치게 용인하면, 남소에 의한 폐해가 나타날 것이기 때문이다. 또한 기업 측이 소송 리스크에 관한 사전 및 사후의 비용분을 사전에 매매가격에 전가하는 것 역시 경쟁법의 취지와도 어긋나는 것이다. 따라서 인가권 행사로 인한 적법성 추정을 넘어설 수 있는 원고의 입증이 필수적이라고 할 것이고, 기업이 초래한 경쟁저해라도, 사전에 정부에 의해 해당 침해행위가 검사·승인되거나 정부가 문제의 행위를 인지하여 적극적으로 규제·감독하는 경우, 또는 정부에 의한 공적 규제형성 프로세스로의 진정한 액세스 그 자체에 관해서는, 경쟁법 위반으로 하지 않는다.

3. 미국 경쟁법 위반 판례 분석

가. 소비자 제기 경쟁법 위반 소송

경쟁법 위반 사례는 통신사업자의 보편적 역무 위반을 경쟁법 상 시장지배력 남용금지 위반으로 보아 소송을 제기한 사건들이다. 법원은 통신사업자 승소 판결을 선고하면서, 경쟁자에 대한 접속의무 보장 등의 보편적 역무 의무위반을 경쟁자 아닌 소비자가 경쟁법 위반으로 소송을 제기하는 경우, 절차법적으로 대위권 내지 소송요건으로서의 당사자 적격이 부인된다는 법리를 원용한다. 보편적 역무 위반을 경쟁법상 경쟁촉진 의무위반으로 청구원인으로 구성하여 민사소송을 제기하는 경우 실체법적으로도 권리보호의 법적 이익을 인정하기 어렵다. 광범위한 의무를 설정하고 있는 「96년 법」과 보다 일반적인 경쟁에 관련된 법인 「독점금지법」을 일체화시킴으로써 경쟁법 상의 이론을 지나치게 확대할 수는 없다.

경쟁법 위반이 의미하는 바는 관련 시장에서의 경쟁저해 효과가 인정된다는 뜻이다. 소비자가 경쟁자에 대한 침해를 넘어 전체 시장의 경쟁이 저해된다는 점을 주장, 입증하는 지위에 있다고 보기는 어렵기 때문에, 이러한 경제상, 산업상의 지위가 부정되는 한, 법률상 지위도 인정될 수 없다. Trinko 판결 이후, 법원은 유사한 소송 사안에서, 동판결의 논지에 따라 UNE 의무관련 주장에 관해서는 경쟁법 적용을 허용하지 않는다.

[표 10] 소비자 제기 경쟁법 위반 소송 요약

소송물	원고	피고	적용법규	관계	결과	쟁점
손해배상	Goldwasser	Ameritech	사업법 및 경쟁법	소비자	청구기각	접속의무
손해배상	Trinko	Bell Atlantic	사업법 및 경쟁법	소비자	청구기각	접속의무
손해배상	LinkLine	AT&T	경쟁법	수직관계	청구기각	거래거절 등
손해배상	Bell Atlantic	Twonmbly	경쟁법	소비자	청구기각	담합

나. 경쟁자 제기 경쟁법 위반 소송

경쟁자는 통신사업자의 착취남용, 방해남용, 배제남용 행위를 청구원인으로 소송을 제기할 수 있다. 약탈가격의 설정이나 차별적 가격 설정 행위는 반경쟁적 행위로 경쟁자의 권익을 침해한다. 소송법상 중요한 입증사항은 경쟁저해이다. 경쟁자가 자신의 권익이 침해되었다는 것을 이유로 경쟁법 적용을 주장하려면, 아울러 경쟁저해 효과를 입증해야 하는 것이다.

일반적으로 「독점금지법」에서는 독점자가 경쟁자가 향유하는 편익까지 보장할 의무는 없다. 그러나 개별 경쟁자가 시장 전체의 경쟁저해 효과를 입증하기는 어려운 일이다. 규제기관인 공정위나 법무부가 입증책임을 부담하는 행정소송이나 형사소송과는 달리, 이러한 민사소

송에서의 입증책임의 엄격한 배분은 불충분한 권리보호라는 결과로 귀결될 위험이 있다. 따라서 실제 판결에서 시사된 입증책임 분배를 제도화하여, 입증책임의 전환이나 완화가 필요하다고 할 것이다. 가령 경쟁자 침해를 입증하면 경쟁저해 효과를 추정하여 경쟁법 위반을 인정토록 하고, 시장지배적 사업자가 경쟁이 저해되지 않았다는 사정을 입증을 하면 위 추정이 복멸되도록 입증책임을 전환하는 것이 필요하다. 이러한 절차법적 갱신은 실체법적 권리구제 확대에 이바지 할 것이다.

[표 11] 경쟁자 제기 경쟁법 위반 소송 요약

소송물	원고	피고	적용법규	관계	결과	쟁점
접근허가	Covad	Bell South	경쟁법	수평관계	청구인용	접속의무
손해배상	MetroNet	US West Comm	경쟁법	수평관계	청구인용	접속의무

다. 판례의 동향

미국에서의 규제산업에 대한 사업법과 경쟁법의 관계에 관해서는 결국 법원의 소송절차 상 입증책임 문제로 해소되고 있다.

먼저 경쟁법에 의한 규제가 경쟁 촉진적 내용을 갖는 사업법에 근거한 규제와 관계되는 경우, 재판에서 경쟁법이 규제대상으로 하고 있는 '시장지배력의 형성·유지·강화'라는 점을 입증할 때 사업법 위반의 점을 어떻게 고려해야 하는지가 문제 된다.

경쟁 촉진적 규제 내용이 사업법에 존재하는 경우, 사업법은 경쟁 촉진적 규제를 내용으로 하는 구체적으로 하는 의무를 사업자에게 부과한다. 이 때 해당 의무위반 행위는 반경쟁적 효과를 가진다고 추정할 수 있으며, 정당화 사유에 대한 입증도 사업자가 진다. 아울러 경쟁저해 효과에 배제나 방해 효과 뿐 아니라 착취효과도 고려되어야 한다.

사업법 상 제재보다 경쟁법 상 제재가 가중되어 있는 경우에는 경쟁법 상 구성요건이 보다 엄격히 해석되어야 한다. 형사처벌이나 3배

배상 등 징벌적 손해배상을 청구하는 경우 그 주장입증의 요건이 한층 강화되는 것은 당연하다고 할 것이다.

중지청구에 대한 원고 적격 확대도 필요하다. Goldwasser 사안에서 법원은 원고가 피고의 직접 고객이며, 「독점금지법」 위반이라고 주장할 수 있는 피고의 행위에 의해 부당하게 고액의 서비스요금을 지불당했다고 할 수 있는 한에서, 「독점금지법」 상의 원고적격을 인정한다. 이 때 원고는 제3자인 피고 경쟁자의 소권을 대위할 수 있다. 원고에게 발생할 수 있었던 손해는 경쟁적 시장에서의 경쟁적 가격설정에 의한 이익을 향유할 수 없었던 것으로 피고 경쟁자의 그것과는 별개인 것이다.

V. 일본 통신시장의 규제

1. 일본 사업법의 규제 형식

가. 비대칭규제

일본의 「전기통신사업법」(이하 '사업법')에도 전기통신사업자의 공정경쟁 확보를 위한 규제가 존재한다. 일본의 경우 「사업법」 상의 규제가, 모든 전기통신사업자에 대한 의무와 특정 전기통신사업자에 대해서만 부과되는 의무의 두층으로 구성되어 있다.

전자의 경우, 전기통신사업자인 설비보유자에 대해서 일반적으로 부당차별금지(「사업법」 제6조)나 상호접속의무(법 제32조)를 부과하고 있고, 이 중 상호접속의무에 관해서는, '전기통신서비스의 원활한 제공에 지장이 발생할 우려가 있을 때'나 '해당 접속이 해당 전기통신사업자의 이익을 부당하게 해할 우려가 있을 때' 등을 제외하고는, 다른 전기통신사업자로부터의 상호접속요구에 따라야 한다고 하여, 소위 설비개방의무를 정하고 있다.

후자의 경우는, 특정 전기통신사업자에 대해서만 부과되는 비대칭규제로서, 「사업법」은 '설비'의 과점성 등에 주목하여 지정전기통신설비제도를 도입하고 있다. 즉, 현행의 지정전기통신설비제도는 도/도/부/현별 점유율이 50%를 초과하는 가입자회선을 갖는 것을 요건으로, 가입자 회선 및 이와 일체로 하여 설치되는 고정통신용 전기통신설비를 제1종 지정전기통신설비(이하 '1종 지정설비')로 지정하였다.

해당 1종 지정설비를 갖는 사업자에게는 ① 접속 업무에 관해서 알게 된 정보의 목적 외 이용·제공의 금지, ② 전기통신서비스에 있어 특정 전기통신사업자에 대한 부당한 차별적인 취급·이익부여 또는 부당한 불리한 취급·불이익 부여의 금지, ③ 다른 전기통신사업자·전기통신설비의 제조업자·판매업자의 업무에 대한 부당한 규율·간섭의 금지의 세 가지 유형이 금지행위로서 요구된다. 또한 특정관계자와의 사이에서 임원의 겸임을 금지하고, 접속이나 전기통신서비스에 관련된

주변적인 업무에 관해서도 특정관계 사업자와 비교해서 불공평하게 취급하는 것을 원칙적으로 금지하는 등 해당 특정관계 사업자와의 방어벽 규제가 부과되고 있다.

또 보장계약 약관에 근거한 프라이스 캡 규제 등 서비스 규제, 접속약관의 인가 등 접속관련 규제가 부과되고, 오픈 액세스를 위한 각종 엄격한 규제가 행해지고 있다. 이들은 1종 지정설비의 필수설비성에 주목한 해당 설비보유자의 시장지배적 지위에 관련된 규제라고 할 수 있다.

이동통신에 관해서도 업무구역 별로 점유율이 10%를 초과하는 단말 설비는 제2종 지정전기설비로 지정되고, 해당 제2종 지정전기설비를 갖는 사업자에게는 제1종 지정전기설비를 갖는 사업자와 마찬가지로, 전술한 금지행위의 세 유형이 규정되는 동시에, 접속약관의 작성 및 사전신고가 법정되고 있다.

또한 '전기통신사업 분야에서의 경쟁 촉진에 관한 지침'에 의해, 행위규제가 금지행위별로 유형화되어 예시되는 동시에, 'NTT동서(토자이)의 업무범위 확대의 인가에 관련된 공정경쟁가이드라인'을 정하고, NTT동서의 업무범위 확대 인가에 관한 NTT법의 운용방침을 사전에 명확화 함으로써 지역통신시장에서의 NTT동서의 시장지배력 레버리지를 방지하려고 하고 있다.

「사업법」은 1종 지정설비나 제2종 지정전기통신설비(이하, '2종 지정설비')로서 지정된 설비의 설비개방 규칙을 설정하고, 그 안에서 사업자 간 서비스를 경쟁시키고자 한다. 이는 구미의 경쟁법의 문맥에서 나오는 'leveling the field'로서, 요컨대 경쟁게임의 룰 그 자체가 공정하게 설계되도록 하는 공정게임의 설계를 지향하는 것이다.

이 점에 관해, 전기통신산업의 감독관청인 총무성은 소위 설비개방에 관하여 '설비경쟁과 서비스경쟁의 적정한 균형론'을 택하고 있다. 즉 유선망의 설비개방에 의해 경쟁의 촉진을 꾀하는 한편, NTT동서의 설비개방만을 철저히 하면 NTT동서의 경쟁사업자는 NTT동서의 설비를 사용하고, 경쟁사업자 스스로는 설비투자를 하지 않게 된다. 여기서는 NTT동서의 설비투자 인센티브를 분리하여 균형을 배려하고 있다. 또 1종 지정설비로서 설비개방의무가 부가되고 있는 유선망 뿐 아니라 이동망에 관해서도 '설비경쟁과 서비스경쟁의 적정한 균형'을 꾀해야 한

다는 것이 총무성의 입장이다.

그러나 '설비경쟁과 서비스경쟁의 적정한 균형'에는 주의가 필요하다. 규제산업인 전기통신사업이라도, 사적 자치가 원칙이며, 지정전기통신설비에 관한 설비개방 룰은 이 사적 자치를 특별한 사정 때문에 수정한 것이기 때문이다.

전기통신산업 분야의 대폭적인 규제완화의 진전은 기술혁신에 의해 이루어졌다. 현재도 인터넷을 중심으로 한 기술혁신이 산업을 변화시켜 방송, 전화, 인터넷 등의 기존 분야를 융합시키고 있다. 일본 전기통신사업 분야의 제도개혁의 주요 변천 내용은 다음의 표와 같다.

[표 12] 일본 「전기통신사업법」의 비대칭 규제

시기	참여/퇴출 규제	요금/약관 규제	상호접속규제
1985년 4월	전기통신사업법 성립; 일본전신전화주식회사(NTT) 설립		
	o 참여허가제	o 요금·계약약관 인가제	o 접속협정 인가제 (사업자 간 협의를 전제)
1997년 11월	o 참여허가기준 중 수급조정 조항의 철폐		o 접속의 의무화 o 지정전기통신설비제도 (고정계)의 도입
1998년 11월		o 요금인가제에서 원칙적 사전신고제로 이행 o NTT의 전화 등에 프라이스 캡 규제의 도입	
1999년 7월	NTT 재편(주식회사, 동서지역회사, 장거리통신회사)		
2000년			o 장기증분비용방식의 도입 o 가입자 회선의 언번들화

			o 콜로케이션 룰의 정비
2001년 11월		o 계약약관인가제에서 사전신고로 이행	o 제2종지정설비(이동계)의 도입 o 시장지배력을 갖는 사업자에 대한 행동규제의 도입 o 접속협정인가제에서 신고제로 이행
2004년 4월	o 참여허가제에서 등록·신고제로 이행	o 요금·계약약관 신고제 원칙 폐지(기초적 전기 통신 서비스 등은 제외)	o 접속협정신고제의 폐지

나. 업종 종단적 규제

전기통신사업 분야의 핵심 개념은 네트워크 외부성, 상호접속, 접속요금이다. 우선 네트워크 외부성으로 소비자가 늘면 늘수록 소비자의 편익은 높아진다. 또한 복수의 네트워크가 있는 경우, 상호접속에 의해 양 네트워크에 가입하고 있는 소비자의 효용은 높아지게 된다. 그 때문에 필수시설을 독점적으로 보유하여 길목을 선점한 네트워크에 접속할 필요가 생긴다. 따라서 이러한 설비를 갖고 있는 사업자는 규제에 의해 개방의무를 지고, 그 접속에 대해서 어떤 접속요금을 부과할지가 시장에서의 경쟁의 방향을 결정하는 큰 요인이 된다. 신규기업의 참여를 막을 정도의 고액의 접속요금을 부과하는 일이 없도록 NTT동서 지역망으로의 접속요금은 인가제로 되어있다.

휴대전화의 판매방법은 수직적 거래제한의 이론에서 볼 때 흥미로운 현상이다. 특히 무료나 마찬가지로 1엔의 가격에 판매되는 기종의 경우가 그렇다. NTT도코모 등의 전화회사는 휴대전화를 보유한 소비자의 통화료 지불에서 지속적인 이익을 올릴 수 있으므로, 가능한 많은 소비자들이 자사의 네트워크에 가입하도록 하기 위해서 휴대전화 보급에 있어서 휴대전화회사에게 제조비용이나 개발비용을 보상하거나 판매회사에게 장려금을 지불하고 있는 경우가 종종 있고, 그 때문에 극단

적으로 낮은 휴대전화의 가격이 성립되는 것이다. 이 같이 소비자에게 침투하는 신제품 할인가인 도입가격(introductory offer)에는 많은 이론이 있으나, 전화회사와 휴대전화 제조사 및 소매업이라는 네트워크 산업과 수직적인 관계에 관해서는 그다지 많이 논의되지는 않고 있다. 네트워크 외부성의 존재가 기업의 도입가격과 관련이 있으므로 독점기업이며 수직적인 관계에서의 네트워크 경쟁이라는 요인이 함께 분석되어야 한다.

신제품 도입가격의 장려금은 결국은 기존 네트워크에 들어온 가입자가 부담하는 통화료에서 지불되는 바, 이러한 신규가입자의 장점과 기존 가입자 사이의 비용부담이 적절하게 행해지고 있는지의 이슈와 경제이론적인 최적의 통화료와 도입가격의 존재에 관한 이슈들에 있어서, 네트워크 산업과 그 하드웨어 제조업과의 관계에 관한 통합적 규제가 필요하다. 또한 하류(downstream)의 고객획득 경쟁은 상류(upstream)의 백본의 혼잡을 초래한다. 따라서 하류에서 과잉참여나 투자가 행해지고 있지 않은지 하류의 경쟁과 상류의 설비와의 정합성도 규제에 반영해야 한다.

일본의 고정 이동통신최대사업자는 NTT그룹의 일원이다. 기업 수에서 알 수 있듯이 이동통신시장은 고도로 과점적이다. 이러한 시장구조가 경제 전체에서 보았을 때 바람직한지는 별론으로 하고 막대한 기존의 설비를 갖고 있는 비중이 큰 기업에게 특별한 규제를 행하는 것은 이미 필수설비에 대한 접속의무 등 비대칭적인 방법을 이용하여 많은 국가에서 이루어지고 있다.

[표 13] 일본의 업종 종단적 규제

	일본
유선통신최대사업자	NTT
이동통신최대사업자	NTT 도코모
이동통신 면허보유자수	4사

다. 규제의 독립성

전기통신산업에 대해서 그 감독관청인 총무성이 규제를 하는 것에 비해, 경쟁정책은 다양한 시장에 적응할 수 있는 몇 개의 원리에 근거하여 시장 메커니즘을 유효하게 움직일 수 있는 정책이라는 특징을 갖는다. 우선 규제당국은 경쟁정책당국보다도 포괄적인 인허가권을 갖고 있어, 자유화 이전에는 세밀한 업종규제를 하고 있었다. 또한 명시적인 법률이나 통달(通達)을 넘어서 행정지도에 의한 재량적인 규제가 행해지는 일도 있는 바, 이는 규제 상 세밀한 대처가 가능한 반면, 투명성, 공평성 및 피규제기업의 예측가능성을 손상하는 면이 있음을 부정할 수 없다.

또한 규제당국은 참여기업의 심사나 가격의 인가 등 경쟁이 행해지기 전에 사전적 규제수법에 의한다는 특징이 있다. 규제당국은 사전에 사업자가 선택할 수 있는 행동을 정의하는 반면, 경쟁정책 당국은 반경쟁적인 행동이 취해지지 않는지를 확인하는 상호보완적인 역할을 구성하고 있는 것이다.

한편 규제당국은 피규제산업에 관한 전문가를 많이 보유하고 있어 계속적으로 그 산업을 모니터하고 있기 때문에 경쟁정책 당국보다도 정보 상 우위에 있는데, 그것이 반드시 뛰어난 규제를 의미하는 것은 아니다. 전문성에 의해 피규제산업과 규제당국 간 관계에서 밀착이 일어나 '규제의 포로'(regulatory capture)가 될 가능성이 있다. 관료가 피규제기업을 적당히 처리해 주는 보상으로 퇴직 후에 그를 그 기업에서 낙하산으로 채용하는 특혜를 줄 수도 있는 것이다.

이러한 이유로 일본 전기통신산업에 대한 규제의 독립성에 대해서 큰 위기감이 드러난다. 우선 비대칭규제의 대상이 되는 NTT그룹의 경우, 현재도 역시 일본정부가 NTT의 대주주이다. 정부 내에서의 부문이 다르다고는 해도 규제주체가 피규제주체의 주식을 대량 보유하고 있는 상황은 시급히 개선할 필요가 있다고 할 것이다. 경쟁정책의 집행주체인 공정거래위원회는 2003년에 총무성에서 내각부로 이행하였다. 총무성 내에서 규제주체와 경쟁정책 주체가 동거하고 있었던 바, 규제와 경쟁정책의 긴장관계가 바람직한 경쟁 환경 만들기에 필수적이라는 경험칙과 무관치 않다.

라. 중복 규제의 실제

1) 진입규제

소프트뱅크에 의한 유선전화와 휴대전화 분야로의 참여표명이나 영국의 통신대기업 케이블·엔드·와이어리스(C&W)의 일본시장으로부터의 철수 등 참여나 퇴출이 극심한 것은 이 시장의 하나의 특징으로, 요금 그 자체나 요금설정 룰을 만드는 것 외에 접속공사 절차의 공정성도 중요한 문제가 된다. 이는 인터넷에 접속함으로써 단일한 네트워크에 가입할 수 있고 어느 통신사업자에 들어가든지 큰 차이가 없는 상황에서는 기기 설정이나 절차에서의 번잡함이 소비자에게 미치는 영향이 크기 때문이다. 2003년 7월, NTT동일본(히가시)은 인터넷 접속 신청 수신을 지연시키는 등으로 신규참여를 방해한 혐의로 공정거래위원회로부터 현장검사를 받았다. NTT동일본은 이러한 상황을 2000년 10월에도 만든 바 있다.

이처럼 기술혁신에 의한 진입장벽의 저하 및 그에 따른 기업의 신규참여가 용이해짐에 따라 경쟁이 격화되고 비효율적인 기업이 시장으로부터 퇴출되는 일들이 끊임없이 일어나게 되면서 이러한 다이나믹한 경쟁에 대응하여 종래 있었던 전화회선 설비를 갖는 1종 사업자와 회선설비를 갖지 못한 2종사업자의 구분을 철폐하는 등 진입규제가 대폭 완화되었다.

극심한 시장 환경 변화에 대응하여 경쟁을 유지하는 것이 중요하다는 것은 말할 것이 없으나, 그러한 정책 안에서도 진입규제는 여전히 중요한 지위를 차지한다. 이러한 규제에 있어서는 현저한 시장지배력이 있는 기업의 규제에 더해 투명성 있는 규제체계를 구축하여 참여기업의 예측가능성을 높일 필요가 있게 된다.

2) 약관 규제

전기통신산업 분야에서 가격이나 서비스에 대한 경쟁뿐 아니라, 어느 네트워크에 들어갈 것인가도 중요한 경쟁의 국면이 된다. 기술혁신에 의해서 시장에 대한 참여가 용이해졌다고 하더라도 여전히 자연 독점적 성질은 남아있는바, 필수시설을 독점적으로 보유하고 있는 사업자가 다른 사업자의 배제를 위해 접속을 거부하는 것을 방지하기 위하여 다른 사업자의 접속을 의무화할 필요가 있고, 이러한 기반시설을 유지·확장하기 위해 다른 사업자가 지불하는 접속요금을 적절하게 설정하여야 할 필요가 있다. 이에 현재 일본 사업법은 NTT동서의 접속요금에 대하여 인가제를 두고 있으며, 인가요금 약관에 대한 적법성 추정의 원칙 역시 인정된다.

또한 휴대전화의 접속조건을 정하는 '제2종 지정전기통신설비제도'는 계약수가 적은 사업자가 계약수가 많은 사업자와 접속교섭을 할 때, 불리해지지 않도록 25% 이상 점유하는 사업자를 2종 지정사업자로 정하고, 접속약관이나 접속료를 정하여 총무성에 신고하도록 의무화하고 있다. 이에 의하면, 2종 지정사업자는 접속약관에 따르지 않으면 접속에 관한 협정을 체결할 수 없다.

마. 사업법의 진화

1) 일본에서의 네트워크 중립성

일본에서는 미국과 상황이 조금 달라서, 길목 설비를 보유하는 NTT동서에 대한 비대칭 규제, 즉 시장지배력 규제가 유효하게 기능하여 왔고, 네트워크에 대한 오픈 액세스 의무, 부당한 차별적 취급의 금지의무 등을 포함하여 그 시장지배력을 반경쟁적으로 행사할 여지가 크게 제한되어 왔으며, 경쟁적인 ISP시장이 성립되어 왔다.

2007년 공표된 '네트워크 중립성에 관한 간담회 보고서'에서 검토한 내용을 보면, ① 네트워크 비용 부담의 공평성, ② 네트워크 이용의 공

평성이라는 2가지 관점에서 망라하여 논점의 정리와 검토가 이루어졌다. 주요 검토항목은 (a) 트래픽 증가와 대역제어의 현황, (b) NTT동서의 차세대 네트워크 오픈화 의무(접속룰의 검토), (c) IP화의 진전 및 수평적/수직적 시장통합화에 따른 시장지배력 규제의 수정이다.

이들 항목들은 모두 네트워크 사업자 및 ISP에 의한 차별행위에 관련된다. 특히 차세대 네트워크는 통신사업자가 일원적으로 트래픽을 관리하고, 또한 서비스 품질을 분류하여 서비스를 제공 할 수 있는(즉, 사용자별로 패킷 유통에 우선순위를 둘 수 있는) 통합관리형 IP망으로, 통신사업자의 C/A사업자와 사용자에 대한 차별적 취급(서비스 품질에 따른 차별화를 포함)을 가능하게 하는 아키텍쳐이다.

NTT동서의 차세대 통신망(Next Generation Networking: NGN)에 관해서는, 접속사업자 입장에서 사업전개 상의 불가결성이나 이용자 편리의 확보라는 관점에서 불가결성이 존재하는 것에 비추어 제1종 지정설비로 지정되고, 중계국 접속기능, 수용국 접속기능, 관문교환기 접속기능 등 기능의 요소별 분리접속이 실현되고 있는 바, NGN 중 어느 범위를 어떤 조건에서 오픈화 할지라는 문제는 설비투자에 관련된 충분한 경제적 인센티브 확보의 문제와도 밀접하게 관련되고 설비경쟁과 서비스 경쟁과의 적절한 균형 확보가 요구된다고 할 것이다.

2) 공평성

다량이용자(heavy user)나 리치콘텐츠(rich contents)를 전송하는 C/A사업자에 대한 추가과금의 시비가 논쟁이 되고 있다. 특히 FCC 신규칙에서 부당한 차별행위가 될 우려가 지적된 C/A사업자에 대한 추가 과금에 관한 보고서에서 ① C/A시장과 ISP시장의 쌍방 시장에서 충분한 경쟁이 실현되고 있는 점, ② C/A사업자가 ISP 등을 바꾸기 위한 전환비용도 낮은 수준임을 전제로 한 후, '콘텐츠 제공자에 의한 리치 콘텐츠의 배신에 관해서 추가요금의 지불을 원칙으로 하는 것은 적당하지 않고, 어디까지나 콘텐츠 제공자와 ISP사이의 당사자 간 협의에 위임하는 것이 적당하다'고 기술하는 데 그치고 있는바, 이와 같은 결론이 나오는 것은 일본 C/A시장 및 ISP시장의 쌍방에서 활발한 경쟁이 성립되고 있다는 인식이 있기 때문으로 일응 수긍이 간다고 할 것

이다.

C/A사업자와 ISP 간 정보의 비대칭성 및 ISP의 '게이트키퍼'성에 관해서는 주의를 요한다. ISP의 시장 점유의 대소에 관계없이 해당 ISP가 그 가입 최종 소비자에 대한 C/A 서비스 제공의 게이트키퍼인 점은 바뀌지 않는다. 특히 C/A사업자 입장에서 자기 트래픽 전송에 관련된 서비스 품질 저하의 원인 특정이 곤란한 가운데, 앞으로 네트워크 혼잡 문제가 보다 심각화 되고, 최종소비자에 대한 요금이 정량제 과금으로의 단계적 이행이 실현되는 경우에도, 유상에 의한 전송 우선화를 실시하는 ISP에 의해 고액의 과금을 강요당할 우려는 있다. 이 점에서 정보의 비대칭성 해소를 위한 투명성 규제 및 공정한 경쟁 환경을 확보한 상태에서의 사업법 및 「독점금지법」의 역할이 기대된다고 할 것이다.

3) 투명성

2008년 제정된 이후 2010년 개정된 '대역제어의 운용기준에 관한 가이드라인'에서는 대역제어의 운용방침에 관해서 '최종 소비자에 충분한 정보개시를 해야 한다'고 하고, 또한 '제어에 해당하는 기준, 제어의 대상이 되는 시간대 및 장소 등과 같은 사항에 관해서, '「사업법」의 소비자보호 룰에 관한 가이드라인'도 참조하면서, 주지해야 한다.'고 표명하는 등, 최종 소비자에게 정보의 개시를 철저히 하도록 보다 강한 표현으로 수정되었다. 한편 C/A사업자에게 정보를 개시하는 것에 관해서는 '최종 소비자에게 개시하는 정보와 같은 정보를 널리 개시하는 것이 바람직하다'고 기술하는데 그친다.

FCC 신규칙의 사고로부터도 알 수 있듯이, ISP네트워크의 DPT지에 위치하는 최종 소비자나 C/A사업자와의 사이에는 명백한 정보의 비대칭성이 존재한다. 일본시장에서는 ISP간 활발한 경쟁이 성립되고 있다고 해도 ISP간 전환비용이 높아지면 기대되는 경쟁이 가용하지 않을 가능성이 있으며, 또한 최종 소비자나 C/A사업자 측에서는 서비스 품질 저하가 무엇에 기인하는지 인식할 수 없다는 문제가 있다.

이 점에서 FCC 신규칙이 브로드밴드 사업자에 대한 투명성 확보를

기본 룰의 하나로서 의무화한 것이 일본 규제에 시사하는 바는 크다. FCC 신규칙의 정보개시의무에서는 네트워크 관리(혼잡관리, 어플리케이션별 관리행위, 접속가능 단말 룰, 안전성), 품질특성(사용기술, 접속속도, 등시성이 높은 콘텐츠로의 적합성), 상업적 조건(가격, 프라이버시 보호방침, 분쟁해결) 등의 내용이 개시대상으로서 예시되고, 정보개시는 사용자, C/A사업자, 및 FCC가 자유로이 열람할 수 있는 방법에 의한 실시가 의무화된다. 또 FCC는 모니터링의 필요에 따라서 개별적으로 추가적 정보를 요구할 수 있다.

한편 일본에서는 사업자단체에 의한 가이드라인이라는 형태로 투명성 확보가 꾀해지는데 그치고, 또한 그 목적에서도 최종 소비자 보호에 중심을 두고 있다. 그러나 브로드밴드 시장에서의 공정경쟁의 촉진 및 네트워크 엣지에서의 이노베이션이나 투자의 인센티브 확보라는 관점에서는 최종 소비자와 마찬가지로, C/A사업자에 대해서도 충분한 정보개시가 필요하다. 또 이는 tearing에 관한 간담회 보고서의 결론의 전제조건이기도 하다. 최근 기술혁신에 의해 개별 트래픽 패턴 분석 등을 통해서 개별 콘텐츠·어플리케이션을 식별하는 기술(소위 'DPI(Deep Packet Inspection)기술')이 점차 개발되는 가운데, 앞으로 ISP 및 네트워크 사업자에 대해서, 보다 엄격한 정보개시의 의무가 필요하게 될 것이다.

2. 일본의 전기통신사업 관련 구체적 사례

가. 요약

[표 14] 일본전기통신사업 관련판결 요약

소의 종류	사안	청구취지	청구원인	판결의요지
행정	KDDI v. 총무성	NTT토자이의 접속요금 인상에 대한 인가 취소청구	인가에 이르는 정차가 불투명하고, NTT토자이가 동일한 접속료를 설정하거나	유선 전화 시장의 급격한 변화로 인한 NTT의 수익성 악화에 대응하는 요금인

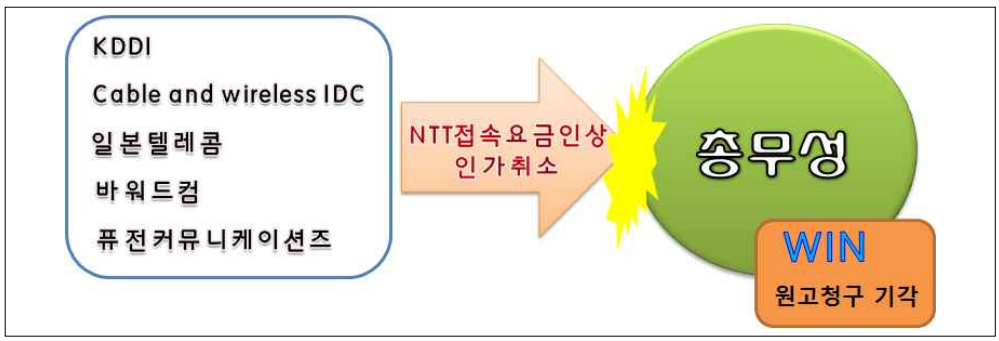
			사후정산제도 등을 도입하는 것은 불합리 하다.	상으로, 시장 변화에 따른 산정 기준의 변화, 유니버셜 서비스로서 동일한 접속료 설정, 실적을 기준으로 한 사후 정산제 등이 위법하다고 할 수 없다(청구기각).
민사	일본 통신 v. NTT Docomo	2006년도 계약당시의 접속료 산정식에 의한 접속료 지불 의무의 확인 및, 2010·2011년도의 과지불분의 반환을 청구	계약 체결 시에 접속료 산정식에 대한 합의가 있었으므로, 2010년도에 피고가 위 산정식을 일방적으로 변경한 것은 위법하다.	현재 심리 중에 있음.
행정	NTT v. JFTC	피고가 원고의 FTTH서비스 'B플랫'등에 대한 시정조치의 취소를 청구	피고가 원고의 FTTH서비스 'B플랫'과 ' B플랫·패밀리 타입'이 「독점금지법」에 위반된다고 하여 내린 시정조치가 위법하다.	원고는 브로드밴드 서비스에 관한 광섭유 시설을 독점적으로 보유하고 있는 사업자로서, 원고가 경쟁사업자에게 부당하게 높은 접속료를 요구하는 한편, 자신의 가입자에게는 낮은 가격으로 위 서비스를 제공하여, 경쟁사업자의 신규진입 및 사업 활동을

				방해한 것은 「독점금지법」 위반에 해당한다 (청구기각).

나. 구체적인 내용.

1) KDDI 대 총무성 사건

[그림 34] KDDI v. 총무성 사건 개요



본 사안은 2004년 7월, KDDI 등의 신전전 5사(KDDI, 케이블 엔드 와이어리스 IDC, 일본텔레컴, 바워드컴, 퓨젼 커뮤니케이션즈)가 총무성을 상대로 NTT 접속요금인상의 인가취소를 구하는 행정소송이다. 새로운 요금은 평균 5%정도 인상될 예정이었는데, 인가에 이르는 절차의 불투명성, 요금산정의 근거가 되는 비용의 부적절, 접속요금 인상이 인가일시 이전에 적용됨 등이 위 청구의 이유인 바, 법원은 원고의 청구를 받아들이지 않았다.

접속료는 전화국과 가정을 연결하는 단말 회선을 갖지 못한 위 신전전이 NTT 회선을 이용할 때에 지불하는 요금으로, 기존 회선을 이용함으로써 신전전은 막대한 설비투자부담을 피할 수 있었으므로, 이제까지 신전전이 시장 참여를 할 수 있었다. 그런데 NTT 유선전화의 이용이 휴대전화나 IP전화 및 인터넷 이용전화 등의 급속한 보급으로 감소일로에 있어 NTT의 수익성 악화를 염려한 총무성이 2003년 4월부터

접속료 인상을 인정했기 때문에 신전전이 소송을 시작하였다.

과거 일관되게 인하해 온 접속료가 이번 산정에서 인상되게 된 이유를 살펴보면 접속료의 산정방식과 관계가 있다. 현재 접속료 산정은 2000년도부터 채용된 '장기증분비용방식(LRIC)'에 기초한 것으로, 현 시점에서 최신 설비와 기술에 의한 접속망을 구축했다고 가정하고 산정한 비용의 합계를 총 통화량으로 나누어 접속료를 산정하는 것이다. 그 주요 목적은 시내전화 서비스를 독점적으로 운영해 온 NTT동서의 경영상 비효율을 배제하는 것에 있다.

그런데 LRIC는 현실성 없는 가정에 의한 계산으로 현실과의 사이에 괴리가 발생한다. 이같이 최신 설비와 기술에 근거한 접속 비용의 산정이 용인되는 이유 중 하나는 지배적 사업자인 NTT동서의 비효율을 배제하는 합리적 방법을 달리 찾을 수 없기 때문이다. 또한 신규참여사업자가 스스로 설비를 설치하여 시내통신사업에 참여하는 경우에는 최신 설비와 기술을 이용하겠지만, 기존 사업자들 역시 최신 설비와 기술에 의해 비용을 산정할 인센티브가 있기 때문이다.

현실을 살펴보면, NTT동서의 구역 내 통화의 통신량은 가입전화, 시간, ISDN을 포함하여 2000년도를 정점으로 2001년도에는 -23.5%, 2002년도에는 -30.5%로 급감하였다. 인터넷 접속이 ADSL이나 CATV모뎀 등 고속 상시접속방식으로 바뀌고, 휴대전화의 보급진전, 이메일의 이용확대, IP전화의 급증 등으로 유선전화의 계약수가 감소하는 등 시장의 구조에 변화가 급격히 진행된 것이다. 그러나 LRIC모델이 이 같은 시장의 구조변화에 따른 통신량의 급감을 반영하지 못하여 현실과의 괴리가 점차 커져가고 있었는데, 그것을 계속 무시해 온 규제당국과 이러한 가능성을 예견했음에도 부당한 산정방식에 이의를 신청하지 않은 신전전 측에 문제가 있었던 것이다.

NTT동서의 동일접속료의 경우, NTT동서가 별도로 접속료를 산정하면 서회사의 접속료가 약 30%가 인상되는데, 이 같은 큰 격차로 인해 동서 영역에서 이용요금의 격차가 발생할 위험이 있어 NTT동서의 접속료를 동일접속료로 하고, 비용이 낮은 동회사로부터 비용이 높은 서회사로 자금지원이 되도록 법제화한 것이다. NTT동서는 NTT가 10% 출자한 별도의 회사이므로 접속료도 별도로 결정해도 무방하다 할 수 있다. 아울러 2003/2004년도에 적용된 접속료 산정의 기초가 되고 있는

통신량은 2001년도 하반기와 2002년도 상반기 실적치를 통년화한 것으로 전화서비스의 통신량은 매년도 20~30% 감소하고 있고 이 경향은 구조적인 변화에 근거한 것으로 앞으로도 계속될 가능성이 높은 이상, 과거의 실적을 기초 통신량으로 하는 실적치에 의한 정산은 어쩔 수 없는 것이라고 할 것이다.

신전전 측은 정산에 있어서 본래 접속료에 포함되어서는 안 되는 NTS(non-traffic-sensitive)비용이 접속료에 포함되어 있는 등, 적정한 원가에 근거하지 않은 접속료의 설정은 사업법 위반이라고 주장하였는데, 여기서 말하는 NTS비용은 통신량과 관계없이 변동하는 비용으로서 구체적으로는 RT(remote terminal) 관련 비용을 가리키는 것으로 개념적으로는 NTS비용은 기본료이며 그 이외에는 통화료나 접속료에서 회수하는 것이 바람직하다.

NST비용을 접속료에 포함시키지 않는다고 하면, 그만큼 기본료를 인상할 필요가 있다. 그러나 기본료는 통화 이용의 많고 적음에 관계없이, 전화 이용계약을 하면 정액으로 지불할 필요가 있는 요금인 반면, 통화료나 접속료는 통화 이용회수나 시간에 따라서 지불하는 요금으로 소비자는 통화 회수나 시간으로 컨트롤이 가능한바, 종래부터 기본료 부담이 커지지 않도록 NTS비용의 일부를 통화료나 접속료에 포함하여 계속 회수하고 있으며, 이를 위법이라고는 할 수 없다.

본 사건은 행정소송의 역할에 한계가 있음을 보여주는 사안이다. 신전전이 이길 승산이 낮은 소송까지 하며 감독관청에 반기를 든 것은 총무성의 통신행정의 무게중심이 접속료 인상을 계기로 NTT 의존으로 가는 것을 견제할 목적이었다고 평가할 수 있다.[70] 하지만 문제의 본질은 접속료 산정의 기초가 되는 LRIC모델이 시장의 구조변화에 따른 통신량의 급격한 감소에 의해 기능적 합리성을 상실했다는 점이다. 따라서 요금 자체를 다투는 구체적 소송에서 통신정책적 관점이 반영된 인가 재량을 극복하기는 어렵다고 할 것이다. 가령 이번 소송이 규제당국을 견제할 목적이라고 하더라도, 요금결정이 적법절차에 의하여 이루어지는 정책 전환의 과정에서 행해진 이상, 이 결정을 경직된 법적 소송의 장에서 다투는 것은 사업법 규제의 포괄성과 전면성을 적정하게 평가한 경영전략으로 평가할 수는 없다.

70) "'NTT 접속료' 제소", 일본경제신문, 2003.7.22.

규제당국과 사업자간 소송에서 경성 규범이 시장의 급격한 변화에 관한 모든 상황을 통제할 수 없는 것은 당연하며, 그 간극을 메우기 위해 행정재량과 정책판단의 유효성이 유효하게 기능한다는 것 역시 당연하다고 할 것인바, 일본에서 규제당국과 사업자 사이의 관계는 법률을 통하여, 그러나 법률을 넘어서는 유기적 관계로 진화되며 새롭게 형성되고 있다고 할 것이다.

2) 일본통신 대 NTT 도코모 사건[71)]

[그림 35] 일본통신 v. NTT 도코모 사건 개요

본 사건은 일본통신이 2012. 4. 19. NTT도코모를 상대로 2010년도와 2011년도의 패킷 접속료 산정식이 총무성의 산정을 기초로 한 계약에 위반한다고 하여, 산정식의 변경 등을 구하는 소를 동경지방법원에 제기한 민사소송으로 현재 심리 중에 있다.

일본통신이 문제시 하는 것은 접속료의 산정식이다. 동사는 2006년 11월에 NTT도코모에 상호접속을 신청하였는데 교섭이 결렬되어, 2007년 7월 총무대신에게 산정을 신청하였고, 그 결과 '원가+적정 이윤'의 가격에 NTT도코모의 통신망을 빌릴 권리를 얻었다. 이에 근거하여 동사는 2008년8월에 NTT도코모의 통신망을 활용한 서비스를 개시하였다.

2008년도와 2009년도는 당시 합의한 산정식으로 접속료를 결정하여 NTT도코모에게 지불하였으나, 2010년도부터 NTT 도코모가 접속료를

71) 조민행·이윤제·유완석, 『중복규제의 현황과 개선방안 연구』, 법제처, 2008.12. p.6

올리는 방향으로 산정식을 변경했다는 것이다. NTT도코모의 사정에 따라 산정식을 바꿀 수 있도록 하면 '접속료를 자의로 올릴수 있기' 때문에 불합리하다고 일본통신이 항의한데 대하여, NTT도코모 측이 접속을 중단하겠다는 통고를 하여 어쩔 수 없이 합의하지 않은 산정식에 따른 접속료를 NTT도코모에 지불해 왔다는 것이다.

일본통신이 이번 소송에서 NTT도코모에 요청하고 있는 것은 ① 2008년6월에 NTT도코모와 합의한 산정식으로 접속료를 지불하는 지위에 있음을 확인하고, ② 합의한 산정식에 의한 접속료를 총무성에 재신고하고, ③ 2010년도와 2011년도 접속료의 과지불분을 반환하라는 것이었다.

NTT도코모는 「사업법」상의 2종 지정설비를 보유하는 사업자로서 그 접속료 등을 규정한 접속약관을 신고하여야 한다. 총무성이 정하는 '제2종 지정전기통신설비제도의 운용에 관한 가이드라인'이 접속료 산정식을 명확하게 정하고 있지 않는 바, 총무대신 산정에서도 접속료의 구체적인 금액까지는 계산하지 않고 일본통신과 NTT도코모의 협의에 의해서 정하였던 것이다.

NTT도코모가 공표한 2011년도 접속료의 원가 중에, 미회수 비용은 산입되어 있지 않는데, NTT도코모 측은 이와 관련하여 일본통신이 주장하는 '산정식의 변경'에 관하여 2010년도부터 접속료 원가 안에 추가한 "접속료 직과비용"을 가리키는 것이라고 주장하였다. 접속료 직과비용은 MVNO에 통신설비를 빌려주기 위해서 필요하게 된 인건비나 물건비 등의 운영비를 말하며, MVNO 고유 비용이다. NTT도코모 측은 "서비스 개시 이후 일정기간이 경과하여 그간의 실적에 따라 비용을 파악할 수 있게 되어 2010년도부터 접속료의 원가에 추가했다."고 설명하였다.

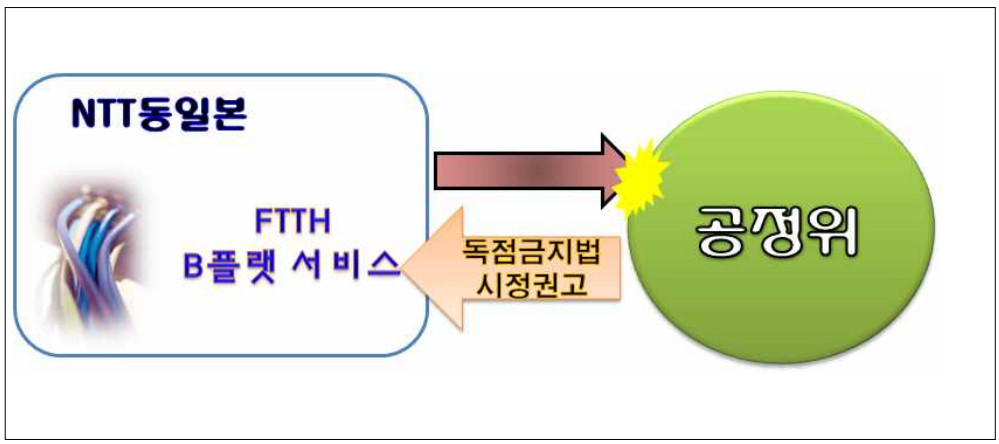
재판에서는 접속료의 원가에 접속료 직과비용을 더한 것이 양사의 계약에 위반인지 여부가 쟁점이 되었는데, 본래 국내휴대전화업계의 거인인 NTT도코모가 계약 수가 20만건에 불과한 일본통신의 MVNO 사업을 이정도까지 경계하는 이유는 일본 휴대전화회사에서는 시장지배적 사업자에게만 부과되고 있는 비대칭규제 때문이다. 현재 NTT도코모가 약관에 근거하여 상호접속을 하고 있는 것은 일본통신뿐만이 아니며, 만일 다른 기업이 통신설비를 빌리고자 하면 NTT도코모는 그 접속

을 거부할 수가 없다.

한편 점유율이 높은 휴대전화회사에게 약관에 근거한 접속을 의무화하고 있기 때문에 MVNO 요구에 따라서 설비를 개방한 경우, 휴대전화사업자는 MVNO의 통신 데이터를 보내는 통로가 된다. NTT도코모 측은 가령 애플이 NTT도코모의 MVNO가 되어 "iPhone"을 판매할 경우, iPhone의 상품력에서 볼 때 단숨에 시장을 석권할 가능성이 있다는 것을 우려한 것이다. NTT도코모 측은 '적자가 줄줄 새는 구조인 채로 위와 같은 통로가 되어 버리는 경우, 우리의 제1책무인 설비의 보수나 운용조차 불안해지며, NTT도코모가 곤란해지는 것뿐 아니라, 설비를 이용하고 있는 사용자나 일본의 국익, 국제경쟁력 등 모든 곳에 번질 것이다'라고 지적하였다.[72]

3) NTT 동일본 대 일본 공정위(JFTC) 사건

[그림 36] NTT 동일본 v. 일본 공정위 사건 개요



일본 공정위는 2003. 12. 4. NTT동일본에 대해서 FTTH 서비스 'B 프랫' 제공에 관하여 「독점금지법」 위반으로 시정권고를 하였다. 또 타 사업자의 ADSL 공사실시에 관하여도 「독점금지법」 위반이 있다고 시정조치 하였다.[73] 이에 NTT동일본이 일본 공정위의 심결 취소를 구하는 행정소송을 제기한 것이다. 일본 최고재판소는 NTT동일본이 제

72) 위 사건은 심리 중이며, 아직 판결이 나지 않은 사건이지만, 일본의 통신시장 상황을 엿볼 수 있다. <http://business.nikkeibp.co.jp/article/NBD/20120426/231421/?ST=pc>
73) http://www.itmedia.co.jp/broadband/0312/04/lp12.html

공한 FTTH 서비스 'B플랫・뉴패밀리 타입'이 「독점금지법」에 위반된다고 하여 원고 패소 판결을 선고하였다.[74]

NTT동일본은 인터넷에 접속함으로써 대량의 데이터 통신을 가능하게 하는 광섬유 설비를 이용한 브로드밴드 서비스, 즉 FTTH 서비스를 'B플랫'이라는 명칭으로 2001년 8월부터 제공하였다. NTT동일본은 2002년 6월부터 실제로는 사용하지 않는 분기방식(NTT동일본의 전화국에서 연장된 광섬유 1심을 복수의 사람들이 공용하는 방식)으로 사용자요금을 설정하여 '단독주택용 뉴패밀리 타입'을 당초 월정액 5800엔, 2003. 4. 1. 이후에는 월정액 4500엔의 사용자요금에 판매하였다. 하지만 동 서비스의 제공 시에는 광섬유 1심을 1인의 사용자에게 제공하는 심선직결방식을 사용하여 실질적으로 타 사업자의 광섬유 1심의 접속요금 5074엔을 밑도는 사용자요금으로 동 서비스를 판매하였다. 이 같은 가격으로 동사는 '가입자 광섬유'에 접속하여 FTTH 서비스를 판매하는 다른 전기통신사업자의 '단독주택용 FTTH 서비스'로의 신규진입 참여를 저해한 것이다.[75]

스스로 설치한 가입자 광섬유 설비를 이용하여 단독주택용 통신서비스를 가입자에게 제공하고 있는 제1종전기통신사업자는 다른 전기통신사업자도 상기 설비에 접속하여 이용할 수 있게 하는 법령상의 의무를 지고 있다. NTT동일본은 「사업법」에 의해, 자사의 광섬유 설비에 타 FTTH 서비스 사업자가 접속할 때 내는 접속요금을 정한 접속약관을 인가받도록 의무화되어 있으며, 또한 자사의 FTTH 서비스 부문도 동액의 접속요금을 자사의 광섬유 설비부문에 내부거래에 의해 지불하는 형태를 취하는 것이 의무화되어 있었다. 2003년말 현재 FTTH 서비스 사업자가 보유하는 '가입자 광섬유' 전체에서 NTT동일본이 보유하는 광섬유의 비율은 70% 이상이었다.

여기서 문제가 된 것은 FTTH 서비스 요금으로, NTT동일본은 단독주택용 뉴패밀리 타입의 월정액요금을 4500엔으로 설정했는데, 이 가격은 NTT동일본이 다른 사업자에게 광섬유 1심을 빌려줄 때의 접속료, 5074엔을 크게 밑도는 것이다. 다른 사업자가 FTTH 서비스를 고려하는 경우, 상당히 자본력이 있는 기업이 아니고서는 새로 광섬유 인프라를 구축하기는 어렵고, 통상적으로 NTT의 광섬유를 빌려서 FTTH 사업을

74) 사건번호 평성21(행히)348, 사건명 심결취소청구사건, 재판년월일 2010.12.17.
75) 田中弘昭、"規制緩和市場への参与と独占的地位の濫用"、神戸学院法学, 第38券 第1号. 2008年9月.

해야 하는데, 이 때 삭감될 수 없는 "접속료"가 원가로서 5074엔이며 기타 경비를 가산하면 최종 사용자요금은 5074엔을 크게 웃돌게 된다.

따라서 NTT동일본이 자사의 FTTH 서비스를 월정액 4500엔에 제공한다면 비용 면에서 경쟁이 되지 않는다. 즉 NTT동일본은 타 사업자에게는 높은 접속료에 광섬유를 제공하면서 부당하게 저렴한 '뉴 패밀리 타입' 요금을 설정함으로써, 사실상 타 사업자의 광섬유 이용을 거부하고 업계로의 신규진입을 저해한 것이다.[76]

NTT동일본은 상기 서비스의 가입자로부터 징수하는 사용자 요금은 여러 가입자가 광섬유 1심을 공용하는 저가 방식을 이용함을 전제로 하여 신고하되, 실제 가입자에게는 광섬유 1심을 1인 가입자가 전용하는 고가의 방식을 이용하는 한편, 다른 전기통신사업자들이 부담하는 상기 시설로의 접속요금은 사용자 요금을 웃도는 금액으로 인가를 받아 제시하여 자신의 사용자 요금이 해당 접속요금을 밑돌게 한 위와 같은 행위는 「독점금지법」 제2조5항의 '다른 사용자의 사업 활동을 배제'하는 행위에 해당하는 것이다.

당시 동일본 지구에서 기존의 가입자 광섬유설비에 접속하여 상기 서비스를 제공하려고 하는 전기통신사업자 입장에서, 그 접속대상은 사실상 NTT동일본에 한정되어 있었다. 상기 서비스는 주로 사업의 규모에 의해 효율이 높아지고, 또한 가입자와의 사이에서 일단 계약을 체결하면 경쟁자에게로 계약을 변경하기 어려운 특성이 있다. NTT동일본은 자신의 가입자에게 상기 서비스를 저렴한 방식으로 제공함을 전제로 그 접속요금의 인가를 받음으로써, NTT동일본에 대한 행정지도를 비롯한 각종 행정적 규제를 실질적으로 면하고 있었다. 또한 NTT동일본은 자신이 설치한 가입자 광섬유 설비를 스스로 사용하는 동시에, 미사용 광섬유의 소재 등에 관한 정보도 사실상 독점하고 있었으며, 상기 서비스의 시장이 당시 급속히 확대되고 있는 가운데 NTT동일본은 1년 10개월간 해당행위를 하여 법원은 이를 「독점금지법」위반으로 판시한 것이다.

76) http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0402/25/news033.html

3. 일본 판례에 대한 분석

일본에서도 사업자의 사업법 위반을 청구원인으로 한 소송은 승소하기 어렵다. 오히려 차별적 요금설정을 경쟁법 위반으로 의율 하는 것이 바람직하다. 다만 이러한 법령의 적용은 사업자가 제소한 행정소송의 판결 이유에서 나타난 것이다. 이는 공정위의 시정조치를 청구할 수 있는 소권을 인정하는 입법 정신의 반영이라 할 것이다.

[표 15] 일본 통신 관련 소송 요약

소송물	원고	피고	적용법규	관계	결과	쟁점
인가취소	KDDI	총무성	사업법	수직관계	청구기각	인가약관의 적법성
과지급금 반환 등	일본통신	NTT Docomo	사업법	수직관계	심리중	인가약관의 적법성
시정조치 취소	NTT 동일본	JFTC	경쟁법	수평관계	청구기각	경쟁사업자 사업활동 방해

VI. 유럽 통신시장의 규제

1. 유럽 전기통신사업과 경쟁법

유럽이사회(European Council)는 통신 분야 자유화와 경쟁법의 적용에 관한 다양한 규범을 만들어 왔다. 1998년에는 통신시장의 완전자유화가 선언되었고, 또한 '통신분야 경쟁법 가이드라인'을 공표하였다. 여기서는 경쟁법에서의 시장지배적 지위의 남용 규제가 중심이 되고 있다.

한편 통신분야에서의 협의의 경쟁법 외에 '현저한 시장지배력'(significant market power, 이하, 'SMP')이라는 개념이 이용되어 왔다. SMP를 갖는 통신사업자에 대해서는 비차별적 규제로서 투명한 접속을 제공할 의무가 부과되었다. SMP는 점유율 25%에 의해 그 지위의 존재가 추정된다. [77] 점유율 25%라는 기준은, 경쟁법 상의 시장지배적 지위가 인정되는 점유보다도 훨씬 낮은 것이며, 또한 관련시장의 획정에서도 경쟁법에서 파악하는 분석수법을 사용하지 않는다.[78]

유럽이사회는 2000년 '통신, 방송, IT, 커뮤니케이션, 네트워크, 서비스에 관한 6개의 제안'을 내놓았다. 이는 사업법 상의 규제는 예외적인 것이며, 경쟁법이 원칙적 규범이어야 한다는 사고로부터, 기존 입법에 대한 포괄적인 개정을 단행한 것이다.

회원국은 이 프레임워크 규제에 근거하여, 기존 입법을 포괄적으로 수정하고, 필요한 경우에는 개정하는 것이 의무화되었다. 회원국은 유

77) 가령 Directive 98/10/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 1998, On the application of open network provision(ONP) to voice telephony and on universal service for telecommunications in a competitive environment, OJ 101 1998에서는 사업자는 관련 시장에서 점유율 25%에서 SMP가 추정된다고 하였다(제2조제2항(i)). 국내규제기관은 25% 미만이라도 SMP를 결정할 수 있고 점유 25%를 넘어도 SMP를 초래하지 않는다고 결정하는 경우도 가능하다. 어떤 경우라도, 그 시장에 미치는 영향력, 시장의 규모에 비교해서 그 사업자의 매출, 최종고객에게로의 액세스 수단의 컨트롤, 금융자원에의 액세스, 및 시장에서의 상품 용역의 공급 경험을 고려해야 한다고 한다.

78) 일본 사업법에서 소위 시장지배적 사업자 규제가 있는데, 그때도 같은 경향을 보인다. 오키나와 셀룰러 규정에 관한 의논에서도, 경쟁법(독점금지법)상의 시장획정 작업은 하지 않고, 행정단위에서 점유가 산정되고, 또한 그 점유의 수치를 극히 중시한 듯하다. 이 의논의 영향을 받은 총무성 '사업법 제37조의2 제1항의 규정에 근거한 금지행위 등의 규정의 적용을 받는 제1종 전기통신사업자(이동통신분야에서의 시장지배적인 전기통신사업자)의 지정'(2002년4월14일)은 경쟁법의 접근에 근접하고는 있으나, 또한 경쟁법과는 상당한 괴리가 있다.

효경쟁이 진전되고 있다면 경쟁법의 규제에 위임하고, 유효한 경쟁이 진행되고 있지 않은 경우에도 경쟁법의 규제에서는 대처할 수 없는 경우에만 분야특수적인 사업법 상 규제를 인정하는 것이 의무화되었다.

유럽연합 집행위원회(European Commission)(이하, '유럽위원회')는 경쟁법의 원리에 따라서 시장을 획정할 것을 요구한다. 적어도 2개의 주요 타입의 관련시장을 고려해야 한다. 최종 소비자용 서비스와 제품 시장 즉 소매시장과, 최종 소비자에 서비스와 제품을 제공하기 위해서 사업자에게 필요한 투입요소의 시장 즉 도매시장이 그것이다.

2. SMP 이론

유효한 경쟁이 인정되지 않고 잠재적으로 규제의 필요성이 있는 시장에서만 NRA(National Regulatory Authorities)는 SMP 사업자에 대해서 비대칭적 규제를 부과하게 된다. 유럽위원회는 사업법 규제와 경쟁법 규제의 개입요건이 괴리됨을 우려하여 SMP 가이드라인에서 유효한 경쟁의 부존재와 SMP 사업자의 존재를 동일시하기로 했다. SMP와 시장지배적 지위는 동일한 기준에 의해 평가되고, 이들을 동등하게 취급하는 것이 입법과정에서 결정된 것이다. 이에 따르면 유효한 경쟁이 긍정되는 것은 해당 시장에서 시장지배적 지위를 갖는 사업자가 존재하지 않는 경우에 한정되며, 하나의 또는 복수의 사업자가 시장지배적인 경우에는 유효한 경쟁이 부정된다는 해석이 된다.

EU의 입법자는 입법과정에서, SMP의 기준을 경쟁법의 시장지배적 지위의 사고와 동등하게 다루는 결단을 했다. 비록 사전규제와 사후규제라는 차이는 있지만, SMP 기준은 TFEU(Treaties of the EU) 제102조의 관점에서의 시장지배적 지위와 같은 사고가 된다. 이는 사업법 규제에 의한 개입의 계기가 되는 최저 기준값의 인상을 의미하는 것으로, SMP 기준이 시장지배적 지위의 사고를 기초로 함으로써 사업법 규제의 범위가 경감했음을 의미한다.

SMP 기준의 해석은 유럽법원의 시장지배적 지위의 판례를 근거로 하며, 시장분석에 관해서 SMP의 기준에 의거한 심사를 하여, NRA는 SMP를 갖는 사업자가 존재하면, 해당 사업자에 대해서 사업법 상 규제

를 부과한다. 이에 대해서 SMP 사업자가 존재하지 않는 시장에서는 사업법 상 규제는 부과되지 않고, 경쟁법의 적용 대상이 된다.

SMP 사업자를 인정한 후, 구체적으로 NRA는 ERG(European Regulatory Group)를 조직하고, 유럽경쟁총국(DG COMP) 및 유럽정보사회총국(DG IMFSO)과 함께 조치에 관련된 '공통의 입장'을 공표하였다. 문제가 되는 SMP 사업자의 행위는 ① SMP 사업자에 의한 수평적 레버리지 행위, ② 고가격 등 수직적 착취 남용으로서의 독점적 폐해행위로, 이에 대하여 우선 문제가 되는 SMP 사업자의 시장진입장벽의 유지 및 강화행위와 수평적 레버리지를 금지하는 조치를 취하고, 이로써도 실효적인 경쟁이 기대될 수 없는 경우에는 소비자 보호를 위해 착취적 남용의 금지로서 소매 수준의 요금규제를 하는 것이다.

상류시장인 도매시장에서의 조치가 문제를 해결하지 못하는 경우에는 하류시장인 서비스 시장에서의 직접규제를 단행한다. 도매시장에서 인프라 간 경쟁이 기대될 수 없는 경우에는, 실효적인 접속의무를 부과함으로써 서비스 시장의 경쟁촉진을 도모해야 하는 것이다. 동시에 접속의무는 상류시장에서의 인프라 개선의 인센티브를 손상해서는 아니된다. 인프라 간 경쟁이 가능한 경우에는, 가능한 한 인센티브 정합적인 조치를 설계하여 인프라 간 경쟁이 활발해지는 경쟁시장으로의 이행을 촉진해야 한다. 가령 단지 접속을 명하는데서 그치지 말고, 하류시장의 경쟁자에게 접속을 인정하지 않는 한 자기의 하류부문으로의 공급도 불가능해짐으로써, SMP 사업자에 의한 자발적인 조치 준수를 확보하는 노력이다.

경쟁법의 사고에 일치하지 않는 시장획정 및 시장지배력 남용을 방지하기 위해서, NRA에 의한 괴리된 시장획정 및 SMP의 남용에 대해서는 유럽위원회에 거부권이 인정되고, 최종적으로는 조약위반의 절차도 가동된다.

SMP의 규정을 둘러싸고 프레임워크 지침 제14조3항에는 시장지배력의 이행에 근거한 SMP, 즉 '레버리지의 효과에 관한 추정규정'이 존재한다. 프레임워크 지침 제14조3항의 요건은 SMP 가이드라인(82)에 따라 Tetra Pak II의 유럽법원 판례의 이론에 근거한 시장 상황을 이해하기 위해서 도입되었는데, 이 '입법상의 추정'이 핵심 개념이다.[79]

79) ECJ, "Tetra Pak International SA v Commission of the European Communities, Case

Tetra Pak II 판례에서는, 포장 시장에 있어서, 일정 시장에서 시장지배적 지위에 있는 사업자가 밀접한 관계에 있는 시장에서도 지배적이며 후자의 시장에서 남용행위가 인정되는 경우에, TEFU 제102조가 적용됨을 밝혔다.

요컨대 위 판례에서의 밀접한 관련 시장에 대해 동 지침에서는 '인접한 시장'을 요건으로 하여 시장지배력 전이의 입증책임을 훨씬 용이하게 하였다. 또한 위 판례에서는 2차 시장에서 탁월한 지위를 요구하고 있는 반면, 동 지침에서는 2차 시장에서의 지위는 아무런 요구를 하고 있지 않고, 위 판례에서는 시장전체에서 지배적 지위와 동일시 할 수 있는 지위를 인정하고 있는 것에 대해서, 동 지침은 단지 전체의 시장지배력 강화의 가능성을 요구하는 데 그쳐, 유럽법원은 Tetra Pak II 판결로 동 102조 적용 범위의 확대를 정당화하였다.

결론적으로 동 지침은 유럽법원의 판례보다 완화한 요건을 규정한 것이다. 시장지배적 지위의 사고와 SMP 기준이 사실상 동일하다면, 사업법에서 경쟁법으로 이행이 용이해질 것이다.

3. 회원국 규제[80)]

가. 독일

「전기통신사업법(TKG)」에 따라 통신 규제를 수행하기 위하여 연방 망규제청(BNetzA)이 망 산업에서의 무차별 접속과 효율적인 요금규제를 담당하고 있다. 망규제청은 연방 행정기관이며, 법에 규정된 통신규제의 목적을 달성하기 위하여 행정행위로서의 행정처분과 명령을 발할 수 있다. 망규제청은 규제처분과 관련된 사항을 심결부가 처리하도록 하여 전문성과 독립성을 강화하고 있는데, 이 심결부의 구성과 절차

C-333/94", ECJ Judgment. 1996.

80) 회원국 규제의 일반적 구조는 각 회원국이 유럽연합 차원의 입법을 국내법으로 수용하는 것이다. 따라서 유럽연합의 사례의 법리가 전체적으로는 그대로 적용된다. 본고에서는 사업법 규제가 강력한 대표적인 국가인 영국과 경쟁법 규제가 강력한 대표적인 국가인 독일의 사례를 살펴본다. 다른 개별국가의 판례의 경향도 크게 다르지 않으며, 보다 구체적인 심층적인 비교분석은 과제로 남긴다.

는 연방 카르텔청(Bundeskartellamt)을 모범으로 하여 만들어 졌다.

「TKG」제19조에 따라 망규제청은 상당한 시장지배력을 가진 공공 통신망 운영자에 대하여 객관적 기준에 근거하여 접속에 대한 합의를 실행하도록 하는 의무를 부과할 수 있다. 또한 「TKG」제27조 1항에 의하면 망규제청은 요금규제를 통하여 시장지배력을 가진 사업자가 최종 소비자나 경쟁자들에게 남용적 착취를 하거나 사업활동을 방해하거나 또는 차별 취급를 하는 행위 등을 가격정책적으로 막는다. 동법 제28조는 덤핑이나 끼워팔기(tying) 등 남용적 가격설정을 사후 규제의 대상으로 설정한다.

「TKG」제42조는 상당한 시장지배력을 가진 통신서비스 제공자 또는 공공 통신망 운영자의 남용행위를 특별하게 규제한다. 즉 SMP를 가진 기업이 자회사에 유리한 조건 내지 품질을 제공하거나, 접속계약의 체결을 근거 없이 지연시키는 경우 남용행위로 추정된다. 이러한 사업자는 시정조치, 과태료 부과와 함께 부당이득을 환수 당하게 된다.

「독일 카르텔법(GWB)」에 의한 규제는 사업자의 위반행위가 있은 후에 그 위반행위의 경쟁제한성을 판단하는 전형적인 사후적(ex post) 규제방식이다. 그런데 「TKG」제40조에 의한 시장지배적 사업자의 지위남용행위 규제는 망규제청과 카르텔청의 관할권의 충돌이 일어날 수 있는 여지가 있다.

「TKG」의 제2조 3항은 「GWB」의 일반조항이 「TKG」의 해석에 영향을 주지 않는다고 명시하고 있고, 제 82조는 시장의 지속적인 평가, 특히 시장지배적 사업자인 경우의 평가를 보장하고 통신영역에서 「GWB」가 의도하는 평가의 기준과 동일한 수준을 보장하기 위하여 카르텔청과 망규제청이 협조하여야 한다고 규정하여 이러한 충돌을 막고자 하였다.

망규제청이 더 이상 규제가 필요 없다고 판단하는 시장에 대해서는, 주파수 배분, 번호 배분, 도로 사용권과 관련된 기술적인 사항을 제외하고는 시장규제권한을 카르텔청의 사후 규제에 유보하고 있다. 따라서 이런 시장에서의 시장지배력을 가진 사업자에 의한 접속의무 위반은 「TKG」제40조가 아닌 「GWB」제19조 4항의 시장지배적 사업자의 지위남용행위로 규율 받게 된다.[81)]

81) 황태희, “독일 통신 시장의 경쟁과 규제 개혁”, 『주요국가의 기업규제개혁법제에 관한 비교법적 연구』 한

나. 영국

영국은 EU Directive를 반영하여 법령 및 규제기구를 정립하였는데, 이에 따라 2003년 7월 「Communication Act 2003」을 공표하고 동년 12월 기존 5개의 통신, 방송 규제기관을 통합한 영국 정보통신 규제기관(Office of Communications: Ofcom)이 설립되었다. 이후 일반 규제기관인 공정거래위원회와 전문규제기관인 Ofcom은 업무제휴를 통해 지속적으로 협력중이다.

통신 · 방송기업 간의 인수합병(M&A)은 국민 경제에 일반적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 주로 공정거래위가 주도하고, 이때에 Ofcom은 전문 식견을 바탕으로 자문역할을 담당한다. 반면에 M&A를 제외한 나머지 커뮤니케이션 영역에 있어서는 Ofcom이 규제를 주도하며, 이 경우에는 MOU에 따라 공정거래위가 Ofcom에 각종 자문을 제공한다.

4. 유럽연합 전기통신사업 관련 구체적 사례

가. 요약

[표 16] 유럽연합 전기통신사업 관련 판결내용 요약

소의종류	사안	청구취지	청구원인	판결의요지
행정	Telefonica S.A. v. EU	피고의 원고에 대한 과징금 부과처분의 취소청구	피고가 원고에 대하여 SMP가이드라인 위반을 이유로 1.5억 유로의 과징	원고는 도매시장 및 소매시장에서 시장지배적 사업자로서, 이윤압착 행위를 저질렀다

국법제연구원., 2008. 6. pp. 51-70.

			금을 부과한 것은 위법하다.	(청구기각).
행정	Telrkomunikacis Polska v. EU	피고의 원고에 대한 과징금 부과처분의 취소청구	피고가 원고에 대하여 SMP 남용을 이유로 1.27유로의 과징금을 부과한 것은 위법하다.	원고는 도매 및 소매 시장에서 시장지배적 사업자로서 전략적으로 그 지위를 남용하여 경쟁사업자를 몰아내고 부당이득을 취하였다(청구기각).
민사	Deutsch Telecom v. Mannesmann Arcor	피고 DT는 시장지배적 사업자로서 그 지위를 남용하여 부당한 가격을 설정하였다.	피고는 경쟁사업자에게 소매시장 최종 소비자에 비하여 더 비싼 요금을 부과하였다.	피고가 적용한 요금이 도매접속요금으로 정하여진 규제 대상에 속하나, 피고에게는 스스로 판단에 의해 어느 정도 이윤압착을 방지할 수 있는 상업적 자유가 있는바, 가격남용에 해당한다(청구인용).
민사	AOL v. Deutsch Telecom	피고(DT)가 T-Online 인터넷 연결 서비스의 끼워팔기를 시도한 것은 위법하다.	피고는 시장지배적 사업자이고, T-Online은 피고의 자회사로 피고가 ISDN에 T-Oline의 인터넷열결 서비스의 끼워팔기를 시도하였다.	ISDN과 이 사건의 인터넷 연결은 서로 아무런 관련이 없는 상품이며, ISDN의 고객들이 비록 위 인터넷 연결 서비스의 사용을 강요받지는 않는다고 하더라도 경쟁사업자의 고객을 흡입하는 경우 반경쟁적 행위로 볼 수 있다(청구인용).
민사	GSM-Gateway 사건	피고에게는 네트워크 착신서비스를	이동통신 네트워크 오퍼레이터가 유선전화라인에서 시작되어 GSM	착신 서비스 공급에 관한 것은 착신시장 자체의 문제이며, 착신시장에서 파생

		공급할 의무가 있다.	gateway를 통해서 무선 네트워크로 전송된 착신전화를 거부한 것은 의무위반이다.	된 독자적인 시장이 없기 때문에, 독일 경쟁제한방지법 제19조 4항 4호의 필수시설 규정은 적용되지 않는다(청구기각).

나. 구체적인 내용

1) Telefonica, S.A. 대 European Commission 사건 (2012)[82]

[그림 37] Telefonica, S.A. v. EC 사건 개요

원고인 Telefonica, S.A.는 Telefonica 그룹의 모회사로, 스페인 국영 독점통신업자로 1998년 통신시장이 완전히 자유화되기 전까지 Telefonica는 스페인 정부 소유로 유선전화 독점권을 소유하고 있었다. 2001년 9월에서 2006년 12월 사이에 Telefonica는 자회사를 통해서 광대역 서비스를 공급하였고, 2006년 자회사들을 합병하여, 그 결과 Telefonica는 스페인에서 유일한 전국 유선전화망을 운영하게 되었다.

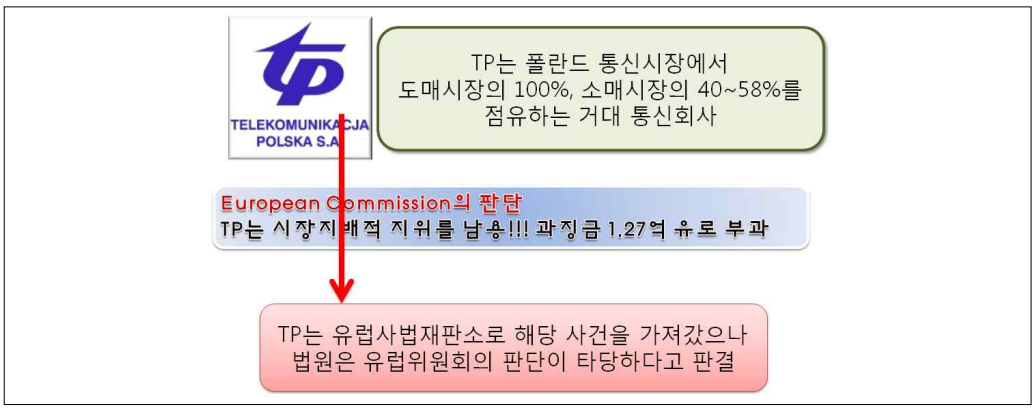
2003. 7. 11. 프랑스의 Wanadoo Espana, SL은 Telefonica가 경쟁사업자에 요구하는 도매가격과 최종이용자에 요구하는 소매가격의 차이

82) Case T-336/7. European General Court (Eighth Chamber).

가 너무 작아서 실질적으로 Telefonica와 경쟁하는 것이 불가능하다고 주장하며 Telefonica를 유럽위원회에 제소하였고, 위원회는 Telefonica가 도매시장과 소매시장 모두에서 시장지배적 사업자로, 이윤압착(margin squeeze)을 행하여 EU의 SMP 가이드라인에 위배되는 행위를 했다고 결론을 내리고, Telefonica에 1.5억 유로가 넘는 과징금을 부과했다. 이에 2007. 10. 1. Telefonica가 위원회의 판결이 부당하다고 주장하며 유럽사법재판소(European Court of Justice)의 지방법원(General Court)에 본 소송을 제기한 것이다. 유럽 지방법원은 유럽위원회와 같은 이유로 위원회의 손을 들어주었고, 본 사건은 기각되었다.

2) Telekomunikacja Polska 대 European Commission 사건[83)]

[그림 38] Telekomunikacja Polska v. EC 사건 개요



폴란드의 통신시장은 도매 광대역 접속망(wholesale broadband access), 도매 네트워크 접속인프라(wholesale network infrastructure access), 소매 대중시장 (retail mass market)으로 나뉘는데, 폴란드의 Telekomunikacja Polska S.A. (이하, 'TP')가 폴란드에서 유일하게 전국망을 가진 사업자로 도매시장에서 100% 독점적으로 공급하였다. 또한 TP는 소매시장에서도 2005년에서 2009년 사이에 회선수로는 40%~58%, 매출액으로는 46%~57%의 점유율을 보였다. 또한 소매시장에는 TP의 자회사인 PTK도 존재하기 때문에 소매시장에서 TP의 총 점유율은 이보다 더욱 높았다. 실제로 소매시장에서 TP의 경쟁회사는 전부 매우 작은 시장점유율을 갖고 있어, DSL시장에서 가장 큰 경쟁자인 Netia도

83) Case T-533/08 (2010).

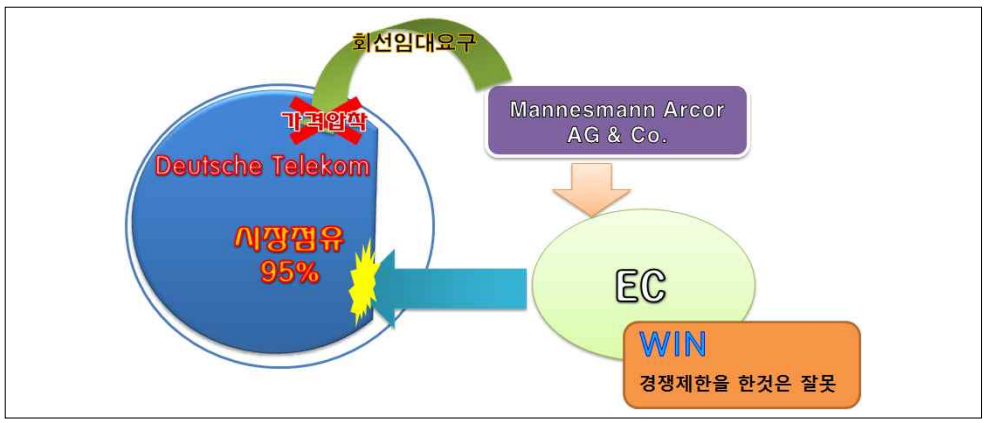
점유율은 9%에 불과하였다.

유럽위원회는 TFEU 제102조를 적용해서 2005년부터 2009년까지 TP의 시장지배적 지위 남용이 계속되었다고 보았는데, 후에 TP 내부문건이 TP가 전략적으로 시장지배적 지위 남용을 통해 경쟁자를 몰아내고 부당이득을 취했다는 것을 증명하였다. 위원회가 찾아낸 TP의 남용행위는 다음과 같다. ① 계약상의 불합리한 조건으로 신규 경쟁업자에 매우 불리했고, 여러 가지 면에서 폴란드의 규제기관이 설정한 최소기준에도 미치지 못했다. ② 70%의 협상에서 TP는 지연전술로 90일 이내에 협상을 마무리 지어야 한다는 규제기관의 데드라인을 지키지 않았다. ③ 네트워크에 제한적인 접근으로 계약을 다 맺은 이후에도 TP는 기술적인 문제 등을 이유로 들면서 네트워크 접속을 종종 제한했다. 또한 접속 사용료를 과장되게 부풀려서 제안하여 경쟁업자들이 스스로 접속을 요구하지 않도록 했다. ④ 소매시장에서 방해남용으로, 기술적인 이유 등을 핑계로 접속을 차단해서 경쟁업자들이 소비자에 공급을 못하도록 하고, 경쟁업자의 요구사항을 시행하는 것을 고의로 늦춰서 고객을 잃도록 유도했다. ⑤ 경쟁업체에 신뢰할만한 정보 제공을 거부하여, TP는 사업방향 결정에 있어서 필수적인 정보를 제대로 제공하지 않거나, PDF 내지는 종이, 하드카피처럼 처리하기 힘든 포맷으로만 제공했다는 것이다.

결국, 2011년 유럽위원회는 경쟁 통신업자에 도매 광대역 상품을 공급하기를 거절했다는 것을 이유로 TP에 1.27억 유로의 과징금을 부과하였는데, 이에 TP는 유럽법원에 위 조치가 위법하다는 이유로 제소를 하였으나, 법원은 위원회의 판단이 타당하다고 판단하여, 본 사건을 기각하였다.

3) Deutsche Telecom 대 Mannesmann Arcor AG & Co. 사건

[그림 39] Deutsche Telecom v. Mannesmann Arcor AG & Co. 사건 개요



본 사건에서 유럽위원회는 통신시장에서의 경쟁법 적용의 가장 강력한 의지를 표명하였다. 즉, 회원국의 인가를 받아 적법성 추정을 받는 것은 사업법 상 적법성에 그치는 것이고, 독립적인 별도의 경쟁법 심사를 받아야 한다는 것이다.

Mannesmann Arcor AG & Co.(이하, 'Arcor')는 1999년 Deutsche Telekom(이하, 'DT')이 독점하던 독일 통신시장에 새롭게 뛰어들었다. 당시 DT는 경쟁 통신사업자에게 회선 접속을 제공하는 도매시장과 최종소비자에게 전화서비스를 제공하는 소매시장, 모두에서 지배적 지위를 확보하고 있었고, 점유율은 95%에 달했다. DT는 양 시장에서의 시장지배적 지위를 남용해서, 경쟁 통신사업자에게 회선 접속을 제공할 때 소매시장에서 최종소비자에게 부과하는 것보다 더 비싼 요금을 부과했다. DT의 회선을 임대해서 최종 소비자에게 접속 서비스를 제공하는 다른 사업자는 DT과 경쟁할 여지 자체가 없었던 것이다. 즉, DT가 경쟁사업자의 경쟁을 제한하는 가격압착(price squeeze)을 저지른 것이다.

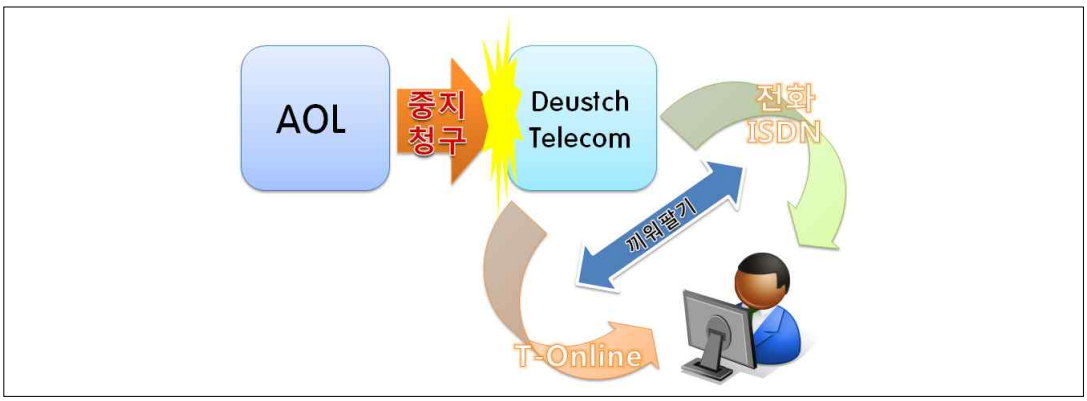
Arcor는 시장지배적 지위를 갖고 있는 DT가 해당 지위를 남용해서 부당한 가격설정을 했다고 유럽위원회에 제소하였고, 이에 대해 DT는 경쟁사업자에 대한 도매접속요금은 독일 통신 규제당국이 정한 것이기 때문에 가격남용에 해당하지 않는다고 주장하였다. 또한 통신사업에 대한 규제는 EU 각 회원국의 규제기관이 할 역할이기 때문에 위원

회에 제소권이 없다고 주장했다.

그러나, 유럽위원회는 DT의 주장을 기각하였다. 위원회에 의하면, DT는 비록 가격규제를 받는 사업자이긴 하지만 스스로의 판단에 의해 어느 정도 이윤압착을 할 수 있는 상업상 자유를 갖기 때문에 가격남용이 성립한다고 판단했다. 마찬가지로 제소권에 관한 판결에서도 DT의 행위가 실제로 경쟁제한에 핵심적인 원인으로 작용했기 때문에 제82조 하에서의 제소가 정당하다고 판단했다.

4) AOL 대 Deutsche Telekom 사건

[그림 40] AOL v. Deutsche Telekom 사건 개요



본 사건은 DT가 전화 ISDN 가입자에 자회사인 T-Online의 인터넷 연결 서비스 끼워팔기를 시도한 것이 위법이라고 주장하며, AOL이 중지를 청구한 민사소송으로, 법원은 AOL의 청구를 인용하였다.

DT는 독일 전화 네트워크에서 과점에 해당하는 망점유율을 보이고 있는데, T-Online은 DT의 자회사로 당시에 인터넷 접속 시장에서 상당한 시장지배력을 갖고 있었다. 원고 AOL은 세계 최대의 인터넷 서비스 제공자로 독일에서 T-Online과 경쟁관계에 있었는데, ISDN과 인터넷 연결 끼워팔기가 위법이라 주장하며 DT와 T-Online을 상대로 소송에 나선 것이다.

독일 연방대법원은 2004년 3월 이에 대해서 DT의 ISDN 고객들이 계약상 T-Online의 인터넷 서비스를 반드시 사용해야 하는 것은 아니지만, 쟁점 사항이 끼워팔기에 해당하기 때문에 독일 경쟁법에 위배된다고 판시했다. 끼워팔기의 요건을 충족하기 위해서는 묶어서 판매되는

두 가지 상품이 서로 연관이 없어야 하는데, DT의 ISDN과 T-Online의 인터넷 서비스는 객관적으로도 그렇고 업계 기준으로 볼 때도 서로 분리된 전혀 다른 상품으로 평가되기 때문이다.

본 판결에 있어서 독일 대법원은 묶어서 판매할 때 고객이 반드시 두 서비스를 다 사용하도록 강요받지 않는다고 해서 반경쟁 효과가 없는 것은 아니라는 점을 강조했다. 이에 의하면 DT의 끼워팔기가 여타 인터넷 서비스 제공 회사의 고객을 반자동적으로(quasi-automatic) 잃도록 하는 효과가 있다면 이것은 반경쟁적인 효과라고 볼 수 있다는 것이다. 즉, 상당한 시장지배력이 있는 기업이 그 힘을 사용해서 끼워팔기를 시도하고 결과적으로 자회사의 시장에서의 시장지배력까지도 강화하는 것은 위법행위가 된다. 대법원은 끼워팔기가 사실상의 '흡입효과'가 있어서 ISDN 가입 고객의 대부분이 인터넷 서비스를 T-Online으로 바꾸게 되므로 「GWB」의 제19조 위반에 해당한다고 판시하였고, 최종적으로 DT는 1,260만 유로의 과징금을 물게 되었다.

5) GSM-Gateway 사건

[그림 41] GSM-Gateway 사건 개요

본건은 이동통신 네트워크 오퍼레이터가 다른 사업자에게 네트워크 착신 서비스를 공급하는 것이 의무화되어야 한다고 GSM-Gateway[84]를 상대로 제기한 소송으로, 법원은 의무로 볼 수 없다고 판단하여 청구를 기각하였다.

84) GSM: Global System for Mobile Communications

착신 서비스 공급에 관한 것은 착신시장 자체의 문제이며, 착신시장에서 파생된 독자적인 시장이 없기 때문에, 독일 경쟁제한방지법 제19조 4항 4호의 필수시설 규정은 적용되지 않는다는 취지의 판결이다.

유선전화라인에서 시작되어 GSM gateway를 통해서 무선 네트워크로 전송된 착신전화를 이동통신 네트워크 오퍼레이터가 거부한 것에는 문제가 없고, 이미 필수시설 원칙과 관련된 접속 규제가 자리매김하고 있는 상태에 추가적으로 접속 규제를 도입하는 것은 오퍼레이터가 경쟁자를 어떻게 다룰 것인가에 대한 타당한 선택권조차도 주지 않는 것이라고 판단한 것이다.[85)]

5. 유럽연합 판례 분석

유럽연합 판례는 회원국 차원을 넘어 유럽연합 차원의 강력한 권리구제 시스템이 작동하고 있음을 보여준다. 경쟁법 위반의 행정사건에서 흔들림 없는 보편적 역무 제공의 의지를 표명하고 있으며, 그 범위는 인터넷 통신의 기반인 광대역 서비스로 확장되었다. 또한 경쟁법을 원칙적 규범으로 하여 유효한 경쟁이 진전되어 있다면 경쟁법에 의한 규제에 위임하고, 그렇지 아니한 경우에도 경쟁법의 규제에 의해서는 대처할 수 없는 예외적인 경우에만 분야특수적인 사업법에 의한 규제를 인정하여, 그 규제가 경쟁법상의 SMP의 남용에 대한 규제에 집중되어 있다.

[표 17] 유럽연합 소송 요약

소송물	원고	피고	관계	결과	쟁점
과징금 처분 취소	Telefonicia S.A	EU	수직 관계	청구기각	광대역서비스, SMP 남용

85) Bender, Christian M. et al., "Effective competition in telecommunications, rail and energy markets," *Intereconomics*, Vol. 46, Iss. 1. Springer, Heidelberg. 2011,

과징금 처분 취소	Telekominikacis Polska	EU	수직관계	청구기각	SMP 남용

Ⅶ. 입체적 규제분류를 통한 입법방안의 제시

1. 행정재량에서 계약재량으로

가. 행정재량

「전기통신사업법」제6조 제1항은 기간통신사업을 경영하려는 자는 미래부장관의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있다. 여기에서의 허가는 사업수행권을 독점적으로 창설한다는 의미에서 공법상 특허에 가깝다. 동조 제4항은 미래부장관은 제1항에 따라 기간통신사업자를 허가하는 경우에는 공정경쟁촉진, 이용자 보호, 서비스 품질 개선, 정보통신자원의 효율적 활용 등에 필요한 조건을 붙일 수 있다고 규정하여 경쟁 촉진적 규제를 그 내용으로 하는 조문을 두고 있다.

여기에서 중복규제와 권한배분의 문제가 생긴다고 할 것이나, 사업법상 인허가가 경쟁의 분야에서 사후적으로 문제되는 경우에, 행정법상 기속행위인 허가는 사업법 당국이 해제요건에 부합하는 한 반드시 허가를 하여야 함에 그치므로 경쟁당국의 유권적 해석이 유력하게 고려되게 되는 반면에, 사업법 당국의 재량이 필연적으로 개재되는 특허는 사업법 규제기관의 판단이 사법적으로도 유권적 해석으로 존중된다고 할 것인바, 위 중복규제 및 권한배분의 문제는 극복될 수 있는 것이다.

또한 사업법에서 위와 같이 경쟁촉진 등을 조건으로 한 사업관할 당국의 특허를 인정하는 것에 대응하여 그 조건을 불이행 하는 경우에 대한 규제방안 역시 규정하는 것이 바람직하다고 할 것인데, 위 사업법은 제20조에서 기간통신사업자가 위 제6조 제4항에 따른 조건을 이행하지 아니한 경우 미래부장관은 그 허가의 전부 또는 일부를 취소할 수 있다고 규정하는데 그치고 있다. 따라서 그 위반의 정도가 허가의 전부 또는 일부의 취소에 이르지 아니하는 경우를 사업법으로 규율하기 위한 방법을 도입할 필요가 있다고 할 것이다. 사업법이 통신산업 분야의 특허와 관련한 제반의 규율을 가지고 있어야 위 권한배분의 문제가 확실해 진다고 할 수 있기 때문이다.

그 방법으로는, 위에서 규정하고 있는 허가의 전부 또는 일부의 취소는 이미 부여한 통신사업 수행권을 회수하는 형태의 강력한 규제로, 그 안에 포섭될 수 있는 낮은 수준의 규제를 도입하는 것은 문제될 것이 없다고 할 것인바, 기간통신사업자가 위 경쟁촉진 등의 조건을 위반한 경우 사법당국이 시정조치를 할 수 있는 근거 규정을 마련하는 것이 상당한 것으로 보인다.

〈개정안〉

제20조(시정조치 등) ① 미래창조과학부 장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면, 기간통신사업자에 대하여 조건의 이행, 당해 위법 행위의 중지, 재발방지 조치 기타 시정을 위한 필요한 조치를 명할 수 있고, 그 허가의 전부 또는 일부를 취소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 사업의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 허가의 전부 또는 일부를 취소하여야 한다.

1. 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 허가를 받은 경우

2. 제6조 제4항과 제18조 제5항에 따른 조건을 이행하지 아니한 경우

나. 계약 재량

미국의 「1996년 법」의 내용은 계약에 직접적으로 관여할 수 있는 규제의 내용을 보여준다. 위 법 제251조에서는 선발지역전화사업자의 비대칭규제상의 법적 의무를 규정하고, 제252조에서는 그 법적의무를 집행하는 법적 수단들을 규정하고 있는데, 그 중 가장 중요한 것은 주(州) 통신위원회의 강제 중재에 의하여 계약 내용과 조건을 결정하는 것이다. 즉, 제251조(C)항은 선발 지역 사업자에 대하여, (ⅰ) 협상의무: 전기통신사업자와 상호접속(재판매, 번호이동성, 번호동등성, 도관 공동사용, 요금분배약정)과 관련된 계약을 체결할 때 신의성실의 원칙으로 협상할 의무, (ⅱ) 상호접속의무: 적절하고, 합리적이고, 비차별적인 가격조건으로 상호접속을 제공할 의무, (ⅲ) 망 세분화 의무, (ⅳ) 재판매 의무, (ⅴ) 변경 통지 의무, (ⅵ) 공동 병설 의무를 부여하고 , 제252조는 위와 같은 거래에 있어서 선발 사업자와 계약이 체결되지 않을 때 통신위원회에 중재를 신청하여 가격 등 계약 조건을 결정하도록 규정하고 있는 것이다.[86)]

이와 같이 소비자의 가격 조건에 영향을 미치는 거시적 관점의 규제의 경우, 사업법 당국의 강재중재권한을 규정하는 조문을 둔다면, 관할에 관한 분쟁을 상당부분 사전에 막을 수 있을 것이다. 이러한 규제방식은 행정법적, 공법적 규제에 그치기보다는 '계약친화적 규제'로 그 규제의 내용이 진화되어야 함을 의미한다.[87] 이러한 공권력에 의한 계약관여는 우리 법제에 있어서도 민사상 부속물 매수청구권 행사, 저작물의 법정 허락 등과 유사하여 전혀 낯선 법리만은 아니라고 할 것이다.

〈개정안: 신설〉

제45조의1(방송통신위원회의 결정청구) ① 전기통신사업자 또는 그 이용자는 설비 등의 제공·공동이용·도매제공·공동사용의 이용대가 산정에 대하여 협의가 이루어지지 않는 경우 방송통신위원회에 그 결정을 청구할 수 있다.

② 방송통신위원회가 제1항의 규정에 의하여 이용대가를 결정하는 경우에는 공정 경쟁 촉진을 위한 제반 사정을 종합적으로 참작하여 이를 산정하여야 한다.

2. 미시경제적 규제에서 거시경제적 규제로

가. 미시경제적 규제

사업체 간의 경쟁이 심화되고, 시장지배적 사업자가 끼워팔기(tying arrangement)나 배타적 협정(exclusive dealing) 등을 통해서 지위를 남용하거나, 시장지배적이지는 않다고 하더라도 독점협정 등 다양한 형태의 불공정거래 행위를 하는 경우, 그리고 합작투자 혹은 인수합병 등의 형태로 기업이 결합하는 경우 등 사업체 간 발생하는 경쟁적 요소로 인한 기업 활동들이 일어나면서 이에 대하여 기업들 간 혹은 한 기업

86) 이영대, "통신에서의 시장지배적 사업자에 대한 비대칭 규제의 법적 성격에 관한 소고", 『정보법학』, 제9권 제1호. 2007, p.116

87) 이영대, "통신에서의 시장지배적 사업자에 대한 비대칭 규제의 법적 성격에 관한 소고 ", 『정보법학』, 제9권 제1호. 2007. 본 연구기관은 이 연구를 통해서 규제체계를 위와 같이 나누고, 통신시장에 보다 정통한 통신당국의 규제를 우선으로 하되, 규제방식은 행정법적, 공법적 규제보다는 '계약친화적 규제'로 그 내용이 진화하여야 함을 밝힌 바 있다.

에 직접적으로 영향을 주고받는 공급자와 경쟁자들의 시장 내 역학관계 및 기업의 직접적인 이해당사자들을 살펴, '경쟁저해성'의 관점에서 규제가 이루어지는 것이 미시경제적 규제이며, 이것이 경쟁법 규제의 본체라고 할 것이다.

나. 거시경제적 규제

통신산업의 규모, 특징, 현대 사회에서 통신산업이 사회나 개인에게 미치는 영향 등을 고려할 때 미시경제적 관점에 의한 규제의 틀에서 벗어난 시경제적 관점에서의 접근 역시 필요하다고 할 것이며, 여기서 종래의 경쟁법 당국의 규제와는 차별화된 사업법 당국 규제의 존재의 의미가 되살아난다고 할 것이다.

정보통신산업의 발전을 위한 방향성, GDP대비 중요도, 소득과 부의 재분배, 실업예방, 물가안정, 서비스 및 품질의 보호, 보편적 역무의 확보, 가격보호, 다양한 정보·관점에 대한 소비자의 접근성 보장, 지역사회 및 문화 발전 등의 거시적인 관점에 의한 규제는 사업법 당국에 의하여 가능한 것이며, 이러한 규제 관점의 차이에서 권한배분의 문제는 극복될 것으로 보여 진다.

〈개정안〉

제28조(이용약관의 신고 등) ③ 제2항 본문의 경우 미래창조과학부장관은 이용약관이 다음 각 호의 기준에 맞으면 이용약관을 인가하여야 한다.

1. 전기통신서비스의 요금이 공급비용, 수익, 비용·수익의 서비스별 분류, 서비스 제공방법에 따른 비용절감, 공정한 경쟁 환경에 미치는 영향, 공공요금의 안정성, 물가변동 그 밖의 경제 상황의 변화 등을 합리적으로 고려하여 산정되었을 것

제29조의1(요금 조정 권고) 미래창조과학부장관은 공공요금의 안정성, 물가변동, 그 밖의 경제 상황의 변화 등을 고려하여 필요한 경우 기간통신사업자에게 전기통신서비스 요금의 조정을 권고할 수 있다.

3. 착취남용 규제에서 종단통합 규제로[88)]

가. 착취남용 규제

일반적으로 수직적 착취 행위는 가격 남용과 출고 조절 등의 독점 이윤을 추구하는 사업자의 남용행위로 인한 폐해가 거래상대방에게 미치는 경우를 일컫는다. 시장지배적 사업자가 계약 상대방과 체결하는 계약 내용과 조건에 의하여 독점 이익을 추구할 때, 당해 계약 상대방에 대한 이익 저해는 직접적으로 발생한다. 이는 시장지배적 사업자가 시장 지배력이 강할수록 더욱 현저하게 나타날 수 있다.

수직적 착취 규제의 경우, 2단계의 주장·입증을 필요로 한다. ① 경쟁자를 착취할 것, ② 그러한 착취행위로 인하여 해당 시장에 경쟁이 저해되었을 것이 바로 그것이다. 그러나 경쟁자에 대한 침해가 경쟁저해 효과를 초래한다는 것이 법원에서 입증되는 것은 매우 어려운 일이다.

우선 사업법 당국은 규제대상인 기업들로부터 직·간접적으로 정보를 받거나 자체적으로 전문지식에 접근할 수 있는 역량을 갖추고 있으며 업계 전 분야에 걸쳐 계속적으로 교류하면서 법원보다 수월하게 경제학적인 접근이나 실증적인 분석을 실행할 수 있어, 사업법 당국이 인가한 영역의 사업 활동에 대해서는 쉽게 경쟁자 침해가 인정되지 않는다.

또한 엄격한 의미에서 경쟁법상 획정된 시장을 달리하는 경우, 비록 경쟁자 침해가 입증되었다 하더라도 이로 인한 경쟁저해 효과의 인과관계를 입증하는 것은 매우 어렵다. 더욱이 관련 시장이 수직적으로 통합된 통신시장에서의 경쟁저해 효과는 그로 인한 편익으로 인하여 상쇄되는 것이 대부분이며, 이미 통신산업 분야에서는 종래의 사업자별 구분이 무의미할 정도로 네트워크 간 융합과 수렴이 일반화되어 있다. 이로 인해 경쟁저해를 판단할 시장을 획정하는 것은 지극히 상대적인 것으로 되어 이로 인한 제재나 가벌성의 정당성을 찾는 것이 매우 힘

88) 이영대·최경규, “시장지배적 남용행위 중 소비자 이익 저해 행위에 대한 규제 방안”, 『2012년 상반기 법·경제분석그룹(LEG) 연구보고서』, 연구 2012-01차. 공정거래조정위원회. 2012. 7.

들어진 것이다.

나. 수직적 종단통합형 규제로

통신사업자가 기존의 독점적 이익을 지렛대로 하여, 해당 사업분야에서 파생한 전기통신사업분야, 광섬유 설비를 이용한 서비스 분야에서의 경쟁을 유리하게 전개할 수 있는 지위에 있는 경우, 사업 분야 전체를 종단하는 통합형 규제가 필요하다. 즉 이러한 사업자는 상류시장인 기존 독점적 시장을 이용하여 그로부터 파생시장인 하류시장에서의 전략에서 우위에 설 수 있는 상황에 있었으므로, 동사는 시장지배적인 '수직적 통합' 사업자라고 할 수 있는 것이다.

수직적으로 통합되고 독점적 지위를 향유할 수 있는 사업자가 독점화되어 있지 않은 시장에서 취하는 가격전략에는, 그 지배적 지위에 알맞은 업적의 대가로서의 가격을 요구하는 경우와, 경쟁 상태에 있는 시장에서 요구하는 경쟁가격을 요구하는 경우이다. 전자의 경우는 일반적으로 독점적 고가격이 설정되고, 후자의 경우에는 역으로 저가격에서의 가격전략이 전개되게 될 것이다.

독점적 고가격을 설정하는 경우는 경쟁사업자가 경쟁에서 유리한 조건을 맞게 되는 것이므로 경쟁법 위반으로 보기 어려우나, 반대로 저가격 전략을 사용하는 경우, 상류시장에서의 독점적 지위를 이용하여 하류시장에서 경쟁자가 자신의 비용 구조로는 그 시장에서 대항할 수 없도록 하는 현상이 발생할 수 있다. 그런데 이러한 현상에 있어서 예측 가능한 가변비용을 입증하지 못하는 한 반경쟁적인 약탈적 가격행위를 중요한 지표로 쓸 수 있는 증거는 극히 제한적일 수밖에 없고, 하류 시장에서의 경쟁자 배제 내지 이로 인한 경쟁저해 효과를 입증하는 것은 매우 엄격한 증거조사의 관문을 통과해야 하기 때문에 이를 경쟁법 하의 약탈적 가격설정이나 착취적 남용 행위로 규제할 수 있는 경우는 극히 희소하다고 할 것이다.

따라서 사업법에서, 위와 같은 경우에 경쟁법에 의한 엄격한 분석을 거칠 필요 없이, 수직적 통합 사업자에 의하여 결정된 해당계약의 체결비용 및 가격 그 자체를 평가하는 것에 중점을 두어 수직적 종단통합

형의 규제를 할 수 있는 방안을 도입하는 것이 필요하다고 할 것이다.

더 나아가 엄격한 실체법상 구성요건의 입증을 입법에 의한 법률상 추정, 실제 재판과정에서의 사실상 추정, 주장 입증책임의 전환 및 경감 등 소송법상의 합리적인 대안으로 해결하는 방법 역시 모색되어야 할 필요가 있다. 가령 상류시장에서의 경쟁자 침해 사실이 입증되면, 하류시장에서의 경쟁저해 사실을 추정시키고, 경쟁저해 사실이 없다는 입증책임을 상대방에게 전환시키는 입법을 추진하는 것이다

〈개정안: 신설〉

제50조의1(독점적 지위의 추정) 제6조의 규정에 의한 기간통신사업자 중 시장점유율이 100분의 25 이상인 사업자는 독점적 지위의 기간통신사업자로 추정한다.

제50조의2(독점적 지위의 기간통신사업자의 금지행위) 독점적 지위의 기간통신사업자는 다른 전기통신사업자, 전기통신산업과 관련된 다른 사업자를 그 외 전기통신사업자나 다른 사업자와 차별하는 행위를 해서는 아니 된다. 다만, 독점적 지위의 기간통신사업자가 차별적 취급에 대한 정당한 사유를 입증한 경우에는 그러하지 아니 하다.

4. 일반 규정에서 구체적 규정으로

가. 일반 규정

사업법과 경쟁법의 중복규제의 문제가 발생하는 이유 중 하나는 통신산업 분야에서 일체의 기술적 규제·시장진입에 대한 규제·통신서비스요금 책정과 같은 계약 조건의 설정에 관한 규제 등에 있어 전반적인 규제권한을 갖는 전문적인 규제기관이 사업법 당국임에도 불구하고, 그 사업법에서 통신산업 분야 전반에 대한 규제의 구체적인 근거규정을 두고 있지 아니하는 데에 있다. 이처럼 사업법이 규제를 요하는 일정한 경우에 대하여 구체적으로 규정하고 있지 아니하고, 공정한 경쟁 환경 조성을 위한 일반 규정의 형태를 띠어, 부득이 경쟁법에 근거한 규제가 발동되게 되고 여기에 사업법 당국의 일반적 규제권한이 중

복되는 문제가 발생하게 되는 것이다.

나. 구체적 규정

사업법에서 전기통신사업자의 반경쟁적 행위에 관한 규제의 구체적 근거 조항을 두어 사업법 당국의 규제 권한을 분명히 하고, 그 해석과 집행에 있어서 본 연구가 제시하는 방안들을 고려한다면, 사업법과 경쟁법의 중복규제의 문제는 극복될 수 있을 것이다.

〈개정안: 신설〉

제50조의 1 (불공정거래행위의금지) 전기 통신사업자는 다음 각 호에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 부당하게 거래를 거절하거나 거래의 상대방을 차별하여 취급하는 행위

2. 부당하게 경쟁자를 배제하는 행위

3. 부당하게 경쟁자의 고객을 자기와 거래하도록 유인하거나 강제하는 행위

4. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

5. 거래의 상대방의 사업활동을 부당하게 구속하는 조건으로 거래하거나 다른 사업자의 사업활동을 방해하는 행위

6. 제1호 내지 제5호 이외의 행위로서 공정한 경쟁을 저해할 수 있는 행위

더불어 「전기통신사업법」에서 통신사업자에 대한 인허가권은 미래부장관에게 있는바, 미래부장관이, 단지 의견을 제출하는데 그치지 아니하고, 위와 같은 행위 등에 관한 직접적인 규제의 권한도 갖는다고 봄이 상당하다.

〈개정안: 신설〉

제52조의 2(시정명령) 미래창조과학부장관은 제50도 제1항 및 제50조의1을

위반한 행위가 있다고 인정하면 전기통신사업자에게 당해 위법 행위의 중지, 재발방지 조치 기타 시정을 위한 필요한 조치를 명할 수 있다.

5. 실체적 경합에서 상상적 경합으로

가. 실체적 경합

사업법과 경쟁법 양자의 관계에 관해서, 일반법·특별법이라는 형식적 구분에 근거하여 양자가 모두 문제가 되는 경우에 사업법이 우선한다는 입장과[89] 사업법과 경쟁법을 완전한 실체적 경합으로 인정하여 모든 경우에 함께 적용하는 것으로, 통칙적 법으로서의 경쟁법의 적용을 어떤 사업영역이든 우선 고려하고 사업법의 적용은 이와는 완전히 독립적으로 존재하여 필요성 및 적용 범위가 완전 배타적이라는 것이라는 입장[90]의 양 극단이 존재한다.

그러나 위의 양 견해 모두 개별·구체적인 문제 해결에 있어서 그 필요성이 높다고 보이는 경우에 사업법의 적용이 고려될 뿐, 일률적으로 형식적인 기준에 의하여 적용의 우선이 결정되거나 혹은 경쟁법이 전면적으로 적용 되거나 하지 아니하는 현실을 반영하지 못하고 있다.

나. 상상적 경합

사업법과 경쟁법의 중복 규제의 문제를 상상적 경합관계로 보아 해결하자는 견해는, 사업법과 경쟁법 양자 모두가 문제되는 경우에 그 법률 효과와 제재 조치를 유기적으로 해석하여 이를 상상적 경합으로 보아 개별적으로 적용법을 결정해야 한다는 것으로, 이에 따르면 진입/퇴출 규제, 보편적 역무 제공의무 위반, 약관 및 요금 규제 및 접속의무

89) 土田和博 「独占禁止法と事業法による公益事業規則の在り方に関する一考察」159ｐ.
90) 岸井大太郎「公益事業の規制改革と独占禁止法」日本経済法学会年報第23号『公益事業の規制改革と競争政策』(2002年) 33ｐ

위반 등의 개별적 사안에서 사업법과 경쟁법 위반의 효과와 제재 수위에 관하여 심층적으로 검토한 후에 그 중 중한 제재를 선택하여 처벌하는 것이 필요하게 된다. 더불어 이에 의하면, 위원회 심결 수준이 아닌 법원의 판결에 의한 제재를 받는 경우 기판력의 확장으로 인한 이중처벌도 금지되며, 과징금을 부당이득의 환수로 보는 입장에서 과다징수가 있는 경우, 환급청구 내지 반환청구가 인정되거나 과징금 부과단계에서는 적극적 공제 요소가 될 것이다.

〈개정안〉

제54조(다른 법률과의 관계) 제50조 제1항을 위반한 전기통신사업자의 행위가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 위반에도 해당하는 경우에는 이에 대하여 제52조에 따른 조치를 명하거나 제53조에 따른 과징금을 부과함에 있어 형법 제40조의 예에 따른다.

6. 경쟁자 보호에서 소비자 보호로

가. 경쟁자 보호

사업법의 출발점은 사업영역을 확보하는 것이다. 따라서 동일 사업법에 의한 인허가를 받은 사업자들의 영역을 조화롭게 공존시킬 책임이 행정당국에 존재하는바, 경업자의 이익을 보호하고, 경업금지의 공법적 가이드라인을 설정하며, 기본적인 경쟁의 자유를 향유하도록 보장하여야 한다. 만일 이러한 경쟁사업자로서의 법적 지위가 침해되면, 이는 법률상 보호이익을 침해한 것으로 보아 소송상 당사자 적격을 부여받게 된다.

그러나 네트워크 경제의 중요한 특성인 외부성, 기업용 시장과 가정용 시장의 2원적 구조, 통신시장의 공공재적 성격, 사회간접자본으로서의 국민경제에서의 역할 등을 종합할 때, 최종 소비자에 의한 권리 구제와 이를 위한 원고 적격 확대가 필연적이라고 할 것이다.

나. 소비자 보호

최근 전기통신산업 분야에서 '망 중립성'의 논의가 뜨거운 감자로 떠올랐다. 망 중립성은 진화하는 개념으로 아직 명확하고 구체적인 합의는 없으나, 우선은 모든 네트워크 사업자는 모든 콘텐츠를 동등하게 취급하고 어떠한 차별도 하지 않아야 한다는 개념으로 이해할 수 있다. 통신망을 사용하는 콘텐츠는 그것이 음성이든 문자든 멀티미디어 데이터든 공정하게 대우받아야 하며, 유·무선 통신사업자는 중립적인 입장에서 망을 운용하여야 한다는 것으로, 모든 인터넷 트래픽이 동등하게 취급되어야 한다는 비차별의 원칙, 인터넷 서비스 제공사업자는 모든 고객 정책을 공개하여야 한다는 투명성의 원칙, 인터넷 서비스 제공사업자는 합법적인 콘텐츠, 네트워크에 해가 되지 않는 단말기와 자신들의 제공 서비스와 경쟁하는 서비스의 차단을 할 수 없다는 차단금지의 원칙, 네트워크 관리관행이 인터넷 서비스의 기술과 망구조를 고려하고 합법적인 망 관리목적을 위해 적절히 설계·운영되고 있다면 합리적인 것으로 인정할 수 있다는 합리적 망 관리의 원칙 등을 포함하는 개념이다.[91] 최근 스마트폰, 노트북 등 디지털기기를 통한 대규모 데이터를 이용하는 인터넷 환경이 대중화·일반화되어 콘텐츠의 대용량화가 급증하고 인터넷 망의 과부하 또한 증가하면서, 통신사업자가 '망 혼잡 관리'라는 명분 아래, 스마트폰 등의 일부 콘텐츠에 대한 이용자들의 접근을 차단하려는 시도를 보이면서 망 중립성이 이슈화 되고 있다. 이처럼 네트워크 망을 보유하고 있는 통신사업자가 일방적으로 일정 콘텐츠의 망 사용을 거절하는 경우, 소비자들의 당해 콘텐츠에 대한 접근이 차단되고, 결국 소비자에게 망 이용요금이 전가되는 결과가 초래된다고 할 것이다.

네트워크 통신망의 공공재적 성격, 사회간접자본으로서 국민경제에 미치는 영향 등을 고려할 때, 위와 같은 통신사업자의 일방적인 행위에 의하여 침해 될 수 있는 최종 소비자의 권리구제를 위하여 원고적격을 확대하는 입법적 방안이 모색 되어야할 필요가 있다고 할 것이다.

91) 신종철, 통신법해설-전기통신사업법의 해석과 사례, 진한엠앤비. 212p.

〈개정안: 신설〉

제52조의2(금지행위 유지청구) 전기통신사업자의 제50조 제1항 위반 행위에 의하여 스스로의 이익이 침해되었거나 침해될 우려가 있는 제3자 또는 이용자는 전기통신사업자에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구 할 수 있다.

더 나아가 광대역 통신망 시장에서 소비자의 법적 권리 내용을 확장하고 소비자에게 '경쟁 환경을 향유할 수 있는 권리'를 인정하는 입법적 방안 역시 도입되어야 할 것이다.

〈개정안: 신설〉

제34조의2(이용자의 경쟁 환경 향유권 등) 전기통신역무의 이용자는 그 선택에 근거하여 합법적인 콘텐츠 및 전기통신 서비스를 이용할 권리, 적법한 단말을 접속할 권리, 전기통신사업자 간 및 전기통신사업과 관련 다른 사업자간 경쟁 환경을 향유할 권리를 갖는다.

Ⅷ. 맺음 (입법의 방향성 제시)

본 연구에서는 법적관점, 경제적 관점을 통하여 중복규제를 해소할 방안을 마련해 보았다. 현행 규제의 틀 안에서는 정확한 로드맵을 제시하지 못하여 사업법과 경쟁법에 의한 중복규제의 문제가 대두되었는데, 본 연구에서 제시하는 틀을 사용한다면 보다 구체적이고 현실적으로 중복규제의 문제를 대처할 수 있을 것이다.

먼저 사업법과 경쟁법 중 선택적 배타적으로 적용하려는 법조 경합적 해석방안은 더 이상 유효하지 않다. 통신시장의 현황을 살펴보면, 인허가 사업자의 경쟁제한적 행위는 당연히 독점의 구성요건에 포섭되어 경쟁법에 의한 규제의 필요성이 존재하기 때문이다. 그럼에도 경쟁의 실질적 제한이라는 대 시장효과를 입증하기 어렵다는 점, 경쟁법 위반의 제재는 국가에 따라서는 시정조치, 실손 전보에 그치는 것이 아니라, 형사처벌, 징벌적 배상에 까지 이르기 때문에 보다 엄격한 심사가 구제절차에서 요구된다는 점, 다양한 미디어 통신 환경에서 전통적인 관련 시장 획정과 시장지배력을 산정하는 방법이 더 이상 통용되기 어렵다는 점 등의 이유로, 실제 경쟁법적 규제의 적용에는 많은 어려움이 따른다. 특히 원고가 경쟁자가 아닌 일반 소비자인 경우는 당사자 적격이라는 소송요건까지 겹쳐 더욱 권리보호의 가능성이 희박하고 할 것이다.

이러한 점을 극복하기 위해 각국에서는 다양한 노력들이 전개되고 있으며, 이러한 노력은 우리의 규제 체제에도 의미 있게 반영되어야 할 것이다.

먼저, 행정법적 경성의 규제가 계약법적 연성의 규제로 변화하고 있는 것이 바로 그것이다. 당사자 사이의 계약의 공정성을 확보하는 규제의 방법으로 경쟁제한적 행위가 이루어진 이후에 이를 경쟁법적인 관점에서 구제하는 방안과 아울러 계약 체결 당시 그 계약 조건 자체의 공정성 기준을 공유할 수 있는 방안이 고려 될 수 있으며, 후자의 경우는 사업법 당국에 의한 규제로서 가능할 것이다.

또한 규제에 있어, 기업 간 혹은 한 기업에 직접적으로 영향을 주고받는 경쟁자들의 시장 내 역학관계, 기업의 직접 이해당사자들 만을 고려하는 미시적인 관점에서 벗어나 경제나 행정, 기술, 정치, 법률, 문

화, 지역사회에 걸쳐 기업과 직·간접적인 이해관계가 있거나 기업의 활동에 영향을 받을 수 있는 외부적 요소들을 장기적으로 고려하는 거시적인 관점이 도입되어야 할 것이며, 여기서 종래의 경쟁법 당국의 규제와는 차별화 된 사업법 당국 규제의 의미를 찾을 수 있을 것이다.

통신사업 분야에서는 전통적인 시장획정에서 사용되는 단일하고 동일한 시장 개념이, 종단적·통합적 개념으로서의 네트워크 개념으로 진화되었다. 이에 SMP와 같이 사업법 상 규제대상을 사전에 지정하여 규제의 효율을 달성하려고 하는 방안의 도입이 필요하다. SMP는 경쟁법 상 시장지배자 지위를 사업법 상 반영하되, 보다 완화된 요건을 규정하여 권리보호의 이익을 확장하고, 수직적 종단통합형 규제가 가능하게 한다.

더불어 기본적 사실관계가 동일한 사안에 대하여 사업법 위반과 경쟁법 위반이 모두 문제되는 경우, 이를 상상적 경합으로 보아, 양자의 법적효과를 심층적으로 분석하여 보다 중한 규제에 의해 규율될 수 있도록 하는 입법 방안을 도입하여, 사업법과 경쟁법이 조화롭게 적용될 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

또한 사업법상 구제 적격도 경쟁자 보호에서 소비자 보호의 개념으로 확대되어야 한다. 다양한 네트워크 간 경쟁관계를 인정하고, 각 네트워크 간의 접속을 보장하는 중립성 원칙과 네트워크 외부성에 따라 확장되는 소비자 권리에 있어 무차별적이고 평등한 조건을 제시하는 보편적 역무 개념의 수정을 통해 통신사업자에게 부여되는 경쟁촉진 조건의 구체적 내용을 명확히 하여, 경쟁자 보호와 소비자 보호를 유기적으로 연결하여 규제의 목적을 달성하려는 모색이 요구된다. 나아가 소비자에게 경쟁당국의 시정조치 청구권을 인정하는 입법례를 참고하여 중지청구 등에 대한 원고적격을 확대하는 노력 역시 필요하다고 할 것이며, 더 나아가 광대역 통신망 시장에서 소비자의 법적 권리 내용을 확장하고 소비자에게 '경쟁 환경을 향유할 수 있는 권리'를 인정하는 입법적 방안 역시 도입되어야 할 것이다.

끝으로 입법의 핵심은 소송법적 절차 보완에 있다고 할 것이다. 종래의 인가의 적법성을 추정하는 전통적 해석 방안을 토대로, 경쟁자 보호에서 경쟁 보호로의 입증책임의 완화, 특정 시장에서의 독점력의 관련 시장으로의 전이에 관한 법률상 추정 등 절차적 편의주의를 통해

통신 사건의 입증에 있어서의 정보 비대칭을 치유하는 입법적 결단이 요구된다고 할 것이다.

참고문헌

공정거래위원회, 의결 제2005-331호, 사건 2005단체0162. 2005. 12. 15.

권오승 편, 『통신산업과 경쟁법』, 법문사, 서울. 2004

_____ 편, .『정보통신과 공정거래』, 법문사, 서울. 2006.

권오승・이원우 편, 『공정거래법과 규제산업』, 법문사, 서울. 2007.

김윤정, "통신위원회의 최근 주요 심결례 연구", 『경제규제와 법』 제1권 제1호, 서울대학교 공익산업법센터. 2008.5.

김정현, "통신법상 금지행위 규제의 문제점과 개선방안", 서울대학교 공익산업법센터 2008년도 상반기 제3회 세미나 발표자료. 2008.4.

김정현 외, 『전기통신사업 금지행위 유형 재정립 및 시정조치 다양화 방안 연구』, 정보통신정책연구원. 2007.12.

김태영, 최영석 『아시아를 호령할 4마리 잠룡』, 미래에셋 투자 보고서. 2007. 5

김태호, "방송통신시장 경쟁규제에서 일반경쟁규제기관과 전문규제기관 간의 권한 배분", 『경쟁규제와 법』, 제1권 제2호. 2008.

김희수・김형찬・이종화・이상규・김원식・곽정호・오기환, 『통신사업의 합리적 비대칭 규제방안 연구』, 연구보고 01-52, 정보통신정책연구원. 2001. 12.

김희수・이원우・한기정・유진식・오기환, 『정보통신시장에서의 공정경쟁환경조성 및 이용자보호를 위한 법제도 개선방안 연구』, 한국전산원.

2002. 12.

김희수·이종화·김형찬·이상규·변정욱·김민철·김정현, 『통신서비스 시장획정 : 방법론 및 주요이슈』, KISDI 이슈리포트 04-07, 정보통신정책연구원. 2004.

문상덕, "전기통신사업분야에 있어서 금지행위의 유형", 이원우 편, 『정보통신법연구 III - 통신법상 이용자 보호 및 공정경쟁을 위한 규제제도의 주요 쟁점과 개선방향』, 경인문화사. 2008. 5.

미국법판례연구회, "<판례연구> 미국 반(反) 독점적 기업 활동(Trust)집단소송에서 병행행위에 관한 변론기준을 엄격히 한 연방최고재판소", 제5회 미국법판례연구회. 2008.

박동주, 『정보통신시장에서의 통신규제정책 연구: 통신위원회와 공정거래위원회간 역할 재정립을 중심으로』, 서울대학교 행정대학원. 2003.

손금주, "전기통신사업법 제54조의 중복규제 여부: 단말기 보조금 관련 방송통신위원회와 공정거래위원회의 규제를 중심으로", 『경제규제와 법』, 제5권 제1호. 2012.

설민수, "규제완화와 공정거래법의 적용: 행정지도가 개입된 가격담합을 중심으로", 『저스티스』. 2010. 8.

신영수, "통신시장의 경쟁촉진을 위한 규제기관의 권한 조정", 중앙법학, 제6집 제1호. 2004. 4.

신종철, 『통신법해설: 전기통신사업법의 해석과 사례』, 진한엠엔비. 2013.

안덕근, "통신시장 관련 이중규제 판례 연구: Trinko 사례 중심으로", 『법학논총』, 제24집 제4호. 2007.

오수민, "EU 규제프레임워크 개정 검토안 분석", 『정보통신정책』 제19권 23호, 정보통신정책연구원. 2007.12.

이병태, 『법률용어 사전』, 법문북스. 2010.

이상규·변정욱·김정현, "통신서비스 시장지배력: 정의 및 판단기준", KISDI 이슈 리포트 04-12, 정보통신정책연구원. 2004

이영대, "통신시장에서의 시장지배적 사업자에 대한 비대칭 규제의 법적 성격에 대한 소고", 『정보법학』, 제9권 제1호. 2007.

이영대・최경규, "시장지배적 남용행위 중 소비자 이익 저해 행위에 대한 규제 방안", 『2012년 상반기 법・경제분석그룹(LEG) 연구보고서』, 연구 2012-01차. 공정거래조정위원회. 2012. 7.

이원우, "통신법상 개별약정의 허용성과 그 한계", 『행정법연구』, 제16호. 2006.

_____, "통신시장규제에 있어서 전문통신규제기관과 일반경쟁규제기관의 관계", 『행정법연구』, 제14호. 2005. 10

이원우 편, 『정보통신법연구 I - 통신시장에 있어서 전문규제기관과 일반경쟁규제기관의 관계』, 경인문화사. 2008.

_____, 『정보통신법연구 III - 통신법상 이용자 보호 및 공정경쟁을 위한 규제제도의 주요 쟁점과 개선방향』, 경인문화사. 2008.

이익현, "대한민국 경제법제 발전 60년사", 「경제법제 선진화 방안 세미나」 발표자료. 전경련・법제처 공동개최. 2011. 11. 23.

이호영, "전기통신사업법상 금지행위 규제의 개선-이용자이익 저해행위를 중심으로-", 『행정법연구』 제20호, 행정법이론실무학회. 2008.

이희정, "통신시장에 대한 경제규제권한의 배분과 조화-영국 모델의 시사점", 『토지공법연구』, 제37집 제1호. 2007. 8.

정보통신정책연구원 편, 『통신서비스정책의 이해』, 법영사, 서울. 2005.

조민행・이윤제・유완석, 『중복규제의 현황과 개선방안 연구』, 법제처. 2008. 12.

홍대식, "전기통신사업자에 대한 사후적 행위규제 제도", 『경쟁법연구』, 제22권. 2010. 11.

황태희, "독일 통신 시장의 경쟁과 규제 개혁", 『주요국가의 기업규제개혁법제에 관한 비교법적 연구』, 한국법제연구원. 2008. 6.

<영문>

Areeda, P. & D. F. Turner, *Antitrust Law,* Little, Brown & Co. 1978.

Areeda, P. *Antitrust Analysis,* Little, Brown & Co. 1981.

Australian Communications Authority, "Telecommunications (Customer Service Guarantee) Scale of Damages 1997," *Communications Legislation.* 2002.

Baker, Jonathan B., “Sector-Specific Competition Enforcement at the FCC," *The Federal Communication*, September 21. 2010.

Beck, Verlag C.H., "The Implications of Asymmetric Regulations on Internet Access," Hellerstein & Associates. March 1999.

Bender, Christian M. et al., "Effective competition in telecommunications, rail and energy markets," *Intereconomics*, Vol. 46, Iss. 1. Springer, Heidelberg. 2011,

Boliek, Babette E.L., "FCC Regulation Versus Antitrust: How Net

Neutrality is Defining the Boundaries", *52 B.C.L. Rev 1627.* 2011.

Chakrabarty, Gargi, "Phone Utility Ameritech Offers Settlement to Indiana Customers," *The Indianapolis Star.* September 20. 2001.

Crandall, Robert W. & James H. Alleman (eds), *Broadband: Should We Regulate High-Speed Internet Access?* AEI-Brookings Joint Center. December, 2002.

Crandall, Robert W., *Debating U.S. Broadband Policy: An Economic Perspective*, The Brookings Institution. March 2003.

Crane, Daniel A. "Has the Obama Justice Department Reinvigorated Antitrust Enforcement?" *Stanford Law Review* 18. July 2012.

Deltorto, Darci, "Pole Position: National Cable & Telecommunications Association v. Gulf Power Co. and the Implications of the FCC's Pole Attachments Act Reaching Higher Ground", *Akron Law Review*, Vol. 37. 2004.

ECJ, "Tetra Pak International SA v Commission of the European Communities, Case C-333/94", ECJ Judgment. 1996.

FCC, "Bell Atlantic/NYNEX Corp.," 32 F.C.C.R. 19,985. 1997.

FCC, "AOL/Time Warner, Memorandum Opinion and Order," FCC 01-12, 16 F.C.C.R. 6547. 2001.

FCC, "News Corp./Hughes Electronics Corp. (DirecTV), Memorandum Opinion and Order," FCC 03-330. 2003.

FCC, "SBC/AT&T, Memorandum Opinion and Order," FCC 06-183. 2005.

FCC, "Verizon/MCI, Memorandum Opinion and Order," FCC 06-184. 2005.

FCC, "Comcast Corp./General Electric Company, and NBC Universal, Inc., Memorandum Opinion and Order," FCC 11-4. 2011.

Faulkner, Sarah, "Invasion of the Information Snatchers: Creating Liability for Corporations with Vulnerable Computer Networks," 18 *John Marshall Journal of Computer & Information Law* 1019. 2000.

Fulton, B. Keith, "The Use of Disclaimers & the Internet's World Wide Web," 6 *Media Law & Policy* 1. 1997.

Futurevision Cable System, Inc. v. MultiVision Cable TV Corp., 789 F. Supp. 760, 766, S.S. Miss. 1992.

Haring, John, Jeffrey H. Rohlfs & Harry M. Shooshan III, "Disabilities of Continued Asymmetric Regulation of AT&T," *Strategic Policy Research*. June 1995

Hartmann, Kevin, "Regulation of Competitive Markets – Two Views from Germany," *CSIS International Communications Studies Program*, Vol. 2 No. 7. June, 1998

Kratternemaker, Thomas G. "The True Believers: Some Thoughts on Competition, Regulation, the FTC and the FCC." *Ftc.gov.* Federal Trade Commission, 16. Sept. 2004.

Kraushaar, Jonathan M., *Quality of Service of the Local Operating Companies Aggregated to the Holding Company Level 1996-1998*, Industry Analysis Division, Common Carrier Bureau, Federal Communications Commission. 1998.

Legg, Michael J., "Telecommunications Access Pricing and Regulator Accountability through Administrative Law and Takings Jurisprudence," *Federal Communications Law Journal*, Volume 56, Issue 3. 2004.

Levin, Harvey J., "Social Welfare Aspects of FCC Broadcast Licensing Standards," *American Journal of Economics and Sociology,* Vol. 13, No. 1. Oct. 1953.

Mann-Stadt, Rendi L., "Limitation of Liability for Interruption of Service for Regulated Telephone Companies: an Outmoded Protection?," *University of Illinois Law Review* 629. 1993.

May, Randolph J. and Richard S. Whitt, "Permissive Forbearance," *Policy Impact, Communications Lawyer*. Summer 1993.

Perritt, Jr., Henry H., *Law and the Information Superhighway*, Wiley Law Publications. 1996.

Pitsch, Peter K., "Common Carrier Regulation of Telecommunications Contracts and the Private Carrier Alternative," 48 *Federal Communication Law Journal* 44. 1996.

Salop, Steven C., "Measuring Entry Barriers and the Rule of Reason," *Antitrust Law & Economics Review*, No. 4. 1983.

Schankerman, Mark and Leonard Waverman, "Asymmetric Regulation, Asymmetric Information and Competition in Multimedia Markets," *Telecom Italia*. September 1997.

Stewart, Morgan, "Commercial Access Contracts and the Internet: Does the

Uniform Computer Information Transactions Act Clear the Air with Regard to Liabilities when an On-Line Access System Fails?," 27 *Pepperdine Law Review* 597. 2000.

U.S. Court of Appeals, "SCFC ILC, Inc. v. VISA U.S.A., Inc., " U.S. Court of Appeals. 18 June 1991. N.p., n.d. Web.

Weiser, Philip J., "Reexamining the Legacy of Dual Regulation: Reforming Dual Merger Review by the DOJ and the FCC," 61 *Federal Communications Law Journal* 167. 2008.

<일문>

岸井大太郎 “公益事業の規制改革と獨占禁止法”, 『公益事業の規制改革と競爭政策』, 日本経濟法學會年報, 第23号. 2002.

키시이 오오타로, “공익사업의 규제개혁과 독점금지법”, 『공익사업의 규제개혁과 경쟁정책』, 일본경제법학회연보, 제23호. 2002.

田中弘昭、“規制緩和市場への參与と獨占的地位の濫用”、神戸學院法學, 第38券 第1号. 2008年9月.

다나카 히로아키, "규제완화시장에의 참여와 독점적 지위의 남용", 고베학원법학, 제38권 제1호. 2008. 9.

土田和博, 「獨占禁止法と事業法による公益事業規則の在り方に關する一考察」. 2006.

츠치다 카즈히로, 「독점금지법과 사업법에 의한 공익사업규칙의 현황에 관한 고찰」. 2006.

土佐和生、“事業法規制と獨禁法規制の排他制御”, 立命官法學, 2・3号 (300・301号). 2005.

토사 카즈오, "사업법규제와 독금법 규제의 배타제어", 입명관법학, 2·3호 (300·301호). 2005.

東條吉純、『米國連邦通信委員會によるネットワーク中立性規則 - 差別行爲の規範的分類の試し-』, 立教大學. 2012. 1. 15.

토죠 요시즈미, 『미국 연방통신위원회에 의한 네트워크 중립성 규칙 -차별행위의 규범적 분류의 시도-』, 릿쿄대학, 2012. 1. 15.

松宮廣和, 『最近米國の情報サービス規制をめぐる論議、再論』, 群馬大學社會情報學部研究論集, 第18券, 97-129頁. 2011. 3. 31.

마츠미야 히로카즈, "최근 미국의 정보 서비스 규제를 둘러싼 논의, 재론," 군마대학 사회정보학부연구론집, 제18권, 97-129쪽, 2011. 3. 31.

情報通信政策研究所、『海外情報通信判例研究会報告書（第1集)』, 総務省. 2010.

정보통신정책연구소, 『해외정보통신 판례연구회 보고서 (제1집)』, 총무성. 2010.

<웹사이트>

http://business.nikkeibp.co.jp/article/NBD/20120426/231421/?ST=pc

http://www.ftc.gov/bc/hsr/introguides/guide2.pdf

http://www.ftc.go.kr/news/policy/competeView.jsp?news_no=1390&news_div_cd=2

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0402/25/news033.html